



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2014/6517 (19957.000592/2015-83)

Data do julgamento: 25/06/2019

Diretor Relator: Henrique Balduino Machado Moreira

Acusados: Eike Fuhrken Batista

José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti

Luiz Eduardo Guimarães Carneiro

Marcelo Faber Torres

Paulo Manuel Mendes de Mendonça

Paulo de Tarso Martins Guimarães

Reinaldo José Belotti Vargas

Roberto Bernardes Monteiro

Ementa: Divulgação de fatos relevantes como instrumento de manipulação de preços da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. Divulgação de fato relevante com omissão material, induzindo investidores a erro. Infração ao inciso I, na forma prevista pelo item II, 'b', da Instrução CVM nº 08/79. Infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 14 da Instrução CVM nº 480/09. Absolvições e Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Por maioria de votos:

1.1. Aplicar ao acusado **Luiz Eduardo Guimarães Carneiro**, na qualidade de diretor-presidente da OGX, a penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$300.000,00** (trezentos mil reais), por não ter agido com o cuidado e a diligência esperados de um administrador de companhia aberta, ao concordar com a divulgação, em 13.03.13, de fato relevante omissivo, induzindo a erro investidores da OGX Petróleo e Gás Participações S.A., em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.

2. Por unanimidade de votos:

2.1. Aplicar ao acusado **Roberto Bernardes Monteiro**, na qualidade de diretor de relações com investidores da OGX, a penalidade de **multa** pecuniária no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), pela divulgação, em 13.03.13, de fato relevante omissivo, induzindo a erro investidores da OGX Petróleo e Gás Participações S.A., em infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09;

2.2. Absolver os acusados **Eike Fuhrken Batista**, **Reinaldo José Belotti Vargas**, **José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti**, **Marcelo Faber Torres** e **Paulo Manuel Mendes de Mendonça**.

2.3. Pela **extinção de punibilidade** para o acusado **Paulo de Tarso Martins Guimarães**, em razão do seu falecimento no curso do processo.

A Sessão de Julgamento do presente processo foi iniciada em 27 de maio de 2019, ocasião em que o Diretor-relator Henrique Machado reconheceu a **extinção de punibilidade** para o acusado Paulo de Tarso Martins Guimarães, em

razão do seu falecimento no curso do processo e votou pela (i) pela aplicação da penalidade de **multa** pecuniária individual no valor de **R\$300.000,00** (trezentos mil reais) para os acusados Roberto Bernardes Monteiro e Luiz Eduardo Guimarães Carneiro; e (ii) pela **absolvição** dos acusados Eike Fuhrken Batista, José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti, Marcelo Faber Torres, Paulo Manuel Mendes de Mendonça e Reinaldo José Belotti Vargas. Após a leitura do voto do Relator, o Presidente Marcelo Barbosa pediu vista dos autos, e suspendeu a sessão.

Presentes, na ocasião, os advogados (i) *Darwin Corrêa e Ricardo Loretto*, representantes do acusado Eike Batista; (ii) *Renata Moritz Serpa Coelho*, representante dos acusados Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, Reinaldo José Belotti Vargas e Roberto Bernardes Monteiro; (iii) *Maria Isabel Bocater*, representante do acusado Paulo Manuel Mendes de Mendonça; e (iv) *Julian Fonseca Chediak*, representante do acusado Marcelo Faber Torres.

Presente o acusado José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti, que fez a sua própria defesa oral.

Presente a procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada na CVM.

Presentes os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Gonzalez.

Em 25 de junho de 2019, na continuação da Sessão de Julgamento, o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, em sua manifestação, apresentou observações sobre o dever de diligência e sua relação com o dever de informar, bem como sobre sua aplicação no caso concreto e concluiu que não seria possível responsabilizar Luiz Eduardo Guimarães Carneiro pelo descumprimento do art. 153, da Lei 6.404/76, motivo pelo qual votou pela **absolvição** do acusado, acompanhando, no tocante aos demais acusados, as conclusões do voto do Diretor Relator.

O Diretor Gustavo Gonzalez apresentou manifestação de voto explicitando as razões pelas quais acompanhou as conclusões do Diretor Relator inclusive no tocante à acusação de falta de diligência formulada contra Luiz Eduardo Guimarães Carneiro.

A Diretora Flavia Perlingeiro, em seu pronunciamento de voto, acompanhou as conclusões do voto do Diretor Relator e teceu algumas considerações sobre a sua concordância com a imputação de descumprimento do dever de diligência atribuído ao acusado Luiz Eduardo Guimarães Carneiro.

O Diretor Carlos Alberto Rebello também acompanhou o voto do Relator.

O Colegiado decidiu, por fim, comunicar o resultado do presente julgamento à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/Nº 55/2014.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Presentes na continuação da Sessão de Julgamento os advogados (i) *Renata Moritz Serpa Coelho*, representante dos acusados Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, Reinaldo José Belotti Vargas e Roberto Bernardes Monteiro; (ii) *Fabio Lemos de Oliveira*, representante do acusado Paulo Manuel Mendes de Mendonça; e (iii) *Julian Fonseca Chediak*, representante do acusado Marcelo Faber Torres.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da continuação da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 08/08/2019, às 22:53, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 09/08/2019, às 09:22, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 12/08/2019, às 17:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 12/08/2019, às 18:37, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 13/08/2019, às 16:45, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0801917** e o código CRC **80A1E7DA**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0801917** and the "Código CRC" **80A1E7DA**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/6517

Reg. Col. nº 9468/2014

Acusados: Eike Fuhrken Batista
José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
Marcelo Faber Torres
Paulo Manuel Mendes de Mendonça
Paulo de Tarso Martins Guimarães
Reinaldo José Belotti Vargas
Roberto Bernardes Monteiro

Assunto: Divulgação de fatos relevantes como instrumento de manipulação de preços das ações da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (atual Dommo Energia S.A.). Divulgação de fato relevante omissivo relacionado aos negócios da Companhia. Infração ao inciso I da Instrução CVM nº 08/79. Infração ao artigo 153 da Lei 6.404/76 combinado com o art. 14 da Instrução CVM nº 480/09.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador **instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas** (“SEP” ou “Acusação”) em face de Eike Fuhrken Batista (“Eike Batista”), José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti (“José Cavalcanti”), Luiz Eduardo Guimarães Carneiro (“Luiz Carneiro”), Marcelo Faber Torres (“Marcelo Torres”), Paulo Manuel Mendes de Mendonça (“Paulo Mendonça”), Paulo de Tarso Martins Guimarães (“Paulo Guimarães”), Reinaldo José Belotti Vargas (“Reinaldo Vargas”) e Roberto Bernardes Monteiro (“Roberto Monteiro”), na qualidade de administradores da OGX Petróleo e Gás Participações (“OGX” ou “Companhia”), para apurar supostas irregularidades na divulgação de fatos relevantes entre 2009 e 2013 pela Companhia.

2. Segundo a SEP, os administradores da OGX teriam feito divulgações inadequadas, com conteúdo excessivamente otimista e notadamente sem relevância material, com o intuito de **dolosamente alterar o valor da cotação das ações emitidas pela Companhia**, em infração ao inciso



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

I da Instrução CVM nº 08, de 08 de outubro de 1979¹, e ao art. 153 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976², combinado com o art. 14 da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2002³.

3. O presente processo originou-se do Processo CVM nº RJ2013/7307, que tratou de diversas **reclamações de investidores** sobre a adequação das publicações realizadas pela OGX. Tais reclamações referiam-se ao fato relevante publicado pela Companhia, em 01.07.2013, que informou a inviabilidade econômica no desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia (“Campos”) (fls. 37-38).

II. DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO

II.1 DIRETORIA ESTATUÁRIA

4. A área técnica apurou que, no período das divulgações dos avisos de fato relevante sobre a presença de indícios de hidrocarbonetos (de 02.10.2009 a 26.04.2012), a diretoria estatutária da OGX (fls. 1711-1717) seria composta por:

- a) Paulo Mendonça, eleito diretor de operações na reunião do conselho de administração (“RCA”) de 03.09.2007⁴;
- b) Marcelo Torres, eleito diretor financeiro e diretor de relações com investidores (“DRI”) na RCA de 03.09.2007;
- c) José Cavalcanti, eleito diretor jurídico na RCA de 06.08.2008;
- d) Reinaldo Vargas, eleito diretor de desenvolvimento da produção da companhia na RCA de 06.08.2008; e
- e) Eike Batista, cuja participação na Companhia era de mais de 60%⁵, eleito diretor presidente na RCA de 22.04.2009.

¹ I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda.

² Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

³ Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

⁴ A partir de 22.04.2009, seu cargo passou a ser de diretor geral e de exploração e produção.

⁵ Segundo os Formulários de Referência da OGX, Eike Batista teria, por meio de seus veículos de investimento Centennial Asset Mining Fund LLC e Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLC, 1,98 bilhões de ações que, cotadas a R\$ 23,39, representariam uma quantia aproximada de 46 bilhões de reais (fl. 1781).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II.2 DIVULGAÇÕES DE INDÍCIOS DE HIDROCARBONETOS

5. A SEP consigna em seu relatório que, entre 02.10.2009 e 26.04.2012, a OGX teria divulgado 82 Fatos Relevantes, sendo que, em 54⁶ deles, teria informado ao mercado a presença de indícios de hidrocarbonetos (fls. 446-503). As divulgações se diferenciariam por: (i) determinar o bloco e poço em que foram encontrados os indícios, (ii) haver ou não a descrição de detalhes da coluna e do *net pay*⁷ do reservatório, (iii) haver ou não estimativas de volume de óleo recuperável⁸ no reservatório descoberto pelo poço, e (iv) haver ou não declarações de administradores a respeito da descoberta.

6. A área técnica fez sua análise sobre a adequação das divulgações por meio do cotejo de seus correspondentes conteúdos à: (i) política de divulgação de informações da Companhia; (ii) legislação e regulamentação específica do setor de óleo e gás realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”); (iii) divulgação de estimativas durante a perfuração; (iv) relevância das divulgações; (v) prática usual de empresas do setor; e (vi) manifestação dos administradores envolvidos, conforme se sumariza a seguir.

II.2.1 POLÍTICA DE DIVULGAÇÕES

7. Segundo apurado, Paulo Mendonça informou (fls. 628-639) que, de acordo com o item 6 da Política de Divulgação e Uso de Informações para o Mercado da OGX (“Política”) (fls. 650-664), a Companhia possuiria um Comitê de Divulgação e Negociação (“Comitê”) presidido pelo diretor presidente e composto pelo diretor de relações com investidores, diretor jurídico, gerente de relações com investidores e eventuais representantes indicados.

8. Além disso, o item 12 da Política obrigaria que a divulgação de Fato Relevante fosse coordenada pelo Comitê, o qual poderia solicitar a participação das diretorias envolvidas na operação ou no negócio de origem do Fato Relevante.

9. José Cavalcanti, por sua vez, informou (fls. 1418-1425) que o Comitê jamais teria sido instalado. Segundo ele, não teria se enxergado utilidade prática, uma vez que a elaboração e divulgação dos Fatos Relevantes caberiam ao DRI, Marcelo Torres, e quando tratassem de informações de natureza técnica, essas seriam fornecidas pela área técnica da Companhia.

10. Marcelo Torres afirmou (fls. 1382-1384) que todo documento de divulgação seria elaborado sob a coordenação de um grupo de profissionais, que, na prática, seria composto pelos membros do Comitê e demais membros da diretoria. No momento em que uma originasse um fato

⁶ Dentre os 54 Fatos Relevantes do período mencionado, haveria (i) 34 com declarações de Paulo Mendonça; (ii) três com declarações de Paulo Mendonça e Eike Batista; (iii) um com declarações de Paulo Mendonça e Reinaldo Vargas; e (iv) 16 sem declarações de administradores da Companhia (fls. 2162 – 2165).

⁷ De maneira simplificada, a descrição da coluna do reservatório representaria a estimativa do tamanho vertical do reservatório, enquanto que a estimativa de *net pay* representaria a altura que efetivamente pode ser extraída.

⁸ No caso concreto, a estimativa do volume de óleo recuperável representaria o que a Companhia esperava extrair de petróleo de certa área – informação que seria utilizada para estimar as receitas do projeto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

relevante, os diretores se reuniram com a área de relações com investidores e a área técnica envolvida na atividade em questão para que todos definissem a forma e o conteúdo a ser divulgado. Uma vez aprovado por todos, o documento se tornaria público via Sistema IPE.

11. Eike Batista apenas alegou (fls. 1426-1445) que a fundamentação e avaliação técnicas das divulgações seriam elaboradas pelos profissionais da área de exploração e pela diretoria financeira e de relações com investidores da Companhia.

12. Em sua avaliação, a SEP não considerou razoável o diretor presidente, que também acumulava o cargo de presidente do conselho de administração e **era o acionista controlador da Companhia**, eximir-se da responsabilidade sobre a divulgação de mais de 50 fatos relevantes, inclusive com base em alegações contrárias às afirmações de diretores da Companhia.

13. Uma das competências do diretor presidente, segundo o Estatuto Social vigente à época, seria a de *“conduzir e coordenar as atividades dos Diretores no âmbito dos deveres e atribuições estabelecidos para os respectivos Diretores, pelo Conselho de Administração e pelo presente Estatuto Social, convocando e presidindo as reuniões da Diretoria”* (fls. 1206-1219).

14. Questionado, Reinaldo Vargas alegou (fls. 1474-1478) que não haveria procedimento formal de elaboração de material destinado à divulgação de informações, não podendo ser garantido que todas as minutas tenham circulado pela diretoria. Admitiu também que teria tido acesso e se manifestado sobre algumas divulgações de descobertas de hidrocarbonetos.

15. Com base nessas respostas, a SEP conclui que todos os diretores estatutários da OGX teriam responsabilidade, ainda que distinta entre eles, sobre as divulgações de fatos relevantes durante o período em que permaneceram nos seus respectivos cargos.

II.2.2 LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA

16. Para a SEP, a ANP exigiria, por meio de contrato, a notificação de qualquer descoberta dentro da área de concessão (de petróleo, gás natural, outros hidrocarbonetos, minerais e, em geral, quaisquer recursos naturais) pelo concessionário, no prazo máximo de três dias, acompanhada de todos os dados e informações disponíveis. Após a notificação, a ANP disponibilizaria a informação em sua página na internet.

17. No entanto, de acordo com a SEP, a exigência da ANP do envio da notificação de descoberta não motivaria, por si só, a divulgação de um Fato Relevante que informasse ao mercado essa descoberta, razão pela qual a área técnica decidiu aprofundar a análise do caso.

II.2.3 DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS DURANTE A PERFURAÇÃO

18. Em 16.11.2009, a OGX divulgou Fato Relevante informando a *“descoberta de óleo nos reservatórios do Cretácio Superior no poço 1-OGX-2A-RJS”*, sendo que o volume estimado de óleo recuperável nesses reservatórios seria de *“400 a 500 milhões de barris”* (fl. 49).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

19. A esse respeito, a ANP informou (fls. 509-516) que seria “*impossível, apenas com base em documento de presença de indício de hidrocarbonetos haver estimativa de reservas*”. Antes da conclusão do poço e sua avaliação, dispõe-se “*apenas da estimativa de volumes in place*”⁹ (VOIP/VGIP) prevista no prospecto”.

20. Posteriormente, a ANP teria reforçado o entendimento nos seguintes termos:

(...) uma Descoberta nada mais é que a detecção de uma acumulação de hidrocarbonetos, sem qualquer espécie de consideração quanto a sua economicidade (...). Nesse momento exploratório (e isso é muito importante) não há condições de se prever o volume de hidrocarbonetos extraível do reservatório (fls. 517-518).

21. E, mais adiante, novamente indagada pela área técnica, a ANP teria reiterado o entendimento:

Reafirmo que as estimativas são sempre dadas em volume de hidrocarboneto in place (VOIP). O volume recuperável depende de uma série de informações que só são obtidas ao final dos Planos de Avaliação (...). Na fase inicial mesmo com o poço concluído é impossível que se tenha um fator de recuperação que possibilite conhecer volume de óleo recuperável (fls. 519-523).

22. A partir daí a SEP concluiu que a divulgação do dia 16.11.2009 não seria correta, tendo em vista que a estimativa de volume de óleo recuperável seria segura apenas após a conclusão do poço e de sua avaliação.

II.2.4 RELEVÂNCIA DAS DIVULGAÇÕES

23. A SEP considerou necessário o entendimento do desenvolvimento de um campo petrolífero, desde a sua exploração até a produção, para que a relevância das divulgações de descobertas de indícios de hidrocarbonetos fosse analisada. Por se tratar de tema específico do setor de óleo e gás, usou, como referência, as informações contidas no livro Fundamentos da Engenharia de Petróleo, de Thomas, J. E. et al., Ed. Interciência Ltda., 2001 (“FEP”).

24. Sobre o tema, a área técnica consignou trechos a respeito da descoberta de uma jazida de petróleo em uma nova área¹⁰, e, após etapa inicial de prospecção, haveria a avaliação de formações¹¹. Acrescentou que, seria nessa etapa da perfuração que o concessionário teria a obrigação de enviar a notificação de descoberta à ANP, caso descobrisse indícios de presença de

⁹ Volume de óleo *in place* (VOIP) representaria a totalidade do volume presente no reservatório, enquanto que o volume recuperável representaria somente a parcela que poderá ser extraída do reservatório.

¹⁰ “uma tarefa que envolve um longo e dispendioso estudo e análise de dados geofísicos e geológicos das bacias sedimentares (...) somente após exaustivo prognóstico do comportamento das diversas camadas do subsolo, os geólogos e geofísicos decidem propor a perfuração de um poço, que é a etapa que mais investimentos exige em todo o processo de prospecção”, conforme página 23 do FEP.

¹¹ “estudos que visam definir em termos qualitativos e quantitativos o potencial de uma jazida petrolífera (...). A avaliação das formações baseia-se principalmente na perfilagem a poço aberto, no teste de formação a poço aberto, nos testes de pressão a poço revestido e na perfilagem de produção”, conforme página 121 do FEP.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

hidrocarbonetos no poço perfurado. Se não houver intervalos de interesse, o poço seria abandonado.

25. Extrai do FEP a conclusão de que, mesmo existindo indícios de hidrocarbonetos na formação durante a perfuração e perfilagem, isso não significaria que poderiam ser produzidos economicamente, pois somente o teste de formação (colocação do poço em fluxo) poderia confirmar, com segurança, a presença de hidrocarbonetos e fornecer dados a respeito das condições de fluxo nas imediações do poço. Nessa toada, e após consulta acerca da relevância da notificação de descoberta enviada por um concessionário, a ANP teria afirmado, em linha com as informações do FEP, que *“os indícios de hidrocarbonetos não têm qualquer relevância para a estimativa de produção de petróleo”* (fls. 519-523).

26. Resume a SEP que a descoberta de hidrocarbonetos em uma perfuração representaria apenas uma etapa do longo caminho entre a prospecção e o desenvolvimento de um campo petrolífero, sendo que, após a etapa de descoberta, ainda existiriam inúmeros desafios até que se conseguisse extrair óleo e/ou gás para que, enfim, a sociedade obtenha receita desse campo.

27. No mesmo período em que teriam sido divulgadas as 54 descobertas, a OGX teria divulgado, por meio de fato relevante, a conclusão de cinco testes de formação em poços que haviam sido objeto de divulgações de descoberta de hidrocarbonetos (fls. 593-597). De acordo com o FEP, na interpretação da área técnica, somente o teste de formação poderia *“confirmar, com segurança, a presença de hidrocarbonetos na formação e fornecer dados a respeito das condições de fluxo nas imediações do poço”*.

28. Aponta a SEP, que, no caso da OGX, menos de 10% das descobertas de hidrocarbonetos teriam resultado em divulgações de testes de formação, que representariam uma confirmação da presença de hidrocarbonetos nos poços e forneceriam ainda outros dados de auxílio à Companhia no cálculo de viabilidade comercial daquele campo petrolífero. Parte do número poderia ser explicada pela divulgação de mais de uma descoberta de hidrocarbonetos em um mesmo poço¹² e pelo fato de que, por possíveis razões, a Companhia não realizaria testes de formação em todos os poços em que foram descobertos hidrocarbonetos.

29. A SEP conclui que a notificação de descoberta de hidrocarbonetos, enviada pelo concessionário à ANP, a princípio, não seria informação relevante, nos termos do art. 2º da Instrução CVM nº 358/02, de modo que tal informação não deveria ter sido divulgada ao mercado por meio de aviso de fato relevante.

30. Segundo apurado, a partir de 26.04.2012, a OGX teria decidido informar as descobertas de hidrocarbonetos apenas no apêndice das apresentações institucionais, enviadas¹³

¹² No caso do poço 1-OGX-3-RJS, cujos resultados do teste de formação teriam sido divulgados em 03.02.2010 (fl. 597), também teriam sido divulgadas duas descobertas de hidrocarbonetos, em 18 e 28.12.2009 (fls. 492-493).

¹³ Por exemplo, o comunicado ao mercado enviado em 24.07.2012, cujo apêndice foi anexado às folhas 599 – 604. Cabe destacar, ainda, que as descobertas de hidrocarbonetos seriam divulgadas nas apresentações institucionais desde 19.11.2009, vide fl. 605.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

por meio de comunicados ao mercado. À época dessa alteração, teria havido mudanças na administração com a saída de Marcelo Torres e Paulo Mendonça, respectivamente em 27.04 e 28.06.2012.

31. A partir da referida data, a Companhia teria passado a entender que as descobertas de hidrocarbonetos não seriam relevantes. Tal mudança de avaliação aparentemente teria sido decorrente das alterações na diretoria anunciadas em 27.04.2012, quando da substituição (fls. 606-607) de Marcelo Torres por Roberto Monteiro. Em meados de 2012, a própria Companhia, por meio de deste diretor (fls. 1446-1460), teria reconhecido que as descobertas de hidrocarbonetos não deveriam ser divulgadas por meio de fato relevante.

32. Quanto a isso, Marcelo Torres alegou que (fls. 1379-1384) (i) até o primeiro trimestre de 2012, a OGX seria companhia pré-operacional, cuja valoração do mercado se basearia essencialmente em estimativas; (ii) fatos atinentes a sua campanha exploratória, que pouco impactariam uma companhia em estágio mais maduro, teriam para o investidor da OGX uma importância significativa; (iii) e em razão da descoberta estar disponível no site da ANP, a diretoria teria julgado prudente divulgar as notificações de descoberta por Fato Relevante.

33. Em sua manifestação (fls. 1385-1409), Paulo Mendonça alegou que a OGX seria obrigada a enviar à ANP a notificação de descoberta e que o fato de analistas acessarem o site da agência para obter tais informações demonstraria que o mercado atribuía relevância às notificações, razão pela qual a OGX teria decidido passar ao mercado todas as descobertas comunicadas à ANP.

34. Segundo a SEP, caso se entendesse que a informação deveria ser transmitida aos analistas de mercado, isso deveria ser feito por meio de comunicado ao mercado. Um aviso legal constante dos fatos relevantes, com referência a riscos e incerteza, não informaria a possibilidade de que as informações ali contidas não fossem relevantes para a decisão de comprar, vender ou manter valores mobiliários.

35. A decisão quanto à divulgação de fatos relevantes seria da competência da própria administração da companhia¹⁴, de forma que, ao decidir por divulgar as descobertas de hidrocarbonetos por meio de aviso de fato relevante, os diretores da OGX teriam induzido o mercado a acreditar que aquelas informações eram, de fato, relevantes.

36. Para José Cavalcanti e Reinaldo Vargas (fls. 1418-1425; 1477-1478), a descoberta de hidrocarbonetos poderia ter relevância dependendo do contexto, sendo que, segundo Reinaldo Vargas, essa decisão caberia ao DRI.

II.2.5 PRÁTICA USUAL DE EMPRESAS DO SETOR

¹⁴ Segundo o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/2014. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sep/oc-sep-0114.html>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

37. A SEP realizou buscas por eventuais divulgações, no mesmo período, de estimativas durante a perfuração de poços de outras companhias com registro na CVM do setor de óleo e gás, como a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”), HRT Participações em Petróleo S.A. (“HRT”) e QGEP Participações S.A. (“QGEP”).

38. Com relação à Petrobras, somente um Fato Relevante teria sido encontrado acerca da divulgação de estimativas desde 2009. A divulgação de 29.10.2010 faria esclarecimentos a respeito de uma notícia de que a reserva de Sergipe teria dezenas de milhões de barris de óleo equivalente (fls. 524).

39. No sentir da área técnica, a Petrobras divulgaria as suas descobertas apenas ao final da perfuração do referido poço, acompanhado do resultado do respectivo teste de formação (fls. 524-568) e, ainda assim, por meio de comunicados não considerados relevantes ao mercado.

40. Neste sentido, aponta que, desde 2012, a Petrobras teria divulgado aproximadamente 45 comunicados ao mercado que informariam a conclusão da perfuração de um ou mais poços petrolíferos sendo que, em nenhuma das citadas divulgações, a Petrobras forneceria informações acerca de estimativas de volume de óleo recuperável durante a perfuração dos poços¹⁵.

41. Do mesmo modo, estimativas de volume de óleo recuperável não teriam sido divulgadas em nenhum dos oito (fls. 569-579) fatos relevantes divulgados pela HRT entre 16.09.2011 e 19.07.2013 acerca da perfuração de poços exploratórios. De 27.04.2012 a 20.05.2013, a HRT teria divulgado seis (fls. 580-586) comunicados ao mercado que informariam a conclusão de uma perfuração e/ou descoberta de hidrocarbonetos. Em nenhuma dessas divulgações teriam sido divulgadas estimativas de volume de óleo recuperável.

42. Também não teriam sido divulgadas estimativas de volume de óleo recuperável em nenhum dos cinco (fls. 587-591) fatos relevantes divulgados pela QGEP entre 14.03.2011 e 13.08.2012 acerca da perfuração de poços exploratórios.

43. Após as diligências junto (i) à Companhia, (ii) à ANP, e (iii) a divulgações de outras companhias do setor de óleo e gás, teria restado claro, no sentir da SEP, que a divulgação de estimativa de volume de óleo recuperável durante a perfuração de um poço não seria prática comum entre as empresas abertas do setor de óleo e gás, tampouco seria considerada adequada pela ANP.

II.2.6 TEOR DAS DECLARAÇÕES

44. Pondera a área técnica que, rotineiramente, a CVM deixaria a avaliação das informações a serem divulgadas ao mercado a cargo dos administradores de companhias abertas, pois, em tese, possuiriam amplo conhecimento do que pode ou não pode ser divulgado.

¹⁵ A única estimativa de volume de óleo recuperável encontrada foi informada em 24.05.2012, após a conclusão da perfuração do poço 1-REPF-12D-RJS e durante a preparação do plano de avaliação para apresentação à ANP.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

45. Diante das características do caso concreto, principalmente (i) a divulgação do fato relevante de 01.07.2013, (ii) as negociações de administradores com ações de emissão da OGX e (iii) a mecânica de remuneração através de plano particular de opções de compra de ações entre os beneficiários e o acionista controlador, a SEP entendeu que haveria justa causa para analisar o juízo de valor realizado pelos administradores da Companhia.

46. Neste passo, a SEP destacou que, em 38 dos 54 fatos relevantes sob exame, Paulo Mendonça fez comentários¹⁶ pessoais a respeito das descobertas, os quais estão parcialmente reproduzidos a seguir (fls. 2162-2165) [grifos do original]:

- i) em 02.10.2009: “essa evidência na bacia mais promissora do Brasil representa **uma importante conquista para a OGX**”;
- ii) em 07.10.2009: “OGX-1 representa o começo de uma campanha exploratória **altamente promissora**”;
- iii) em 12.11.2009: “a perfuração segue em andamento e **continuamos otimistas com o potencial dos objetivos mais profundos**”;
- iv) em 30.11.2009: “a identificação de uma expressiva coluna com hidrocarbonetos em reservatórios de alta qualidade na seção do Albiano **superou nossas expectativas**”;
- v) em 28.12.2009: “vem apresentando todos os elementos para converter-se em **um importante polo produtor de petróleo**”;
- vi) em 05.03.2010: “a província recentemente descoberta se estende também até o norte do bloco BM-C-41, ratificando o seu **importantíssimo potencial petrolífero**”;
- vii) em 12.04.2010: “[o poço] vem confirmar o **grande potencial** desta bacia em diversas idades geológicas, abrindo, portanto, uma **expressiva frente de novas possibilidades para estes reservatórios**”;
- viii) em 15.07.2010: “**a dimensão das descobertas** realizadas neste poço reforça a importância de nossos blocos localizados mais ao norte na Bacia de Campos. Este resultado é **tão positivo** que novas perfurações nesta área se tornaram prioritárias”;
- ix) em 20.07.2010: “isso ratifica o **importantíssimo potencial petrolífero da região**”;
- x) em 11.08.2010: “o que sinaliza para uma coluna **potencialmente superior** à já encontrada neste bloco. Esse resultado **reforça a atratividade desta região** mais ao norte da bacia de Campos, que pode representar **uma nova província de grande importância para a nossa Companhia**”;
- xi) em 12.08.2010: “esta descoberta **abre uma nova fronteira exploratória** em uma bacia terrestre, fato que não ocorria há aproximadamente duas décadas no Brasil”;
- xii) em 20.09.2010: “o poço OGX-20 marca um ano do início de nossa campanha exploratória, **com taxa de sucesso sem precedentes**”;

¹⁶ A SEP desprezou as declarações dos demais administradores, tendo em vista que elas representavam menos de 10% da totalidade das declarações constantes de fatos relevantes sobre a descoberta de hidrocarbonetos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- xiii) em 17.11.2010: “[a perfuração] confirma a **presença de uma província petrolífera** na região e **ressalta o potencial dos nossos blocos**”;
- xiv) em 24.11.2010: “estas novas informações reforçam a **perspectiva do enorme potencial da região**”;
- xv) em 01.03.2011: “o resultado do OGX-31 **eleva nossas expectativas** em relação à província albiana”;
- xvi) em 20.04.2011: “os poços OGX-40 e OGX-41 confirmam a **bem sucedida campanha delimitatória da OGX**”;
- xvii) em 16.01.2012: “essa descoberta é **importante** pela grande coluna e net pay identificados na seção albiana, assim como pela **qualidade do reservatório aptiano e seu comportamento**”;
- xviii) em 01.02.2012: “a confirmação destes reservatórios do pré-sal em águas rasas da bacia de Santos, pela equipe da OGX, **representa um marco** para a indústria e reforça o **enorme potencial** das bacias sedimentares brasileiras”;
- e
- xix) em 26.04.2012: “essa descoberta demonstra o atual estágio de maturidade da OGX, com **resultados excepcionais** ocorrendo em paralelo nas áreas de Exploração e de Produção da Companhia”.

47. Segundo a área técnica, teriam sido cerca de 30 mensagens de Paulo Mendonça com tom otimista, ressaltando tão-somente o potencial positivo das descobertas de hidrocarbonetos, sem informar, em momento algum, os eventuais desafios da Companhia até que a descoberta se tornasse, de fato, algo relevante para a OGX. Em relação ao tom dos comentários, a área técnica lembrou recomendação contida no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/GEA-3/Nº01/2014:

As informações objeto de divulgação deverão estar expressas em linguagem clara e objetiva, devendo ser verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro (...) a companhia deve eximir-se de emitir juízo de valor, sobretudo no que diz respeito ao andamento de disputas judiciais e decisões nelas proferidas, as quais devem refletir o exato teor de tais decisões¹⁷.

48. Acrescenta que o artigo 14 da Instrução nº 480/09 estabelece ser obrigação do emissor “divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”.

49. Sobre os comentários de Paulo Mendonça divulgados nos fatos relevantes, a SEP consigna a existência de um tom otimista (fls. 2162-2165), ressaltando o potencial positivo das descobertas de hidrocarbonetos, sem informar, em momento algum, os eventuais desafios da Companhia até que a descoberta de hidrocarbonetos se tornasse, de fato, algo relevante. Ao emitir seu juízo acerca do potencial de cada descoberta de hidrocarbonetos, o diretor da Companhia teria, no mínimo, corrido o risco de **induzir investidores a erro**, indo de encontro ao estabelecido pela citada instrução.

¹⁷ Ainda que se argumentasse que o Ofício Circular é de data posterior às divulgações da OGX, a informação já constaria do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2007, divulgado pela SEP em 2007.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

50. Quanto à isso, Paulo Mendonça alegou (fls. 1388-1393) que (i) as informações seriam sempre respaldadas por relatórios de terceiros independentes e (ii) as divulgações acompanhadas de mencionado aviso legal informando os riscos.

51. Para a SEP, não seria razoável um administrador de companhia aberta divulgar informação de forma inadequada e posteriormente alegar que a referida divulgação continha um aviso no rodapé informando que as suas afirmações estariam sujeitas a riscos, incertezas e premissas. Além disso, a área técnica registra que a forma otimista de suas declarações não teria encontrado amparo em nenhum dos relatórios técnicos que compõem as mais de seis mil folhas dos autos do processo.

52. Instado, Marcelo Torres arguiu que (fls. 1382-1384) os fatos relevantes sempre teriam refletido a visão da Companhia à época de sua divulgação, visão que seria lastreada em dados técnicos certificados por empresa independente, ressaltando que a OGX teria tomado a iniciativa de contratar a DeGolyer & MacNaughton em diversas oportunidades para ratificar as estimativas.

53. Segundo José Cavalcanti e Eike Batista (fls. 1418-1425; 1432-1445), sendo os dados constantes dos fatos relevantes vindos de profissionais técnicos responsáveis pelas atividades, nenhum dos dois teria capacidade de opinar a respeito da qualidade das informações técnicas.

54. Por fim, Reinaldo Vargas (fls. 1477-1478) alegou que as conclusões contidas nos fatos relevantes seriam da diretoria de exploração, enquanto que a decisão acerca da “forma de divulgação, ‘se’ e ‘como’ fazê-la, seria tomada pelas diretorias de exploração e de relações com investidores”.

55. Para a SEP, não seria possível acatar tais argumentos porque, a princípio, não seria necessário conhecimento técnico para identificar a linguagem otimista e exagerada contida nas divulgações. Dessa forma, concluiu, pois, que várias divulgações teriam apresentado conteúdo inadequado com condão de induzir investidores a erro.

II.3 PLANO DE OPÇÕES

56. Após a divulgação de notícias no início de agosto de 2013 acerca do plano de opções disponibilizado aos funcionários da OGX (fls. 1718), a SEP iniciou seus questionamentos (fls. 1497-1499) sobre o assunto.

57. Eike Batista (fls. 1668-1675) teria confirmado a outorga de opções de compra de ações da Companhia por meio de contratos particulares (fls. 1676-1710; 1722-1770) entre ele e os seus beneficiários, incluindo os diretores estatutários da OGX. Segundo esses contratos, não poderia haver alienação de ações até, no mínimo, 26.11.2011.

58. Posteriormente, teriam sido celebrados dois aditivos que diminuiriam as quantidades de ações outorgadas, estenderiam o prazo de exercício para até sete anos e também permitiriam a alienação imediata de até metade das ações exercidas por cada beneficiário.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

59. Entre 2009 e 2012, Eike Batista teria realizado, por meio do veículo de investimento Centennial Asset Mining Fund LLC (“CAMF”), transferências privadas (fls. 1676 – 1710; 2141-2152) de ações aos referidos beneficiários para cumprir o plano de opções. No total, Eike Batista teria transferido a seguinte quantidade, já ajustada pelo desdobramento ocorrido em 2009, de ações aos seguintes diretores:

Diretor	Ações Transferidas
Marcelo Torres	11.081.700
Paulo Mendonça	11.081.700
Reinaldo Vargas	1.886.700
José Cavalcanti	868.300
TOTAL	24.918.400

II.3.1 AVALIAÇÃO DA SEP

60. A SEP concluiu que, dependendo da cotação das ações da Companhia, a maior parte da remuneração desses diretores seria proveniente do citado plano de opções pessoal do acionista controlador. Com o objetivo de compreender melhor a dimensão da remuneração, considerou importante traçar um histórico das cotações das ações da OGX e das remunerações dos administradores aprovadas em assembleia geral ordinária (“AGO”).

61. Adotando um critério conservador, a SEP considerou, com base na cotação das ações entre 08.09.2009 e 06.02.2012, que a remuneração aproximada baseada em ações dos diretores teria variado de R\$ 8,5 milhões até R\$ 110 milhões no período de três anos.

62. Quanto à remuneração aprovada nas AGOs de 2009 a 2011, a remuneração total para a diretoria teria sido de aproximadamente R\$ 20 milhões (fls. 1772-1779). Dividindo-se essa remuneração por cinco diretores, chegar-se-ia à remuneração média de R\$ 4 milhões por diretor.

63. O percentual da remuneração dos diretores¹⁸ com opções sobre ações da OGX seria, portanto, no mínimo, o dobro do percentual da remuneração fixada em assembleias gerais ordinárias (fls. 1772-1779). No caso de Paulo Mendonça e Marcelo Torres, a SEP estimou que a remuneração com ações seria próxima de 30 vezes a remuneração fixada em assembleia.

64. Diante disso, a SEP concluiu que os diretores da OGX teriam interesse financeiro nas divulgações, haja vista que elevadas cotações significariam (i) mais retorno financeiro com a venda de ações, (ii) a possibilidade de garantir futuras vendas de ações com preços elevados, ou (iii) uma elevação dos seus patrimônios em ações da Companhia, quando não pudessem ou desejassem vender as ações.

II.3.2 NEGOCIAÇÕES COM AÇÕES

¹⁸ Excluindo Eike Batista, que era o acionista controlador e não tinha remuneração por opções.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

65. A SEP identificou que, após as divulgações dos fatos relevantes, com conteúdo excessivamente otimista, Marcelo Torres, Paulo Mendonça e José Cavalcanti (fls. 343-344) teriam dado início a uma sequência de alienações por seis pregões que totalizariam um montante de mais de R\$16 milhões.

66. Indagado (fls. 1382-1384), Marcelo Torres alegou que as alienações teriam sido realizadas (i) de acordo com a Política, (ii) de acordo com as regras do Contrato, (iii) em momentos que não detinha informação relevante, (iv) em períodos não vedados, e (v) sempre com anuência do acionista controlador.

67. Paulo Mendonça, por sua vez, afirmou (fls. 1388-1409) que teria alienado 1.321.000 ações no período de 02.10.2009 a 26.04.2012 respeitando os ditames legais e a Política, sendo que ainda deteria aproximadamente 8 milhões de ações da OGX.

68. José Cavalcanti informou (fls. 1418-1425) que (i) teria a necessidade de vender uma parte das ações para custear gastos pessoais, tendo em vista que o Contrato representaria uma parte relevante da sua remuneração; (ii) não teria alienado ações com o conhecimento de qualquer informação ou Fato Relevante ainda não divulgado ao mercado; e (iii) sempre teria vendido uma pequena parcela das ações que detinha, permanecendo com o resto em carteira.

69. A SEP não encontrou indícios de que os referidos administradores tenham realizado as mencionadas negociações na posse de informações privilegiadas. Por outro lado, a SEP concluiu que:

em essência, a união dos fatos obtidos por meio das diligências desta Superintendência após a divulgação de 01.07.2013 – quais sejam: (i) a OGX divulgar mais de 50 fatos relevantes cujo conteúdo não era relevante para a Companhia, (ii) administradores emitirem declarações otimistas com o potencial de induzir o mercado em geral a erro, (iii) o incentivo financeiro desses administradores em elevar ou manter elevadas as cotações das ações, e (iv) os administradores, enquanto declaram otimismo ao mercado também alienam parte de suas ações – representa, na verdade, prática de manipulação de preços no mercado de valores mobiliários¹⁹.

70. Ressaltou que se faria necessário o exame do comportamento dos administradores da OGX em dois grupos. No primeiro estariam Marcelo Torres e Paulo Mendonça, diretores das áreas diretamente ligadas às divulgações²⁰, que teriam alienado conjuntamente quase R\$ 45 milhões em ações da Companhia durante a prática descrita, razão pela qual poderia se concluir que são os administradores diretamente responsáveis pela manipulação dos preços da OGX.

¹⁹ Vedada pelo inciso I da Instrução CVM nº 08/79 e definida pelo inciso II dessa Instrução como a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda.

²⁰ Marcelo Torres como DRI, pessoa responsável pela divulgação dos fatos relevantes, nos termos do art. 3º da Instrução CVM nº 358/02 e Paulo Mendonça como diretor de exploração da Companhia, responsável pela área que comunicava o DRI sobre as descobertas de hidrocarbonetos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

71. Noutro grupo estariam Eike Batista, Reinaldo Vargas e José Cavalcanti que (i) teriam se beneficiado pouco ou nada da citada prática, (ii) não trabalhariam em áreas diretamente ligadas às divulgações, e (iii) estariam de acordo com o teor das divulgações. Para a SEP, os membros deste segundo grupo, ao manifestarem-se a favor da divulgação dos fatos relevantes, ainda que não estivessem diretamente envolvidos com as descobertas de hidrocarbonetos e não tivessem conhecimento suficiente sobre elas, teriam agido sem a diligência requerida pelo art. 153 da Lei nº 6.404/76²¹.

II.3 FATO RELEVANTE DIVULGADO EM 13.03.2013

72. Destaca a SEP que o fato relevante de 13.03.2013 teria informado a declaração de comercialidade das acumulações Pipeline, Fuji e Illimani. Estas teriam dado lugar aos campos Tubarão Areia, Tubarão Tigre e Tubarão Gato (fls. 55), cujas estimativas de volume de óleo *in place* para cada campo foram atualizadas naquele momento. Diante disso, a área técnica examinou as divulgações anteriores relacionadas aos referidos campos, a seguir resumidas.

II.3.1 PIPELINE

73. Segundo apurado pela área técnica, a primeira divulgação da Companhia acerca do andamento da perfuração do poço 1-OGX-2-RJS (“OGX-2”) teria sido realizada em 12.11.2009, quando a detecção de indícios de hidrocarbonetos durante sua perfuração (fls. 44-45) teria sido informada por meio de fato relevante.

74. Em 16.11.2009, teria sido divulgado novo fato relevante acerca do OGX-2, que teria informado (i) a descoberta de óleo, e (ii) que o volume estimado de óleo recuperável nesses reservatórios seria de “400 a 500 milhões de barris” (fls. 46).

75. Em 22.12.2009, teria sido divulgado o sexto Fato Relevante referente ao OGX-2 que teria estimado um volume total de óleo recuperável para todos os reservatórios (referentes às diferentes profundidades do poço) entre um e dois bilhões de barris. Os testes realizados também teriam revelado a presença de reservatórios carbonáticos de alta qualidade (fls. 50).

76. Em 22.03.2011 e 20.04.2011, teriam sido divulgadas presenças de hidrocarbonetos nas perfurações dos poços OGX-36D e OGX-41D, poços delimitatórios da acumulação de Pipeline, descoberta na perfuração do poço OGX-2 (fls. 52-53).

77. Em 15.07.2011, no que se refere ao poço OGX-39HP – poço Pipeline horizontal²² –, a Companhia teria divulgado (i) a conclusão da perfuração do referido poço, (ii) o resultado de teste de formação neste poço, que indicou capacidade de produção de 10.000 barris por dia de óleo, e (iii) a identificação de muito boas condições de reservatório (fls. 54).

²¹ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

²² Seria prática comum a perfuração de poços horizontais para maximizar a vazão de extração de óleo e gás.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

78. Em 13.03.2013, a OGX teria declarado a comercialidade das referidas acumulações, informando que Pipeline havia sido dividida entre os campos Tubarão Tigre e Tubarão Gato, com as seguintes estimativas de volumes (fls. 55):

	Volume in place ²³ total estimado (mmboe ²⁴)		
	P90**	P50 ²⁵	P10**
Tubarão Tigre	314	461	675
Tubarão Gato	50	71	101
Total (Pipeline)	364	532	776

II.3.2 FUJI E ILLIMANI

79. Na mesma linha, a SEP destacou que, em 24 e 31.03.2010 teria sido divulgada a presença de hidrocarbonetos na perfuração do OGX-8, cuja acumulação foi denominada Fuji (fls. 57-58).

80. Em 15.05.2010, teria sido informada (i) a conclusão da perfuração do OGX-8 e (ii) a necessidade de novos dados e estudos para verificar se estariam diante de uma mesma acumulação no que se refere à conectividade entre os poços OGX-3 e OGX-8 (fls. 51).

81. A única divulgação da Companhia acerca do poço 1-OGX-28D-RJS de acumulação denominada Illimani teria sido realizada em 24.01.2011 e teria identificado a presença de hidrocarbonetos nesta localidade (fls. 59).

82. Em 13.03.2013, a OGX declarou a comercialidade das acumulações Pipeline, Fuji e Illimani, informando que as acumulações de Fuji e Illimani receberam, conjuntamente, o nome de campo de Tubarão Areia, com as seguintes estimativas de volumes (fls. 55):

	Volume in place total estimado (mmboe)		
	P90	P50	P10
Tubarão Areia	157	291	563

II.3.3 ESTUDOS E MATERIAIS DE POSSE DA COMPANHIA

83. Segundo a SEP, desde 2011 a OGX já teria analisado as áreas dos Campos e concluído preliminarmente que a exploração das áreas seria mais complicada do que o imaginado inicialmente pela Companhia.

84. Em julho de 2012, teria sido constituído grupo de trabalho (“GT”) para realizar (fls. 88) (i) busca de soluções mais baratas, tendo em vista a aparente inviabilidade econômica dos

²³ Volume in place corresponderia ao volume total de óleo encrustado em uma rocha-reservatório, enquanto que volume de óleo recuperável corresponderia apenas ao volume a ser extraído da rocha-reservatório.

²⁴ Milhões de barris de óleo equivalente.

²⁵ Percentual de certeza quanto à produção.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Campos de Tubarão Azul²⁶, Tubarão Tigre, Tubarão Areia e Tubarão Gato; e (ii) investigação da viabilidade do projeto da unidade WCPP²⁷, dados os aparentes riscos tecnológicos do projeto.

85. Quanto à WCPP, após contratação da empresa Rameshni & Associates Technology & Engineering, LLC (“RATE”) para validação e detalhamento da unidade, a conclusão (de fevereiro de 2013) teria sido a de que o projeto teria resultado em “*equipamentos de grandes dimensões e conseqüentemente elevados custos*”, sendo sugerido também que “*fossem avaliadas outras tecnologias buscando a viabilidade do projeto*” (fls. 97-100).

86. Já a apresentação do GT realizada em 24.09.2012 (fls. 101-109) conteria os seguintes pontos:

- a) participação da empresa terceirizada Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda. (“Schlumberger”) sob a forma de minuta sem conclusões técnicas e financeiras²⁸;
- b) estimativa de volume (i) in place dos Campos de 676 milhões de barris, e (ii) de óleo recuperável entre 49,4 e 77,8 milhões de barris;²⁹
- c) valor presente líquido³⁰ (VPL) negativo em qualquer dos cenários traçados (base ou otimista).

87. Seria provável, para a SEP, que as conclusões do relatório da Schlumberger, ainda que omitidas da minuta juntada aos autos do presente processo, tivessem servido de base para a apresentação do GT, principalmente no que se refere às novas estimativas de volumes para as áreas dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia.

88. Na sequência, em março de 2013, teria sido entregue à Companhia o reprocessamento da sísmica³¹ dos reservatórios localizados nestes quatro campos (os Campos mais Tubarão Azul), feito pela empresa CGG Brasil, com dados mais precisos sobre as características da área, para permitir à OGX uma melhor avaliação do modelo geológico, tendo em vista comportamentos distintos dos poços perfurados e concluídos para produção (fls. 246-266).

²⁶ Campo de exploração que não faz parte da investigação do presente processo.

²⁷ Unidade que tratava o gás contaminante H₂S (fls. 91-96).

²⁸ Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nº 682/13, de 07.10.2013 (fls. 115-245), a própria Schlumberger teria afirmado que “como após a entrega do referido documento (minuta) à OGX, esta considerou concluído o serviço requerido o documento se manteve em forma de minuta, não chegando a ser emitido um relatório final completo.”.

²⁹ A área do poço OGX-42D, mencionada na apresentação, foi somada à área da acumulação Pipeline/Etna, tendo em vista que, conforme o citado poço era delimitatório da área de Pipeline (comunicado ao mercado de 10.08.2011). A variação para a acumulação Pipeline/Etna estimada pela apresentação é explicada pela existência de cenários base e otimista para o fator de recuperação, sendo este fator um percentual do volume in place que pode ser extraído. A área do poço OGX-56D, mencionada na apresentação, foi somada à área da acumulação Fuji/Illimani, tendo em vista que, conforme o citado poço era delimitatório da área de Fuji (comunicado ao mercado de 10.08.2011).

³⁰ Subtraindo-se as despesas das receitas ao longo do tempo, e descontando o saldo do valor presente, obter-se-ia o valor presente líquido do projeto – VPL.

³¹ Método de prospecção geofísica que utiliza os princípios da sismologia para estimar as propriedades da subsuperfície da Terra com base na reflexão de ondas sísmicas frequentemente utilizado na prospecção de hidrocarbonetos e outros recursos minerais.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

89. De posse dos estudos (i) do reprocessamento sísmico (março/2013), (ii) do GT (setembro/2012), (iii) da Schlumberger (setembro/2012) e (iv) da RATE (fevereiro/2013); a área de reservatórios da Companhia teria realizado (fls. 293-307) um estudo final e apresentado à diretoria executiva em junho de 2013 que, por sua vez, o teria reapresentado na reunião do conselho de administração de 28.06.2013.

90. Acerca desse estudo final, a SEP destacou as seguintes partes:

- a) as primeiras análises da Área de Reservatórios, ainda em 2011, já sinalizariam “*volumes e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial*”, a partir do qual teria se decidido pela contratação de uma consultoria externa;
- b) a análise realizada pela Schlumberger teria confirmado o modelo concebido pela área de reservatórios, com um volume *in place* total de óleo na faixa de 700 milhões de barris;
- c) associada à redução do volume, teria havido uma redução significativa do fator de recuperação, inicialmente estimado em torno de 20%, para inferior a 10%”;
- d) o estudo da Schlumberger teria resultado num volume recuperável de cerca de 80 milhões de barris no caso mais otimista, com um fator de recuperação de 12%, e de 50 milhões de barris no caso mais provável, o que representaria uma recuperação de 7,3%; e
- e) além dos baixos volumes recuperáveis, o projeto contemplaria a perfuração de 12 poços horizontais, com produção coletada e processada numa unidade WCPP, o qual teria levado a um CAPEX de quatro bilhões de dólares e uma curva de produção com pico na faixa de 60.000 bpd, resultando num VPL negativo de mais de um bilhão de dólares;

Descoberta	Campo	Previsão Inicial			Previsão Final		
		Volume in place	FR	Volume Recuperável	Volume in place	FR	Volume Recuperável
Pipeline	Tigre	460,9	20,00%	92,2	314,5	10,30%	32,4
Pipeline (OGX-42D)	Gato	71,3	20,00%	14,3	50,3	15,00%	7,5
Fuji/Illimani	Areia	291	21,80%	63,4	162	13,50%	21,9
TOTAL		823,1	20,60%	169,9	526,8	11,70%	61,8

91. Com base nesse estudo, o conselho de administração da Companhia teria se reunido em 28.06.2013 e concluído que não existiria tecnologia capaz de tornar economicamente viável o desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia.

II.3.4 CONSIDERAÇÕES DA SEP



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

92. Diante das informações, a SEP concluiu que:
- a) a primeira e única estimativa de volume do campo de Tubarão Areia (acumulações Fuji/Illimani) teria sido divulgada em 13.03.2013, quando o volume *in place* teria variado de 157 a 563 milhões barris de óleo equivalente;
 - b) a estimativa de volume dos campos de Tubarão Tigre e Tubarão Gato (acumulação de Pipeline), teria variado de (i) 400 a 500 milhões de barris de óleo equivalente recuperáveis em 16.11.2009; (ii) 1 a 2 bilhões de barris de óleo equivalente recuperáveis em 22.12.2009; (iii) 1,4 a 2,6 bilhões de barris de óleo equivalente recuperáveis (incluindo a acumulação de Etna, que, desde então, não foi citada em estimativas da Companhia) em 13.05.2010; e (iv) 364 a 776 milhões de barris de óleo equivalente *in place* em 13.03.2013; e
 - c) ainda que os volumes estimados tivessem diminuído de 2009 até 2013, com a divulgação de 13.03.2013 teria ficado a expectativa de haver, pelo menos, entre 521 e 1.339 milhões de barris de óleo equivalente *in place* nos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Areia e Tubarão Gato.
93. A divulgação de 13.03.2013 teria trazido apenas dados de volume *in place*, sem mencionar o volume de óleo recuperável que, por sua vez, já seria informação disponível para a Companhia desde o resultado do GT, de 24.09.2012.
94. No relatório da área de reservatórios, a própria Companhia teria reconhecido que o fator de recuperação (percentual entre volume *in place* e volume de óleo recuperável) previsto inicialmente seria de 20%, enquanto que a Schlumberger o teria estimado em um percentual inferior a 10%. Em nenhuma divulgação, a Companhia teria mencionado o fator de recuperação esperado para as áreas dos Campos.
95. Em 21.09.2012 a OGX teria recebido informações da Schlumberger que diminuía muito (94%, no mínimo) as estimativas de volume de óleo recuperável até então divulgadas ao mercado em 13.05.2010³².
96. Além disso, em 13.03.2013, a Companhia, utilizando as análises da Schlumberger divulgadas pelo GT, teria divulgado apenas a estimativa de volume *in place*, omitindo a estimativa de volume de óleo recuperável e o VPL negativo do projeto.
97. Diante disso, a SEP concluiu que:
- Não é preciso análise tão profunda para que se chegue a conclusão de que os administradores tentaram realizar todos os estudos possíveis para divulgarem, com o maior nível de certeza possível, que os Campos eram

³² A divulgação de 13.05.2010 daria conta de que havia pelo menos 1,4 bilhões de barris de óleo recuperáveis na área dos Campos. A Schlumberger teria concluído, em 21.09.2012, que haveria, na verdade, algo entre 49,4 e 77,8 milhões de barris de óleo recuperáveis na mesma área, uma redução de, no mínimo, 94% sobre o valor até então divulgado ao mercado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

comercialmente inviáveis. No entanto, nota-se que foi realizada uma divulgação parcial, dado que foram informadas a declaração de comercialidade e uma estimativa com faixas prováveis de volumes de óleo *in situ* nos Campos. Causou estranheza a seleção de dados para a divulgação de fato relevante, sendo que os dados negativos, que ainda necessitavam de comprovação, foram omitidos do fato relevante, como o VPL e o fator de recuperação muito abaixo das expectativas. (...) Quando a OGX divulgou, por meio de fato relevante, a comercialidade das áreas, pode-se afirmar que a interpretação lógica de qualquer leitor – investidor ou não – é de que, segundo a Companhia, essas áreas eram comercialmente viáveis.

98. Para a área técnica, o VPL negativo apresentado pelo GT já demonstraria preliminarmente a inviabilidade econômica dos Campos, divulgada somente em 01.07.2013, de sorte que a divulgação de 13.03.2013 seria exatamente o oposto do entendimento do GT, reportado à diretoria da OGX em 24.09.2012. Os resultados trazidos pela Schlumberger e apresentados pelo GT teriam alterado radicalmente a situação até então divulgada ao mercado e significariam, ainda que preliminarmente, a inviabilidade econômica dos Campos, exatamente o oposto do divulgado em 13.03.2013.

99. Sobre tal questão, os diretores teriam afirmado (fls. 1410-1425; 1446-1489) que os referidos estudos seriam inconclusivos e que a Companhia possuiria alguns estudos positivos e outros negativos, sendo que em 13.03.2013 teriam sido informados apenas os dados conclusivos. Já Reinaldo Vargas declarou que “*acreditando na capacidade de alcançar meios que viabilizassem o desenvolvimento dessas áreas [Campos], a Companhia declarou a comercialidade das mesmas como forma de evitar a obrigatoriedade de devolvê-las à ANP sem antes ter a certeza de sua inviabilidade*” (fls. 1477-1478).

100. A SEP concluiu que, apesar de a Companhia ter realizado a declaração de comercialidade em razão da necessidade contratual para que não fosse obrigada a devolver à área à ANP, a divulgação de um aviso de fato relevante com referido conteúdo “*dá a entender que aquele(s) campo(s) é(são) economicamente viável(is)*”.

101. Prossegue a SEP afirmando que, se o intuito fosse o de não perder o bloco concedido pela ANP, não seria razoável tratar a comercialidade como informação relevante. E não haveria como essa informação ser relevante, notadamente porque, conforme informado pelos diretores, não havia certeza da comercialidade da área.

102. Por essas razões, no entender da área técnica, a divulgação de 13.03.2013 teria sido realizada de modo inadequado e prejudicial aos investidores da Companhia, que teriam acreditado que aqueles Campos eram economicamente viáveis desde então, tendo em vista que não houve nenhum informe da OGX de que a viabilidade econômica ainda estava sendo estudada.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

103. Como a divulgação de 13.03.2013 teria sido um ato isolado da diretoria da OGX à época, a SEP inferiu que não teria havido configuração de comportamento compatível com manipulação de preços, pelos motivos resumidos a seguir:

- a) em comparação com a prática utilizada de 2009 a 2012, os três novos diretores³³ da Companhia não possuiriam plano de opções diretamente outorgado pelo acionista controlador (fls. 1668-1675), de modo que o interesse econômico na divulgação de informações otimistas dos cinco diretores da Companhia em 13.03.2013 seria significativamente inferior ao interesse dos cinco diretores no período de 2009 a 2012, ainda que dois integrantes fossem comuns em ambas as formações da diretoria;
- b) os cinco diretores não teriam alienado ações entre a divulgação do Fato Relevante de 13.03.2013, que informou a comercialidade dos Campos, e a publicação de 01.07.2013, que comunicou a inviabilidade econômica dos mesmos Campos, de modo que não parece que os cinco diretores da OGX em 13.03.2013 tenham auferido vantagem econômica com a divulgação do omissa Fato Relevante nessa data;
- c) a Companhia não teria deixado claro ao mercado que a declaração de comercialidade era um artifício para não perder a concessão dos Campos – o que não justificaria, por si só, a divulgação de um fato omissa que eventualmente tenha induzido investidores a erro, porém auxiliaria na conclusão de que a conduta dos diretores, salvo melhor juízo, teria sido diferente de prática de manipulação de mercado.

III. DAS RESPONSABILIDADES

104. Diante de tudo o que se apurou, a SEP atribuiu responsabilidade para:

- a) **Paulo Manuel Mendes de Mendonça**, na qualidade de diretor da OGX eleito em 03.09.2007 (fls. 1711), por prática de manipulação de preços, definida pelo **inciso II, “b”**, e vedada pelo **inciso I**, ambos da **Instrução CVM nº 08/79**, por meio da divulgação inadequada de Fatos Relevantes no período de 2009 a 2012, enquanto alienava ações de emissão da Companhia;
- b) **Marcelo Faber Torres**, na qualidade de diretor da OGX eleito em 03.09.2007 (fls. 1711), por prática de manipulação de preços, definida pelo **inciso II, “b”**, e vedada pelo **inciso I**, ambos da **Instrução CVM nº 08/79**, por meio da divulgação inadequada de Fatos Relevantes no período de 2009 a 2012, enquanto alienava ações de emissão da Companhia;

³³ Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, Roberto Bernardes Monteiro e Paulo de Tarso Martins Guimarães.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- c) **José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti**, na qualidade de diretor da OGX eleito em 06.08.2008 (fls. 1712-1713), pelo descumprimento ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**, por não ter agido com cuidado e diligência ao manifestar concordância com a divulgação (i) inadequada de Fatos Relevantes no período de 2009 a 2012, e (ii) de Fato Relevante omissos em 13.03.2013, com o condão de levar investidores a erro;
- d) **Reinaldo José Belotti Vargas**, na qualidade de diretor da OGX eleito em 06.08.2008 (fls. 1712-1713), pelo descumprimento ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**, por não ter agido com cuidado e diligência ao manifestar concordância com a divulgação: (i) inadequada de Fatos Relevantes com conteúdo otimista e sem relevância no período de 2009 a 2012, e (ii) de Fato Relevante omissos em 13.03.2013, com o condão de levar investidores a erro;
- e) **Eike Fuhrken Batista**, na qualidade de diretor da OGX eleito em 22.04.2009 (fls. 1714-1715), pelo descumprimento ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**, por não ter agido com cuidado e diligência ao manifestar concordância com a divulgação inadequada de Fatos Relevantes no período de 2009 a 2012;
- f) **Roberto Bernardes Monteiro**, na qualidade de diretor da OGX eleito em 27.04.2012 (fls. 1716), pelo descumprimento ao **art. 14 da Instrução CVM nº 480/09**, pela divulgação de Fato Relevante omissos em 13.03.2013, com o condão de levar investidores a erro;
- g) **Luiz Eduardo Guimarães Carneiro**, na qualidade de diretor da OGX eleito em 28.06.2012 (fls. 1717), pelo descumprimento ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**, por não ter agido com cuidado e diligência ao manifestar concordância com a divulgação de Fato Relevante omissos em 13.03.2013, com o condão de levar investidores a erro; e
- h) **Paulo de Tarso Martins Guimarães**, na qualidade de diretor da OGX eleito em 29.08.2012 (fls. 2161), pelo descumprimento ao **art. 153 da Lei nº 6.404/76**, por não ter agido com cuidado e diligência ao manifestar concordância com a divulgação de Fato Relevante omissos em 13.03.2013, com o condão de levar investidores a erro.

IV. DO PARECER DA PFE

105. Em 17.07.2014, a Procuradoria Federal Especializada – PFE emitiu parecer (Parecer Nº 139/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGD/AGU – fls. 2221-2228) no qual entendeu, uma vez cumprido integralmente o disposto no artigo 11 da Deliberação CVM nº 358/2008, estar presente, em tese, a materialidade justificadora da imputação de responsabilidade atribuída aos acusados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

106. Ademais, em cumprimento ao disposto no artigo 10, parágrafo único, da Deliberação CVM nº 258/2008, vislumbrou-se a ocorrência de potencial violação ao disposto no art. 27-C da Lei 6.385, de 07 de dezembro de 1976, caracterizando-se indício de prática de crime de ação penal pública, razão pela qual deveria ser expedida comunicação ao Ministério Público Federal.

V. DAS DEFESAS

V.1 JOSÉ CAVALCANTI

107. Em defesa (fls. 2376-2466), José Cavalcanti alegou, inicialmente, que sua autoria imprudente ou negligente acerca dos fatos ocorridos no período de 02.10.2009 a 26.04.2012 não teria sido provada pela SEP. A Acusação teria apenas caracterizado o comportamento de todos aqueles a quem não imputou prática direta de irregularidade como coautoria pela divulgação das informações da OGX.

108. Além disso, como diretor jurídico e, por força das normas da CVM e das atribuições do estatuto social da Companhia, não caberia a ele a divulgação de fatos relevantes, sendo o DRI o único responsável por sua divulgação e avaliação. Outros administradores não poderiam interferir nessa atividade a menos que tivessem razões fortes para isso.

109. Ou seja, seus deveres de vigiar e investigar só poderiam ser considerados descumpridos quando o acusado fosse alertado por circunstâncias ou eventos que indicassem a real necessidade de dedicar mais atenção ao assunto (os chamados *red flags*).

110. Além disso, a atmosfera que envolvia a OGX durante o referido período seria a de um conjunto de fatos e circunstâncias que tornaria implausível supor que os fatos relevantes não sinalizavam avanços nas operações em direção a um sucesso empresarial.

111. Por exemplo, em março de 2011 e maio de 2012, a OGX lançou títulos de dívida (*bonds*) no mercado financeiro internacional, captando mais de US\$ 3,5 bilhões. Atuaram como *joint bookrunners* os bancos J.P. Morgan, HSBC, Credit Suisse e Itaú BBA. Conforme exigência dos bancos, a OGX foi analisada pelas agências Standard & Poor, Fitch e Moodys, ganhando classificação excepcional para seu crédito por todas elas.

112. Se as supostas irregularidades fossem razoavelmente perceptíveis por um diretor jurídico, a própria CVM – possuidora de conhecimento maior – teria tomado iniciativa de determinar a retificação das divulgações, como sua prerrogativa, sobretudo em face da quantidade delas comunicadas à Autarquia.

113. A interpretação sobre o que é fato relevante seria difícil. Porém, a regulamentação e a jurisprudência da CVM orientariam para que, na dúvida, o fato deveria ser tratado obrigatoriamente como relevante, haja vista o imperativo de conferir maior transparência aos negócios das companhias.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

114. Ademais, a análise dos referidos fatos relevantes tornaria inegável a afirmativa de que todos os eventos aos quais a Acusação se refere são relevantes, de acordo com a prática adotada pela Petrobras – único paradigma disponível para a OGX e padrão de companhia petrolífera aberta. No entanto, ao avaliar sua adequação, a SEP teria usado como exemplos outras companhias que não poderiam ser comparadas com a OGX.

115. Seria tendenciosa a afirmativa de que a divulgação teria sido feita de maneira inadequada e de que, posteriormente, a Companhia teria alegado a existência de “aviso no rodapé”. Na verdade, tratar-se-iam de declarações insertas nos mesmos documentos e nos mesmos formatos.

116. Além disso, a SEP teria atribuído ao título “fato relevante” uma importância exagerada quando o que de fato importaria para os investidores seria a informação transmitida, na medida em que a existência de descoberta teria o mesmo efeito no mercado se divulgada como “comunicado”.

117. Ocorrendo a declaração de comercialidade, a publicação de fato relevante constituiria praticamente uma inexigibilidade de conduta diversa. No caso concreto, não se poderia contestar que se tratava de informação relevante para os investidores que, ademais, chegaria inevitavelmente ao mercado, uma vez que a ANP a disponibilizaria em seu site.

118. A análise de viabilidade econômica de um campo seria um estudo mais aprofundado do que o que ocorre antes da declaração. Tal análise conferiria ao concessionário uma nova oportunidade para decidir se deveria ou não realizar os investimentos necessários para o desenvolvimento do campo. Por isso, ele teria um prazo adicional de seis meses.

119. Da mesma maneira, não poderia vingar a imputação de que existia uma “omissão” no conteúdo desses fatos relevantes porque não teria sido informada estimativa de volume de óleo recuperável a esses Campos. Essa informação não teria sido incluída porque seria exatamente isso o que a Companhia estaria tentando calcular quando declarou a comercialidade.

120. Assim que assumiu a presidência da Companhia, em meados de junho de 2012, Luiz Carneiro alterou a organização da OGX, transferindo a área de reservatórios, que se reportaria anteriormente ao diretor de exploração, para a própria presidência.

121. Ele teria solicitado, então, uma avaliação criteriosa dos ativos da Companhia, que redundaram no Relatório “Valoração dos Ativos Bacias de Campos e Parnaíba” (fls. 2514-2530) de julho de 2012. O Relatório questionou alguns dados técnicos considerados nos estudos de viabilidade econômica dos projetos de produção da OGX.

122. Depois disso, o novo diretor presidente teria convocado a diretoria para dar ciência do resultado do Relatório, recomendando a criação de um grupo de trabalho (“GT”) com o objetivo de “Avaliar a Oportunidade de Desenvolvimento da Produção das Acumulações de Pipeline, Fuji, Illimani e Osorno” (fls. 101).

123. O GT teria contado com a participação de profissionais de diversas áreas da OGX, além de componentes da Schlumberger. Ao contrário do que consta na Acusação, porém, não teria havido “estudo da Schlumberger que consta de uma minuta sem as conclusões técnicas e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

financeiras” (fls. 2210), mas sim a contratação de especialistas em reservatórios que, em conjunto com técnicos da OGX, aprofundariam o conhecimento sobre o potencial de produção.

124. Em 24.09.2012, o GT apresentou à diretoria o resultado de suas análises com um volume de óleo *in place* bem menor do que aquele que era então considerado correto, principalmente pela área de exploração da Companhia. O GT teria aconselhado, então, uma série de providências a serem tomadas, antes de garantir os números apresentados.

125. Além daquelas providências sugeridas pelo GT, também estariam sendo reprocessados os mapas sísmicos das áreas de Pipeline, Fuji, Illimani e Osorno com o objetivo principal de compreender melhor a estruturação das acumulações destas áreas.

126. Paralelamente, a Companhia teria um prazo até 11.03.2013 para se posicionar diante da ANP em relação às acumulações Pipeline, Fuji e Illimani. Contudo, não haveria tempo hábil para a OGX estudar em que grau a baixa produtividade obtida no poço TBAZ-1, do Campo de Tubarão Azul, afetava o desenvolvimento dos demais Campos (fls. 69).

127. Quanto a isso, o artigo 157, §5º, da Lei nº 6.404/76³⁴ reconhece que, em certas situações, os administradores das companhias podem legitimamente optar por não divulgar informação. A divulgação relativa à existência de estudos e negociações sobre a tomada de decisões relevantes antes que estas se tornem definitivas pode contrariar interesse da sociedade.

128. Assim que foram terminados os estudos e se chegou à conclusão definitiva sobre a inviabilidade econômica no desenvolvimento dos campos, a administração da companhia não teria hesitado em divulgar fatos relevantes contendo resultados finais.

129. Logo, seria forçada a alegação da SEP de que, desde 2011, a OGX teria analisado as áreas dos Campos e concluído preliminarmente que os volumes e a compartimentação seriam muito diferentes da interpretação inicial. Na verdade, (i) seria a área de reservatórios e não a OGX que entenderia que a compartimentação seria um complicador adicional; e (ii) se isso fosse verdade, não seria a exploração mais complicada do que imaginado e sim a exploração³⁵ dos Campos.

V.2 LUIZ CARNEIRO E PAULO GUIMARÃES

130. Luiz Carneiro e Paulo Guimarães apresentaram defesa (fls. 2467-2538) conjunta, na qual alegaram, inicialmente, que seria necessário analisar o contexto da época em que ambos tomaram posse (28.06.2012 e 29.08.2012, respectivamente), ressaltando, mais adiante no

³⁴ Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. § 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.

³⁵ Termo técnico usado para se referir à retirada, extração ou obtenção de recursos naturais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

documento, que a ausência de individualização de responsabilidade violaria o ordenamento jurídico ao promover responsabilização objetiva.

131. Também reiteraram a posição de José Cavalcanti de que o *workshop* de maio de 2012 teria apresentado resultado preliminar positivo em relação aos campos de Pipeline, Illimani e Osorno, suscitando dúvidas entre os técnicos especializados em reservatórios e em exploração quanto ao volume de óleo recuperável.

132. Assim como o acusado anterior, ambos afirmaram que, ao final de junho, quando Luiz Carneiro assumiu o cargo de diretor presidente, ele teria transferido a área de reservatórios para a própria presidência da Companhia e que a primeira tarefa do novo gerente executivo de reservatórios teria sido a avaliação de alguns *assets* da OGX, o que teria gerado o Relatório (fls. 2513-2530) de 07.12. Luiz Carneiro teria então convocado a diretoria e dado ciência do resultado de relatório a todos os diretores, recomendando a criação do mencionado GT.

133. Na mesma linha, para eles, não teria havido, como diz a Acusação, “estudo da Schlumberger”, mas sim contratação de especialistas em reservatórios que, em conjunto com técnicos da OGX, teriam aprofundado o conhecimento sobre o potencial de produção do reservatório. O grupo teria apresentado à diretoria o resultado com um volume *in place* bem menor do que era tido como correto até então e sugerido providências para que se garantisse que os números fossem definitivos.

134. A decisão da OGX de declarar a comercialidade dos campos teria o objetivo de reter as acumulações que estavam sob a concessão da Companhia para que áreas não fossem devolvidas. Tal informação chegaria ao mercado de qualquer forma, uma vez que a ANP a disponibilizaria em seu site. Com data limite para a Companhia se posicionar, não teria sido possível determinar em que grau a baixa produtividade obtida no poço do campo de Tubarão Azul afetava o desenvolvimento econômico dos demais.

135. Ademais, seria comum na indústria de óleo e gás esse procedimento de retenção da área por meio de uma declaração para posterior busca de soluções que viabilizem os projetos até a elaboração do plano de desenvolvimento. A análise de viabilidade econômica, por outro lado, seria um estudo muito mais aprofundado, o qual permitiria a decisão pelo concessionário sobre a entrada ou não na fase de produção.

136. A própria SEP já teria constatado (fls. 2212) que os dados negativos apresentados pelo GT precisariam de comprovação. No período da declaração, a intenção da Companhia seria a de continuar seus estudos sobre as possibilidades de recuperação do óleo *in place*, buscando tecnologia capaz de viabilizar economicamente a produção nos campos.

137. Igualmente mencionaram o artigo 157, § 5º da Lei 6.404/76, que admite o sigilo por parte dos administradores de companhias abertas, em situações excepcionais, sobre determinada informação potencialmente relevante, caso entendam que a sua revelação pode prejudicar interesse legítimo da companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

138. Ao contrário da interpretação da Acusação, em 2011, a OGX estaria no meio das atividades de avaliação exploratória e prova disso seria que ainda estavam sendo realizados poços exploratórios no primeiro semestre de 2012. O que a Acusação teria apontado como “primeiras análises da Área de Reservatórios” seriam questionamentos iniciais levantados internamente e submetidos à gerência executiva de reservatórios.

139. Quanto ao fato relevante de 13.03.2013, a realidade da Companhia seria ditada pelo cumprimento de um prazo contratual com a ANP. Como os resultados até então seriam inconclusivos, a OGX teria preferido não desistir do projeto.

140. Quando os acusados passaram a integrar a diretoria da Companhia, já haveria uma discussão interna sobre o volume de óleo recuperável nos campos. Em vista disso, Luiz Carneiro e Paulo Guimarães, juntamente com os demais diretores em exercício, teriam decidido que, para a tomada de qualquer deliberação a respeito da exploração e produção dos campos, seria necessária a realização de estudos sobre a sua real viabilidade econômica.

141. Os dois acusados, juntamente com os demais diretores, ao identificarem as divergências internas entre a área de exploração e a de reservatórios e o risco dos campos no tocante à sua inviabilidade técnica e econômica, teriam solicitado diversos estudos para poderem optar de forma consciente por um plano de desenvolvimento ou devolver as acumulações à ANP.

142. Por fim, apontaram que o tratamento dado aos fatos relevantes já teria sido realizado pela OGX em outras oportunidades (17.05.2011, 25.04.2012 e 14.05.2012), como também pela Petrobras. Em 29.12.2006 (fls. 2535) a referida companhia divulgou ao mercado que havia encaminhado à ANP declarações de comercialidade de 19 novas áreas. Posteriormente, esses campos teriam sido devolvidos por se concluir que não seriam economicamente viáveis.

V.3 REINALDO VARGAS

143. Reinaldo Vargas apresentou defesa (fls. 2539-2664) na qual alegou, inicialmente, a necessária delimitação de competência, já que, na condição de diretor de produção, suas atividades nada diriam respeito à comunicação com o mercado.

144. Em linha com sua manifestação prévia, o acusado alegou que os fatos relevantes relativos à descoberta de óleo seriam elaborados pela diretoria de exploração (fls. 1477), responsável pelas atividades de exploração e reservatórios e revisados pela diretoria de relações com investidores, mas não dependeriam de aprovação dos demais membros da Companhia.

145. Uma vez preparada pela área técnica e refletida pela área de relações com investidores, a minuta de fato relevante seria circulada por e-mail para os diretores, a fim de que o administrador responsável pela área que elaborou o conteúdo técnico aprovasse as informações. O conteúdo em si exigiria grande conhecimento técnico, de modo que um diretor que não o tivesse nada poderia agregar na revisão ou análise de documento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

146. Inclusive, o único fato relevante que teria contado com a manifestação do acusado seria o de 20.04.2011, no qual não haveria qualquer afirmação sobre a estimativa de óleo recuperável, nem o retorno esperado, apenas a informação de que as acumulações teriam prioridade no desenvolvimento para a produção.

147. A acusação de que o acusado não teria agido com cuidado e diligência ao manifestar concordância com as divulgações seria genérica e levaria à anulação do Termo de Acusação porque não comprovaria a participação efetiva do acusado nas práticas irregulares ou consideraria a responsabilidade dele de forma objetiva, o que não é aceitável à luz da legislação.

148. Seria inadmissível que a denúncia não relacionasse a ação ou omissão cometida com o resultado danoso ou qualquer outro elemento indiciário de culpabilidade demonstrando nexo de causalidade. Quanto a isso, a própria CVM já se manifestou:

“Não (cabe) responsabilizar os administradores (...) uma vez que não ficou demonstrado o responsável direto pela suposta infração. O Direito Brasileiro rejeita a culpa objetiva. Só se pode punir o administrador individualmente quando ficar comprovado cabalmente a sua responsabilidade pelo ato ilegal”³⁶

149. Além disso, com as modificações³⁷ na administração da Companhia, seria possível constatar a relevância e influência do DRI na condução da Política de Divulgação, visto que, com a substituição do antigo diretor por Roberto Monteiro, apesar de os demais membros permanecerem, teria havido alteração na divulgação de fatos relevante ou comunicados.

150. Quanto às informações divulgadas entre 02.10.2009 e 26.04.2012, Reinaldo Vargas alegou que, até o primeiro trimestre de 2012, a OGX seria uma companhia pré-operacional, de modo que sua precificação pelo mercado seria baseada em estimativas. Todos os fatos relacionados à campanha exploratória seriam considerados pelos investidores como importantes para tais estimativas, uma vez que seriam dados disponíveis da Companhia.

151. Os técnicos da área de exploração e reservatórios sempre teriam defendido, em razão das tecnologias existentes à época dos fatos, ser possível estimar o volume de óleo recuperável a partir dos dados obtidos por meio de um único poço exploratório, sendo que a aquisição de dados do poço utilizaria serviços e equipamento de alta tecnologia.

152. A Petrobras, inclusive, por diversas vezes, teria divulgado fatos relevantes com estimativas de volume de óleo recuperável e/ou linguagem bastante otimista a partir dos dados obtidos com apenas um poço exploratório (fls. 2597-2607).

153. No caso da OGX, essas estimativas teriam sido apresentadas para vários analistas de bancos de investimento cujos relatórios teriam sido positivos e igualmente otimistas. A DeGolyer

³⁶ Inquérito Administrativo nº 01/79, julgado em 29.07.1979.

³⁷ Quando Paulo Mendonça passou a ocupar o cargo de diretor presidente, Roberto Monteiro substituiu Marcelo Torres como diretor financeiro e DRI e Paulo Santos, até então gerente executivo de exploração, foi incorporado à diretoria de exploração e reservatórios.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

& MacNaughton, por exemplo, realizou em novembro de 2009 e abril de 2011 a avaliação dos recursos da OGX e os resultados indicaram importantes volumes de óleo recuperável.

154. A Companhia também realizou importantes captações de dívida no mercado internacional, lideradas pelo banco J.P. Morgan. Tais operações seriam sempre precedidas de uma análise por parte do banco coordenador e por parte dos investidores.

155. Por fim, ao longo do período entre 2009 e 2012, não teria havido sequer um único pedido de esclarecimento por parte da CVM.

156. Quanto ao fato relevante de 13.03.2013, o acusado alegou que, ocorrendo declaração de comercialidade de um campo, a divulgação pela Companhia a esse respeito constituiria praticamente uma obrigação, uma vez que tal informação fica disponível no site da ANP. Sua divulgação, portanto, seria imprescindível.

157. Ademais, esse procedimento seria comum na indústria de óleo e gás e teria o intuito de permitir a posterior busca de soluções que viabilizassem os projetos até a elaboração do plano de desenvolvimento.

158. Além disso, todos os fatos relevantes publicados pela Companhia dispõem de extenso aviso legal, com conteúdo completo e minucioso, que destacariam os expressivos riscos e incertezas a que estivessem sujeitas as afirmações divulgadas.

159. Na divulgação de março de 2013, não teria sido divulgada estimativa de óleo recuperável para esses Campos. A ausência desta informação se justificaria pelo fato de não haver tal estimativa.

160. A primeira tarefa que Luiz Carneiro, como diretor presidente, teria dado ao novo gerente executivo de reservatórios teria sido a avaliação criteriosa de alguns ativos da Companhia, o que gerou um Relatório (fls. 2645-2664). O novo presidente teria, então, convocado a diretoria e dado ciência a todos do resultado de mencionado relatório recomendando a criação de um GT.

161. Assim como os demais, o acusado também alegou que não teria havido “estudo da Schlumberger” (fls. 2210), mas sim contratação de especialistas em reservatórios que, em conjunto com os técnicos da OGX, aprofundariam o conhecimento sobre o potencial de produção do reservatório.

162. Da mesma maneira, Reinaldo Vargas alegou que o GT teria sugerido uma série de providências a serem tomadas antes de garantir que os números apresentados fossem definitivos.

163. Como até aquele momento as dificuldades vislumbradas não seriam definitivas e se acreditava que seriam encontradas soluções de desenvolvimento dessas áreas, a declaração de comercialidade seria a única alternativa.

164. A defesa também apontou para o artigo 157, § 5º, da Lei 6.404/76 que reconhece que, em certas situações, os administradores podem não divulgar determinada informação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

165. O ex-presidente da CVM, Marcelo Trindade, também já se expressou em relação à manutenção do sigilo da informação sobre a existência de estudos acerca do cancelamento de registro da companhia até que decisão neste sentido fosse efetivamente tomada:

“É bastante razoável supor como sendo de interesse legítimo da companhia a não divulgação de estudos acerca do cancelamento de seu registro de companhia aberta. Sob essa ótica, tais informações poderiam ser mantidas em sigilo, não obstante caracterizassem um fato relevante (...)”³⁸

166. De acordo com o *Guidebook of Directors*³⁹, elaborado pela *American Bar Association*, os administradores devem confiar nas informações e nos relatórios e estudos que tenham sido elaborados pelo corpo executivo, por empregados, auditores e outros membros dos órgãos de administração dos quais não façam parte, desde que não tenham conhecimento de fatos que os levem a desacreditar nos dados.

167. Por fim, o acusado afirmou que não teria negociado qualquer ação da OGX, nem o pretendia fazê-lo enquanto seu contrato com a Companhia estivesse em vigor.

V. ROBERTO MONTEIRO

168. Roberto Monteiro apresentou defesa (fls. 2665-2720) tempestiva na qual alegou, primeiramente, que, que seria necessário analisar o contexto da época em que tomou posse (24.04.2012). Desde essa data, as descobertas de hidrocarbonetos não teriam sido mais divulgadas por meio de fatos relevantes. O único fato relevante questionado pela SEP e divulgado pelo acusado enquanto DRI teria sido o de 13.03.2013.

169. Quanto à declaração de comercialidade, o acusado afirmou que sua divulgação como fato relevante deveria ocorrer tão logo a administração formulasse juízo a respeito de sua relevância para o mercado.

170. Conforme a Instrução CVM nº 358/2002, caber à administração da própria companhia, a partir do momento em que se verifica a existência de decisões, fatos e atos a ela relacionados, analisar se estes podem influenciar de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de emissão na companhia e/ou na decisão de investidores de comprar ou vender tais títulos e, em caso afirmativo, providenciar sua divulgação.

171. A decisão da OGX de declarar a comercialidade dos Campos teria tido por objetivo reter as acumulações que estavam sob a concessão da Companhia para que as áreas não fossem devolvidas. Ademais, por ter submetido tal declaração à ANP, esta informação chegaria ao mercado de qualquer forma.

³⁸ Inquérito Administrativo nº 16/2000, julgado em 05.12.2002.

³⁹ American Bar Association. *Corporate Director's Guidebook*. 5th ed. The Business Lawyer, Chicago: August, 2007, v. 62, n. 4, p. 1494.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

172. Tal tratamento já haveria sido realizado em outras oportunidades pela OGX, conforme os fatos relevantes de 17.05.2011, 25.04.2012 e 14.05.2012, e pela Petrobras (fls. 2719-2720).

173. Tendo em vista a data limite de 11.03.2013 para a Companhia se posicionar perante à ANP em relação às acumulações, não teria havido como a OGX determinar em que grau a produtividade obtida no poço TBAZ-1 (Campo de Tubarão Azul) afetava o desenvolvimento econômico dos demais Campos.

174. Porém, como as dificuldades vislumbradas não seriam definitivas, a Companhia decidiu por emitir a declaração.

175. Os investidores do setor deveriam conhecer os riscos e os procedimentos envolvidos no exercício da atividade e, consequentemente, não poderiam acreditar que os Campos seriam economicamente viáveis desde a declaração.

176. Além disso, como alegado pelos os outros acusados, todos os fatos relevantes viriam com aviso legal.

177. Quanto ao fato relevante de 13.03.2013, o acusado não teria sido o responsável pela declaração em questão ou mesmo pela produção de conteúdo.

178. No período citado, a intenção da Companhia seria a de continuar seus estudos sobre as possibilidades de recuperação do óleo *in place*, obtendo, com isso, resultados conclusivos.

179. Roberto Monteiro também faz menção à Lei 6.404/76 no que diz respeito à opção dos administradores das companhias de não divulgar determinada informação caso entendam haver risco aos interesses da companhia. A doutrina também acentuaria que se considera legítima a manutenção do sigilo de informações cuja revelação favoreça os concorrentes.

180. A administração da companhia não seria obrigada a consultar a CVM caso decidisse não revelar ao mercado determinado ato ou fato relevante, mas teria apenas a faculdade de fazê-lo na hipótese de haver dúvida a respeito da conveniência da divulgação: “Na hipótese de o administrador ter dúvida acerca da divulgação de informação relevante, poderia consultar a CVM quanto à manutenção do sigilo sobre tal informação.”⁴⁰

181. Em 2011, a OGX estaria no meio das atividades de avaliação exploratória, sendo que ainda estariam sendo realizados poços exploratórios no primeiro semestre de 2012. As mencionadas “primeiras análises da Área de Reservatórios” seriam, portanto, questionamentos iniciais.

182. Quanto à não divulgação de dados relativos ao VPL e ao fator de recuperação dos Campos, estes seriam dados ainda em análise e não conclusivos. A Companhia teria continuado com seus estudos sobre as possibilidades de recuperação do óleo *in place*.

⁴⁰ Nota Explicativa nº 28/1984.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

183. Em relação à inexigibilidade de conduta diversa, exigir do DRI qualquer conduta diversa quanto à divulgação contrariaria os deveres de diligência e de agir no interesse social – ambos impostos pela legislação vigente⁴¹.

184. De acordo com o princípio do *business judgment rule*, o qual visa conferir uma proteção aos administradores, de modo a limitar a intromissão de terceiros no processo decisório da sociedade, as decisões tomadas por administradores, desde que de boa fé e no interesse da sociedade, não poderiam ser revistas pelos tribunais ou pelas autoridades administrativas, mesmo que tais decisões se revelassem malsucedidas.

V.5 MARCELO TORRES

185. Marcelo Torres apresentou defesa (fls. 2.721-2.936) tempestiva na qual, inicialmente, alegou que a SEP teria deixado de olhar a norma que a ela caberia aplicar. Se o tivesse feito, teria constatado que a descoberta de recursos da companhia é expressamente referida como fato relevante que deve ser publicado.

186. Em sede preliminar, a defesa alegou que a Acusação teria sido formulada sem que o acusado fosse chamado para prestar depoimento pessoal. Caso tivesse sido convocado, Marcelo Torres poderia ter evitado que se formasse uma visão distorcida dos fatos.

187. O próprio parecer do Professor Marcelo Trindade (fls. 2806-2836) corroboraria isso: “(...) não se pode dissimular a surpresa com o fato de ter sido produzida uma acusação de manipulação de preços sem que os depoimentos dos acusados e de outros diretores tenham sido tomados (...)”.

188. No decorrer das investigações, diversos ofícios foram encaminhados no intuito de solicitar esclarecimentos sobre fatos específicos e pré-selecionados. As respostas a tais ofícios seriam igualmente limitadas, uma vez que a manifestação dos acusados teria que se resumir a responder, objetivamente, as indagações a eles direcionadas.

189. Quanto a isso, a defesa solicitou o arquivamento do processo sem julgamento de mérito, uma vez que a acusação, ao não garantir ao acusado a prerrogativa da autodefesa, que não

⁴¹ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. § 1º O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. § 2º É vedado ao administrador: a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia; b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo. § 3º As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2º pertencerão à companhia. § 4º O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

poderia ser substituída por pedidos de esclarecimento, teria violado o direito constitucional de ampla defesa.

190. Visando dar mais substância à sua defesa, foi apresentado parecer do Professor Marcelo Trindade, ex-presidente da CVM que, por sua vez, concluiu que:

- a) a conduta de manipulação de preços vedada pela Instrução CVM nº 08/79 apenas se configuraria caso o agente (i) agisse com intenção específica de manipular; (ii) adotasse meio idôneo à manipulação; e (iii) e, ao agir intencionalmente, desse causa ao resultado de produzir oscilações artificiais;
- b) os esquemas de *pump and dump* envolveriam a disseminação de informações falsas ou inequivocamente distorcidas;
- c) no caso concreto, a própria SEP teria reconhecido a veracidade das informações divulgadas nos fatos relevantes;
- d) o padrão de divulgação adotado pela OGX não seria ilegal ou violador de norma regulamentar vigente, tendo em vista que (i) os avisos teriam trazido divulgações obrigatórias; (ii) os mesmos avisos teriam sido acompanhados de alertas; (iii) a forma de divulgação seria indiferente; e (iv) a existência de declarações estariam em linha com manifestações habituais do mercado;
- e) a Acusação não teria demonstrado os impactos decorrentes da divulgação sobre a cotação das ações da OGX, deixando de demonstrar a relação de causalidade entre os atos e a eventual variação no preço;
- f) a SEP não teria demonstrado que Marcelo Torres agiu com intenção específica de manipular preços; e
- g) não estariam presentes, pelos motivos expostos, os elementos necessários para imputar ao acusado a conduta de manipulação de preços.

191. O Acusado também se empenhou em demonstrar que, quanto às descobertas de indícios de hidrocarbonetos, o inciso XX, do parágrafo único, do art. 2º da Instrução CVM nº 358/02 determina expressamente que a descoberta de recursos da companhia deve ser divulgada por meio de fato relevante.

192. Os riscos e desafios relacionados à campanha exploratória da Companhia seriam divulgados de forma clara em todos os seus fatos relevantes e comunicados ao mercado e não meramente em notas de rodapé, como afirmado pela SEP.

193. A comparação feita pela Acusação entre a prática de divulgação da OGX com a da Petrobras teria se mostrado descabida, uma vez que tais companhias se encontrariam em momentos exploratórios e estágios operacionais distintos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

194. Além disso, a quantidade de fatos relevantes divulgados a respeito de novas descobertas de indícios de hidrocarbonetos seria proporcional à intensa atividade exploratória da Companhia no período, incomparável aos exemplos da HRT e QGEP.

195. A mudança da prática de divulgação adotada pela Companhia teria sido iniciativa do próprio acusado e não do novo DRI, tendo ocorrido antes de a OGX se tornar uma companhia operacional.

196. O acusado teria tido o cuidado de definir as diretrizes que pautariam a divulgação de fatos relevantes não só com base nas normas da própria CVM, mas também nas práticas de mercado e na experiência internacional.

197. Historicamente, a CVM sempre teria adotado uma postura pró-divulgação, punindo em diversas oportunidades aqueles que falharam no dever de divulgar informações que constituíam fatos relevantes.

198. Já em relação ao tom otimista dos fatos relevantes divulgados pela OGX, este refletiria, na verdade, a visão da Companhia diante do contexto no qual se inseriria até o momento de divulgação.

199. Ademais, a inclusão de comentários e declarações de administradores nos fatos relevantes seria prática comum no mercado.

200. Segundo a defesa, a divulgação de estimativas durante a perfuração de um poço seria adequada, uma vez que, à época do registro de oferta pública inicial de ações da OGX, a CVM teria analisado tanto o prospecto da Companhia, quanto o estudo de viabilidade econômico-financeira.

201. A acusação teria concluído, com base nos esclarecimentos da ANP, que não seria possível realizar estimativas de reservas durante a fase inicial da exploração, quando, na verdade, todas as estimativas divulgadas pela OGX seriam estimativas de recursos e não de reservas.

202. A realização de estimativas de recursos durante a fase inicial de exploração seria prevista pela própria regulamentação da ANP. Tanto seria possível realizar estimativas em fase inicial que (i) a própria ANP o teria feito quando das descobertas do campo de Libra; (ii) a Petrobras, em pelo menos três oportunidades em 2003, teria divulgado estimativas semelhantes; e (iii) tal prática também seria seguida por companhias estrangeiras;

203. Quanto ao plano de opções e vendas de ações, as negociações realizadas pelo acusado demonstrariam comportamento de quem não se aproveitou de qualquer manipulação de mercado, tendo alienado quantidade muito inferior àquela a que teria direito nos termos do plano e o tendo feito somente em oportunidades que não guardavam qualquer relação com os mais de 50 fatos relevantes considerados inadequados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

204. A segunda venda de ações teria sido feita pelo acusado somente após a divulgação do relatório da DeGoyle & MacNaughton de 2011, que acabaria por derrubar o preço das ações emitidas pela OGX.

205. O *black out period*, instituído pelo acusado em 17.05.2010 e suspenso somente em 07.06.2011, teria se mostrado prova inequívoca de que não houve qualquer manipulação de mercado, pois (i) nesse período, as ações da OGX teriam tido alta expressiva; e (ii) 29 dos 54 fatos relevantes mencionados teriam sido divulgados dentro desse intervalo.

V.6 EIKE BATISTA

206. Eike Batista apresentou defesa (fls. 2937-3128) tempestiva, na qual alegou, resumidamente que:

- a) as divulgações feitas pela OGX durante o período de 2009 a 2012, quanto à descoberta de hidrocarbonetos, estariam em linha com o art. 2º da Instrução CVM nº 358/02 e adequadas às práticas de mercado e ao estágio operacional em que se encontrava a OGX (fase exploratória);
- b) durante os quatro anos em que foram divulgados os 54 fatos relevantes objeto da análise, a SEP jamais teria alertado a Companhia sobre a suposta falta de relevância da descoberta de hidrocarbonetos, sendo que, somente após o insucesso empresarial dos seus campos exploratórios, é que a CVM teria passado a considerar descabidas tais divulgações, atitude que não encontraria amparo na boa fé objetiva e violaria o disposto no art. 2º, XIII, da Lei 9.784/99⁴²;
- c) o prospecto, os formulários de referência, os comunicados e fatos relevantes teriam sempre registrado longa advertência quanto aos riscos relacionados aos seus negócios e expressamente afirmado que as informações constantes de cada um estariam “sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas”.
- d) os documentos ainda advertiram que “diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais diverjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas [...]”; e
- e) ainda que se reconhecesse a irrelevância dos fatos relevantes mencionados, nada conduziria à responsabilidade de Eike Batista.

207. Caso a SEP não tivesse desconsiderado (i) os termos de cada um dos fatos relevantes à luz do estágio operacional da OGX, (ii) as ressalvas de risco desde o IPO e em todos os fatos

⁴² Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

relevantes; e (iii) as peculiaridades da indústria, não teria chegado à conclusão de que houve falha ou culpa.

208. Além disso, a SEP teria desconsiderado os contornos e peculiaridades das companhias de petróleo ao acabar negando que, na fase pré-operacional, tudo o que se pode informar ao mercado seriam os dados que foram passados, com a ressalva dos riscos inerentes.

209. A SEP teria partido da presunção de que, a cada poço, um teste de formação deve ser feito. Aos testes de formação, na verdade, somar-se-iam outros meios de diagnóstico. No caso da OGX, teriam sido feitos muitos testes tal como evidenciariam os fatos relevantes de 22.12.09, 03.02.10, 09.02.11, 12.05.11, 15.07.11, 20.06.11, 02.09.11, 03.10.11, 12.04.12 (fls. 3075-3089).

210. O mercado, no caso em questão, teria tido inequívoco conhecimento da realidade. Desde a primeira divulgação do formulário de referência da Companhia, seria constatada a ressalva de que a prospecção de petróleo poderia ser distinta das projeções anunciadas.

211. Ademais, como trazido pelas demais defesas, cada descoberta de hidrocarbonetos seria notificada à ANP.

212. Os agentes sofisticados – com plena capacidade de análise e interpretação dos dados públicos – não teriam reagido com indiferença aos fatos relevantes, nem teriam recriminado sua divulgação, razão pela qual teriam conferido nota ‘B+’ para as *unsecured notes* emitidas pela Companhia e concluído pela estabilidade do *rating*.

213. Não faria sentido a afirmação da SEP de não ser “necessário conhecimento técnico para identificar a linguagem otimista e exagerada contida nas divulgações mencionadas” (fls. 2179). A linguagem dos grandes bancos, fazendo suas próprias análises, seria ainda mais otimista (fls. 3091-3096).

214. Não haveria indicação, por parte de órgãos fiscalizadores, de alegada errônea de informações “irrelevantes” divulgadas. Nesse sentido, a OGX teria sido capaz de levantar no mercado internacional de *bonds* mais de US\$ 4 bilhões em dívida para financiar suas operações. Entre os credores dos *bonds* estariam as maiores instituições financeiras do mundo sendo que, à época, nenhuma teria qualificado como “irrelevantes” as informações divulgadas pela OGX.

215. Seria equivocada a conclusão de que a descoberta de hidrocarbonetos não representaria fato relevante, haja vista a suposta alteração de prática de divulgação adotada pela própria Companhia que, a partir de 26.04.12, teria passado a divulgar tais informações apenas no apêndice de apresentações institucionais. A mudança indicaria que a Companhia já se aproximava da fase de produção.

216. Ao contrário do afirmado pela SEP, o conteúdo da informação estaria em linha com outras passadas ao longo dos anos pela Petrobras. Conforme seu fato relevante divulgado em 08.11.07, a companhia informou ao mercado o potencial positivo dos volumes estimados de óleo e gás para os reservatórios do pré-sal, antes da sua confirmação:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

“Os volumes recuperáveis estimados de óleo e gás para os reservatórios do pré-sal, se confirmados, elevarão significativamente a quantidade de óleo existente em bacias brasileiras, colocando o Brasil entre os países com grandes reservas de petróleo e gás do mundo” (fls. 3115-3124).

217. Dadas as circunstâncias, Eike Batista teria acreditado nas informações que recebia e nas condutas e rotinas implementadas por seu time de profissionais. No período em que atuou como diretor presidente, não haveria evidência a respeito da inviabilidade dos Campos.

218. Em outras ocasiões, a CVM já teria rechaçado acusações de negligência de administradores por entender como correta a divulgação paulatina de informações, em conformidade com a disponibilidade dos novos dados e estudos procedidos pela Companhia:

“(…) II – É adequado e desejável o procedimento de divulgação paulatina das informações, conforme tornem-se disponíveis e suficientemente concretas, a juízo do administrador, e com ressalva de sua sujeição a modificações.”⁴³

219. A SEP não teria alertado a OGX sobre a suposta irrelevância das informações divulgadas, pois não haveria nada de errado com elas. Afinal, teriam se pautado nos resultados indicados pelos estudos técnicos.

220. Ainda que irrelevantes, o silêncio da CVM ao longo de quatro anos e diante das 54 divulgações, teria feito surgir o direito da OGX de publicar os fatos relevantes acerca das descobertas.

221. Mesmo que se entendesse que os fatos publicados fossem irrelevantes, estes teriam sido divulgados sem a ciência da prática de ilícito e para o cumprimento do *full disclosure*, traduzido no dever de divulgar as principais informações da Companhia. Restaria caracterizado o erro inevitável quanto à ilicitude de que trata o art. 21 do Código Penal – aplicável por analogia ao processo administrativo sancionador.

222. Por fim, a defesa de Eike Batista requereu, com base no art. 20 da Instrução CVM nº 538/2008 e nos arts. 2º, X, 30 e 39 da Lei 9.784/94, determinação de produção de prova:

- a) pericial, de engenharia de petróleo, para demonstrar embasamento técnico dos fatos relevantes divulgados no período questionado;
- b) contábil, para demonstrar que, no período abrangido pela presente acusação, Eike Batista jamais teria alienado ações, investindo pesadamente na companhia;
- c) testemunhal, com finalidade de corroborar os argumentos indicados acima no sentido de que o acusado não teria participado ativamente da aprovação dos fatos relevantes e mesmo que o tivesse feito, não teria expertise para determinar sua relevância;

⁴³ Inquérito Administrativo nº 22/99.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

223. Além disso, Eike Batista encaminhou, junto à sua defesa, pedido⁴⁴ de tratamento confidencial ao Relatório ICTS e seus anexos apresentados sob o argumento de que tais documentos estariam suportados e acompanhados de cópias de contratos com terceiros, protegidos por cláusula de confidencialidade.

V.7 PAULO MENDONÇA

224. Paulo Mendonça apresentou defesa (fls. 3129-3291) tempestiva, na qual requereu, preliminarmente, a juntada do Processo CVM nº RJ 2013/7307, que tratou de reclamações de investidores envolvendo a divulgação de informações pela OGX, no presente PAS com o objetivo de atender aos princípios da busca da verdade real, ampla defesa e do devido processo legal.

225. Quanto ao mérito, alegou que a atividade desenvolvida pela indústria de óleo e gás seria de grandes riscos, principalmente no segmento *upstream* (fase exploratória), sendo que o Prospecto de IPO da OGX teria informado sobre todos os riscos inerentes à atividade.

226. O tom utilizado nas declarações do acusado seria compatível com a prática do mercado. Haveria, ainda, aviso legal em cada uma delas, sendo que os fatos relevantes afirmariam que os poços ainda estavam sendo perfurados, havendo somente indício da presença de hidrocarbonetos.

227. A ANP também divulgaria por conta própria em sua página de internet todas as descobertas – todos os indícios de hidrocarbonetos reportados – seja pela OGX ou por outros concessionários.

228. Durante o período em que o acusado fez parte da diretoria da OGX, teria exercido o direito de adquirir um total de 11.08.700 ações OGXP3 e, para tanto, teria efetuado o pagamento à Centennial Asset no valor de cerca de R\$ 2.000.000,00. Das ações adquiridas, Paulo Mendonça teria alienado apenas 1.321.300 enquanto esteve na Companhia, não obstante grande parte de suas ações estarem aptas à alienação.

229. Mesmo após o seu desligamento da OGX, o acusado teria mantido parte substancial das ações OGXP3 por acreditar no forte potencial da Companhia (cerca de 9.760.400 ações em carteira – 88% do seu “pacote de remuneração”). Mais de dois anos após seu desligamento, o acusado ainda deteria em torno de 8.000.000 ações OGXP3, figurando entre um dos maiores acionistas minoritários, como pessoa física, da OGX.

230. Quanto ao conteúdo dos fatos relevantes divulgados, a defesa de Paulo Mendonça alegou resumidamente, que este corresponderia à total realidade de fatos que, por sua vez, teriam sido embasados em dados precisos e respaldados por relatórios de companhias especializadas.

⁴⁴ Fls. 2978. Em despacho assinado em 05.04.2014 (fls 3293 – 3294), o presidente da CVM Leonardo P. Gomes Pereira destacou que os anexos descritos no Relatório ICTS não constavam nos autos do processo, mas que o documento apresentava informações de caráter comercial e estratégico, além de dados financeiros e interesses negociais cuja exibição poderia causar prejuízo às partes envolvidas, o que justificaria a concessão de sigilo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

231. Todos os documentos técnicos que embasaram os fatos relevantes teriam sido solicitados e disponibilizados à SEP. A análise da Acusação teria se mostrado inadequada por ter se restringido a pesquisa de companhias congêneres à OGX ao período compreendido entre 2012 e 2014, que seria posterior aos fatos analisados nesse PAS.

232. Para qualquer sociedade petrolífera que estivesse em estágio pré-operacional, a ocorrência de uma descoberta na área explorada representaria um evento importante e animador, o que justificaria sua comunicação ao mercado, bem como o tom otimista quando da transmissão de tal informação.

233. O art. 2º da Instrução CVM nº 358/2002 menciona, no rol exemplificativo de hipóteses em que um fato pode ser considerado relevante, a descoberta de recursos:

“Art. 2º. Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável:

(...)

XX – descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da companhia.”

234. Quanto à distinção entre fato relevante e comunicado ao mercado, inexistiria regulamentação própria da CVM a esse respeito. Tampouco nos Estados Unidos existiria tal distinção, onde as companhias fazem suas divulgações por meio de *press releases*, que contém informações técnicas e declarações de administradores.

235. No que se refere a descobertas de indícios de hidrocarbonetos, a SEP teria, no passado, se posicionado de maneira diametralmente oposta à tese defendida no Termo de Acusação, tendo procedido a mais de uma acusação, tanto em face do diretor financeiro e de relações com investidores, quanto do diretor de exploração e produção da Petrobras.⁴⁵

236. A mensagem transmitida pela CVM à época do PAS CVM nº 2009/6713⁴⁶, seria no sentido de que se uma informação fosse potencialmente relevante, não seria possível utilizar como argumento o fato de a informação ter sido levada a conhecimento público mediante simples notificação de descoberta à ANP.

⁴⁵Depreender-se-ia da leitura do Parecer do Comitê de Termo de Compromisso relativo ao PAS CVM nº 2009/6713, datado de 13.02.2010, que o diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras supostamente teria infringido o disposto “no § 4º do art. 157 da Lei 6404/76, combinado com o § 3º do art. 3 da Instrução CVM 358/02 por não ter divulgado Fato Relevante sobre existência de petróleo leve na segunda perfuração do campo de Tupi, no momento em que tal informação foi transmitida à ANP [...]”.

⁴⁶ Ressaltou-se que o Parecer do Comitê de Termo de Compromisso no âmbito do PAS CVM nº RJ 2009/6713 é datado de 13.02.2010, mesma época dos Fatos Relevantes analisados no presente PAS.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

237. Existiriam diferentes tipos de testes de formação, sendo que todos teriam como objetivo aferir a pressão do poço e a possibilidade de vazão (extração) dos hidrocarbonetos existentes na jazida. A OGX teria realizado RFTs⁴⁷ em todos os poços pioneiros e também TFRs⁴⁸ em pelo menos dez poços – ao contrário do que apenas cinco como teria alegado a Acusação.

238. Independente do estágio de evolução da prospecção e da classificação do tipo do recurso, o mercado faria a sua análise de risco vs retorno considerando os cenários inerentes à atividade exploratória.

239. O próprio comportamento do mercado de valores mobiliários, principalmente dos analistas com notória experiência na área de petróleo e gás natural, evidenciaria que as divulgações realizadas pela Companhia não seriam imprecisas. Haveria apenas o objetivo de informar o que ocorria e não o de influenciar a decisão dos investidores.

240. Tanto a doutrina, quanto à jurisprudência seriam pacíficas em relação à necessidade de identificar os requisitos objetivos e subjetivos para a caracterização de manipulação de preços.

241. No entanto, a SEP não teria demonstrado qualquer elemento que concluísse que o acusado teria manipulado a cotação dos papéis da OGX e que, ao proceder assim, teria agido com dolo específico com vistas à obtenção de vantagem indevida ou lucro para si.

242. Os fatores elencados pelo Relatório do Consultor Heitor Campani (fls. 3217-3231) também confirmariam a inocorrência de manipulação de preços. Ver-se-ia, inclusive, que o acusado perdeu o “timing” da venda que seria buscado por um manipulador.

243. Para caracterizar manipulação de preços, seria preciso que o manipulador se utilizasse de qualquer processo ou artifício com o objetivo de alterar a cotação. Uma operação seria artificiosa quando as partes nela envolvida não desejassem realmente adquirir ou alienar o ativo-objeto, mas apenas criar uma falsa aparência de mercado.

244. A SEP não teria conseguido apontar artifício ou processo utilizado pelo acusado. Em momento algum a Acusação teria afirmado que as informações veiculadas seriam falsas, apenas se insurgindo quanto às declarações supostamente otimistas. O tom otimista jamais poderia ser comparado à artifício ou processo.

245. A Acusação, apesar não contestar a veracidade das informações divulgadas pela Companhia, teria lastreado seus argumentos no entendimento de que tais informações seriam irrelevantes, o que seria contraditório dado que, se os fatos fossem irrelevantes, não seriam capazes de influenciar a conduta dos participantes.

246. Não haveria explicitado, no Termo de Acusação, as oscilações provocadas pela divulgação dos fatos relevantes, do mesmo modo em que não haveria indicação de supostas oscilações decorridas de outros fatores.

⁴⁷ Teste de Formação Repetitivo.

⁴⁸ Teste de Formação a Poço Revestido.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

247. A Instrução CVM nº 08/79, ao exigir a presença de um ato intencional (dolo específico) e de um resultado que derive desse ato, torna obrigatória a verificação de um nexo de causalidade entre os dois elementos. A Acusação, no caso, não teria se desincumbido de demonstrar quais foram os impactos dos fatos relevantes nas cotações das ações.

248. A relação entre anúncio de fatos relevantes e o retorno das ações OGXP3, conforme análises constantes do Relatório de Heitor Campani, seria insignificante e, portanto, não haveria nem mesmo evidência estatística que sugerisse indícios de manipulação de preços.

249. Teria sido verificado também que o comportamento das ações da OGX no período seguiu o mesmo padrão de valor de negociações das ações da Petrobras.

250. Adicionalmente, o acusado teria ressaltado que o uso de opção de ações como parte integrante do pacote de remuneração dos administradores seria considerado um bom mecanismo de governança corporativa e uma prática comum adotada em todo o mundo. Seria natural, assim, que os executivos que percebessem a totalidade ou parte de remuneração em ações exercessem as opções adquirindo e alienando ações.

VI. DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

251. Em 08.12.2014, José Cavalcanti, Luiz Carneiro e Paulo Guimarães protocolaram propostas individuais de Termo de Compromisso (fls. 3296-3300; 3316-3322; 3323-3329), nas quais reafirmaram suas razões de defesa e se comprometeram a pagar R\$100.000,00, cada um. Roberto Monteiro e Reinaldo Vargas apresentaram propostas semelhantes (fls. 3330-3336; 3337-3344), nas quais se comprometeram a um pagamento de R\$200.000,00, cada. Finalmente, em 09.12.14, Paulo Mendonça enviou proposta (fls. 3301-3312) se comprometendo ao pagamento de R\$400.000,00 à CVM.

252. Todos os pedidos reunidos resultaram na abertura de processo administrativo em apartado (PA CVM nº RJ2014/14074 – fls. 3345).

253. Em 01.12.2015, o Colegiado da CVM deliberou (fls. 3448-3449) a rejeição das propostas acompanhando o entendimento do parecer do Comitê de Termo de Compromisso e da PFE, apontando a existência de óbice legal à aceitação, em virtude do não atendimento ao art. 11, II, 5º, da Lei 6385.76, que requer a correção das irregularidades com indenização de prejuízos.

VII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

254. Em 16.12.2014, o processo foi distribuído para a Diretora Luciana Dias em reunião do Colegiado (fls. 3.346).

255. Em 08.09.2015, o processo foi redistribuído para o Diretor Roberto Tadeu em reunião do Colegiado, em atendimento ao disposto no art. 9º da Deliberação CVM nº 558/2008, tendo em vista a licença maternidade da Diretora Luciana Dias, cujo término coincidiu com o fim de seu mandato (fls. 3391).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

256. Em 26.07.2016, o processo foi redistribuído para minha relatoria em reunião do Colegiado, de acordo com os termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/08 (fls. 3602).

VIII. DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E RECURSO INOMINADO

257. Em 19.02.2015, Eike Batista encaminhou manifestação (fls. 3371-3374) acerca do pedido de produção de provas formulado em sua defesa.

258. Em dita manifestação, requereu (i) produção de perícia contábil, visando demonstrar que ele jamais teria alienado ações no período abrangido; e (ii) prova fundamental de perícia de engenharia de petróleo, a fim de demonstrar o embasamento técnico dos fatos relevantes.

259. Em 31.05.2015, a então diretora Luciana Dias deferiu (fls. 3375-3377) pedido de apresentação de perícias contábil e de engenharia de petróleo, esclarecendo que caberia ao acusado a indicação de especialistas e custeio. Também foi deferida produção de prova testemunhal na forma de manifestação por escrito de testemunhas listadas.

260. Em 09.04.2015, Eike Batista protocolou recurso inominado (fls. 3392-3397) com o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida pela diretora da CVM.

261. Segundo o acusado, a decisão teria transferido a ele a incumbência prática da produção probatória e o seu custo. Tendo a decisão fixado prazo incompatível e inviável de produção de provas, esse fato também se equipararia à negativa da prova. Além disso, a decisão teria contrariado a lógica processual, uma vez que correriam em paralelo as provas técnica e testemunhal.

262. No recurso, Eike Batista solicitou que se fixassem os prazos de 120 dias para a perícia contábil e de 180 dias para a perícia de engenharia de petróleo, e que as audiências com as testemunhas ocorressem de forma presencial e após a conclusão das provas periciais.

263. Novo expediente (fls. 3398-3407) fazendo parte do recurso foi protocolado em 15.04.2015 no qual (i) foram reiterados os pedidos de reconsideração da decisão; (ii) foi apresentado um rol de testemunhas com as respectivas questões a serem feitas a cada uma delas; e (iii) foi anexada uma proposta de trabalho elaborada pela empresa Hill International para a realização dos serviços de perícia de engenharia de petróleo.

264. Em 13.05.2015, o Diretor Roberto Fernandes decidiu (fls. 3413-3416) pela produção das provas periciais nos prazos solicitados pelo acusado.

265. Em 14.03.2017, neguei (fls. 3626-3628) provimento ao recurso de Eike Batista, mantendo a decisão da Diretora Luciana Dias e facultou ao acusado a apresentação de lista atualizada de testemunhas e de questões no prazo de 10 dias de sua intimação. O colegiado (fls. 3629-3631), por unanimidade, seguiu o voto do relator.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

266. Em 15.03.2017, foi deferido pedido (fls. 2801-2803) de produção de provas apresentando por Marcelo Torres em sua defesa no sentido de analisar o comportamento das ações da OGX durante o período destacado pela Acusação.

267. Em 30.03.2017, Eike Batista apresentou lista atualizada de rol de testemunhas e perguntas, além de juntar documento (fls. 3925-2953) de laudo pericial formulado pela Tendências Consultoria Integrada (“Parecer Tendências”).

IX. DAS PROVAS PRODUZIDAS

IX.1 DOS LAUDOS PERICIAIS

IX.1.1 LAUDO CONTÁBIL

268. Em 11.02.2016, Eike Batista juntou laudo contábil elaborado pela APSIS Consultoria, no qual informou que o valor total dos seus aportes nas Companhias OGX e OSX haveria sofrido desvalorização de 74,91% até o dia 03.09.2013, data da venda da última ação do seu segundo período de alienação (de 27.08.2013 a 03.09.2013).

269. Entre a data de divulgação das conclusões iniciais do GT, em 24.09.2012, e o início o primeiro período de alienação do acusado (de 24.05.2013 a 10.06.2013), o valor da participação de Eike Batista nas Companhias teria se reduzido em aproximadamente R\$ 8,985 bilhões, ou 67%, sem que tivesse havido qualquer alienação.

270. Durante o período entre o final da primeira alienação e o início da segunda, o qual o laudo denominou “Período Crítico”, a participação de Eike Batista na OGX teria sofrido desvalorização de aproximadamente R\$ 12,342 bilhões, já considerando o valor apurado nas duas alienações. O valor total oriundo da primeira e segunda alienações juntas teria sido de aproximadamente R\$ 333 milhões.

271. O laudo ressaltou os aportes realizados por Eike Batista na OSX, entre novembro de 2012 e julho de 2013, totalizando R\$ 1,259 bilhões, que teriam tido o objetivo de viabilizar a construção das plataformas FPSO para exploração dos campos posteriormente descobertos inviáveis. Desse total, R\$ 241 milhões teriam sido aportados entre a primeira e segunda alienação.

272. Os valores auferidos na primeira alienação teriam sido destinados ao cumprimento de obrigações contratuais com o Mubadala Development Company (“MDC”). Os valores auferidos na segunda alienação teriam sido destinados ao cumprimento de obrigações contratuais com a GE, o Bradesco e obrigações de Eike Batista quanto ao exercício de uma PUT pela OSX.

273. O estudo conclui que os recursos auferidos com as alienações no Período Crítico teriam sido efetivamente utilizados para pagamento das dívidas que haviam sofrido desenquadramentos contratuais com os credores que tinham em garantia as referidas ações.

IX.1.2 LAUDO DE ENGENHARIA



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

274. Em 11.04.2016, Eike Batista protocolou laudo de engenharia elaborado pela Hill International, o qual teceu considerações acerca do que foi apresentado no PAS RJ 2014/6517.

275. De maneira geral, referido laudo concluiu que a Política de Divulgação e Uso de Informações para o Mercado da OGX seria correta e adequada sob a perspectiva da boa governança e refletiria no âmbito da Companhia as melhores práticas da indústria à época de sua elaboração e não à luz dos fatos supervenientes.

276. A OGX teria se estribado no entendimento de promover, com base nos fatos de interesse da época, o *full disclosure* dos acontecimentos, tratando os fatos comunicados como relevantes. A Companhia também consideraria que a maioria deles trataria de informações que chegariam ao mercado de qualquer forma, uma vez que a ANP os disponibilizaria em seu site.

277. Segundo o documento, as equipes de exploração e engenharia de reservatório e reserva da OGX conheceriam plenamente as normas e práticas de estimativas de reserva recomendadas pelo PRMS e pela ANP.

278. Seria possível, notadamente com as tecnologias mais recentes, efetuar estimativas de volumes de uma descoberta ainda durante a perfuração de um poço exploratório. A OGX teria feito uso de tecnologias como o monitoramento em subsuperfície com LWD/MWD (Logging While Drilling/Measuring While Drilling).

IX.1.3 PARECER ECONÔMICO

279. Em 30.03.2017, Eike Batista juntou parecer econômico elaborado pela Tendências Consultoria Integrada.

280. Tal documento concluiu que a situação econômico-financeira das principais empresas do Grupo EBX seria muito grave, com insuficiente capacidade de geração de caixa para manutenção de suas atividades e elevado endividamento.

281. A situação estaria se agravando ainda mais, pois a geração negativa de caixa nas principais empresas acarretaria elevação adicional do endividamento e o acúmulo de prejuízos resultaria em redução do patrimônio líquido, evidente ao se considerar de forma combinada (soma simples) as empresas de capital aberto do grupo.

282. As dívidas descritas não refletiriam completamente, em termos econômicos, o endividamento do grupo EBX, pois abrangeriam as empresas fechadas. Ademais, existiria um contrato do controlador do grupo e do fundo Centennial Asset Brazilian Equity Fund LLX com o MDC para captação de US\$ 2 bilhões na forma de participação de 5,63% em ativos detidos por Eike Batista direta ou indiretamente. Esse contrato poderia ser considerado um contrato de participação, mas, do ponto de vista econômico, constituiria uma dívida.

283. A ocorrência de default de dívidas garantidas da OSX resultaria em aumento do endividamento assumido pela OGX. Dado que, naquele momento, o endividamento da Companhia já seria de US\$ 3,97 bilhões, a incorporação de mais empréstimos e financiamentos ao seu passivo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

resultaria em um endividamento superior a US\$4 bilhões. Tal situação poderia acarretar antecipação de vencimento dos títulos emitidos pela OGX e, assim, comprometer a liquidez da Companhia.

284. Diante do elevado endividamento ao qual o grupo estaria exposto, aliado aos prejuízos operacionais que já se apresentariam desde o início do ano e às perdas patrimoniais verificadas no período, a venda das ações OGX e OSX, ocorridas no período entre maio e junho e agosto a setembro de 2013, teria sido motivada pelo intuito de renegociar e adimplir os contratos mencionados, que já abrangeriam as ações alienadas por Eike Batista como garantia de pagamento aos credores.

285. A atuação do acusado teria evitado que as posições acionárias em garantia fossem vendidas em sua totalidade, tendo ele preservado sua condição de acionista controlador tanto na OGX quanto na OSX até a presente data.

286. Ademais, o endividamento do Grupo EBX constituiria parte significativa do passivo das instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN)⁴⁹, sendo que o default do grupo acarretaria em graves consequências, com redução de liquidez e capacidade de empréstimos do sistema bancário brasileiro.

287. Alguns compromissos vencidos em maio e setembro de 2013, se não fossem cumpridos ou renegociados, implicariam em default, com repercussão para todo o grupo, pois suas empresas seriam submetidas aos efeitos da declaração pelos credores, do vencimento antecipado cruzado (*cross default* e *acceleration default*) da quase totalidade das operações de créditos bancários e títulos mobiliários.

288. Em uma situação como essa, restaria aos credores e às empresas liquidar os ativos ou preservar as operações, permitindo a geração de recursos nas atividades que se mostrassem economicamente viáveis e amenizassem as perdas. Essa última solução geralmente implicaria a repactuação dos empréstimos concedidos e a concessão de novos empréstimos ou aporte de recursos que permitissem a continuidade das atividades viáveis.

289. Haveria, portanto, um grande lapso temporal entre as conclusões parciais do GT da OGX que colocariam em dúvida o potencial dos poços de petróleo da companhia e o momento em que Eike Batista vendeu ações. No mesmo período, a queda no preço das ações teria sido brutal, sendo resultado das próprias divulgações trimestrais e eventuais obrigatórias que seriam feitas ao mercado. O momento e as circunstâncias em que Eike Batista vendeu ações e a destinação dada aos recursos financeiros obtidos permitiriam concluir que a conduta teve o objetivo econômico de cumprir obrigações e reestruturar dívidas existentes.

⁴⁹ Do total registrado em maio de 2013, as dívidas e os avais contraídos pelo grupo com o Itaú totalizariam R\$ 5,1 bilhões, representando 6,2% do Patrimônio Líquido (PL) da instituição, enquanto o total contraído com o Bradesco corresponderia a 5,5% do seu PL, dado o endividamento de R\$ 3,6 bilhões do grupo com essa instituição. Em relação ao BTG, as dívidas seriam R\$ 2,5 bilhões, que representariam 23,6% do patrimônio líquido do banco.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IX.2 DAS MANIFESTAÇÕES DAS TESTEMUNHAS

290. Em 12.05.2017, a SPS enviou ofícios (fls. 3711-3720) para João Borges Ferreira Neto, Raul Silva, André Pastura, Ernesto Guedes e Juliano Magalhães Macedo intimando-os a prestar informações, conforme requerido por Eike Batista.

291. Em 02.06.2017, Raul Silva protocolou resposta ao ofício enviado, alegando que a ICTS teria elaborado o relatório não tendo característica de auditoria e sim de escopo limitado ao levantamento dos eventos pertinentes ao assunto, com base nos documentos fornecidos pela EBX, evidências e relatos de gestores e funcionários.

292. Conforme descrito no Master Partnership Agreement EAV/Section 6.07, as ações teriam sido dadas como garantia do acordo e depositadas em uma lockbox do HSBC.

293. De acordo com os comprovantes de transferência, US\$94.040.358,80 teriam sido transferidos para o OTX Fund decorrente da venda de 126.650.500 ações.

294. De acordo com o documento OGX Sale Letter to Itau, o Mudabala teria notificado o desenquadramento das garantias estabelecidas com a CAMF e feito um acordo para autorizar a venda das ações depositadas em garantia na lockbox com a exigência de transferência imediata dos fundos para o seu controle (OTX) e também para receber um pagamento em dinheiro no montante de US\$ 56.000.000.

295. No acordo de reestruturação “Transaction Agreement”, assinado em 03.07.2013, a EAV teria ficado obrigada a efetuar um pagamento de US\$150.000.000, sendo que US\$94.000.000 deveriam ser provenientes da venda de ações da OGX e US\$ 56.000.000 pagos em dinheiro.

296. Em 01.06.2017, Ernesto Guedes apresentou manifestação descrevendo a participação de Eike Batista na OGX em diferentes momentos e afirmou que a conduta objetiva do acusado, na qualidade de controlador da OGX, teria como elementos e racionalidade econômica os seguintes fatores: (i) grave situação econômico-financeira do Grupo EBX; (ii) efeitos cruzados entre as empresas do Grupo EBX; e (iii) venda das ações como forma de evitar o colapso do Grupo EBX.

297. Em 12.06.2017, João Borges Ferreira Neto enviou correspondência na qual respondeu aos esclarecimentos solicitados.

298. Por meio dela, informou que teria trabalhado na OSX como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores durante o período de junho de 2012 a abril de 2013.

299. Também teria conhecimento de que nos meses de setembro de 2012 e dezembro de 2013, Eike Batista teria realizado aportes por meio do exercício da PUT e por AFAC no valor estimado de US\$ 620 milhões e R\$ 160 milhões, respectivamente.

300. De acordo com as informações que lhe foram prestadas, as ações de emissão da OSX de propriedade do controlador Eike Batista teriam sido dadas em garantia para as transações com o Grupo GE e Mudabala.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

301. A decisão de não trazer a unidade OSX-2 para o Brasil teria ocorrido quando o depoente já não mais trabalhava na OSX. Em junho de 2013, a OGX teria comunicado à OSX e ao mercado que havia concluído que não existiria, naquele momento, tecnologia capaz de tornar economicamente viável o desenvolvimento dos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia, bem como sobre sua intenção de requerer junto à ANP a suspensão do desenvolvimento dos respectivos campos.

302. O depoente desconheceria o processo de admissão do investimento realizado pelo Grupo Mubadala, apenas sabendo que haveria um processo de *due diligence* conduzido pelos investidores.

303. O Fundo Soberano Mubadala teria, segundo conhecimento do depoente, investido no Grupo EBX por meio de um instrumento híbrido (participação no capital e dívida) o valor em reais equivalente a aproximadamente dois bilhões de dólares. Referido instrumento contemplaria uma cesta de ativos que teriam sido oferecidos em garantia, composta por ações das companhias listadas na bolsa.

304. Em 27.07.2017, André Pastura enviou correspondência em que afirma ter exercido o cargo de gerente de finanças corporativas de janeiro de 2012 até maio de 2013, e de gerente geral financeiro, de junho de 2013 até abril de 2015.

305. Sore os questionamentos, declarou que Eike Batista teria investido na OSX de janeiro de 2012 a abril 2015, através de subscrição de ações, exercício da PUT OSX, AFAC e mútuos o valor aproximado de R\$ 1,5 bilhões.

306. Em 04.08.2017, Juliano Magalhães Macedo apresentou correspondência, na qual alegou que o trabalho técnico realizado pela Hill Internacional teria constituído uma análise de todos os documentos disponíveis à época. Em sua visão, os fatos relevantes divulgados quanto à descoberta de hidrocarbonetos estariam em linha com o art. 2º da Instrução CVM nº 358/2002, aderente às práticas do mercado e ao correspondente estágio operacional da OGX naquele momento.

307. A necessidade de revisão dos modelos geológicos e de reservatório durante o processo de desenvolvimento teria ocorrido porque foi medido o desempenho de poços colocados em fluxo com vazões muito abaixo das medidas nos primeiros testes, assim como teriam sido revisados para baixo os volumes de recursos. A Companhia teria agido no sentido de aprofundar essa linha de estudos.

308. A criação do tipo de grupo multidisciplinar de trabalho, tal qual o GT, seria prática comum e que sempre traria bons resultados na indústria de petróleo na fase de desenvolvimento da produção, principalmente quando se tratando de projetos mais caros, como os de natureza offshore.

309. No período compreendido entre 25.09.2012 a 01.07.2013, ainda na transição da fase de avaliação para a fase de desenvolvimento de campos descobertos, a OGX teria buscado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

implementar, de modo correto, as recomendações do GT, bem como avaliar o desempenho dos poços postos em produção.

IX.3 DO COMPORTAMENTO DAS AÇÕES DA OGX

310. Em novo despacho (fls. 3862-3867) a GMA-2, diante da solicitação de realização de diligências requerida por Marcelo Torres, efetuou avaliação estatística dos retornos diários das cotações das ações ON de emissão da OGX (código OGXP3) no período de janeiro 2009 a abril 2012. Nessa análise também utilizou como insumos os retornos diários do principal *benchmark* do mercado de ações brasileiro, o Índice Bovespa (“IBOV”).

311. Numa primeira avaliação, foi feita uma simulação dos retornos diários acumulados, excluindo-se da base de dados os resultados observados nos pregões imediatamente subsequentes à data de divulgação de cada Fato Relevante.

312. A linha de cima do gráfico representa o comportamento da OGXP3 entre 02.01.2009 (base 100) e 30.04.2012. A linha de baixo representa o comportamento da mesma ação no mesmo período, quando desconsiderados os pregões seguinte aos 54 fatos relevantes:



313. Os retornos acumulados contando com o efeito dos fatos relevantes totalizaram um valor positivo de 159,4%. Sem eles, o retorno acumulado teria sido de 20,60% – mais de 87% do ganho líquido do papel OGXP3 no período observado nos dias seguintes.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

314. Caso a hipótese de atribuir um retorno de 0% a esses pregões desconsiderasse o efeito do mercado, poder-se-ia substituir o retorno desses dias pelo retorno do IBOV. O resultado obtido foi representando pela linha intermediária do gráfico a seguir:



315. Nessa segunda hipótese, o papel OGXP3 acumulou um retorno positivo de 49,76% no período, bem inferior aos 159,41% obtidos após a divulgação de todos os 54 fatos relevantes.

316. Os retornos diários ocorridos nos pregões subsequentes à divulgação de fatos relevantes totalizaram a maior parte da valorização do papel OGXP3 no período.

317. A GMA-2 também elaborou análise do tipo Estudo de Eventos (no caso, as 54 divulgações de fatos relevantes). Os resultados foram reunidos na tabela a seguir reproduzida:

Estatística de teste	2,9338141
Valor limite (5%)	1,6448536
Conclusão	Rejeitar a hipótese nula
Valor-p	0,167412%

318. Chegou-se à conclusão de que utilizando (i) janela amostral de retornos de 120 pregões; (ii) IBOV como indicador de mercado; e (iii) valor de alfa (utilizado de forma unicaudal), teria havido efeito significativo associado aos pregões selecionados, tendo sido percebido neles um retorno anormal superior ao dos demais pregões e que não poderia ser atribuído a uma variação normal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IX.4 DAS MANIFESTAÇÕES

IX.4.1 MARCELO TORRES

319. Em 28.03.2018, Marcelo Torres enviou manifestação (fls. 3901-4117) tempestiva sobre as provas produzidas pela análise da SMI, na qual alegou que a diligência realizada não seria apta a explicar o comportamento das ações da OGX. O material mais adequado para isso seria o Parecer Tendências (fls. 3925-3953), que explicaria claramente os motivos por trás das movimentações dos papéis de emissão da Companhia.

320. Como teria ficado demonstrado pelo Parecer, as divulgações de 54 fatos relevantes indicados pela SEP não operariam de modo a inflar artificialmente os preços das ações da Companhia. Na verdade, mais de um terço desses fatos teriam produzido o resultado contrário e impactado negativamente tais preços.

321. O Parecer também teria mostrado que o comportamento desses papéis teria sido semelhante a relevantes índices do petróleo e seria natural que uma companhia que visasse exploração de petróleo tivesse os valores de suas ações impactados por fatores conjunturais do setor.

322. Mesmo acompanhando as trajetórias de índices de petróleo, as cotações da OGX ainda estariam significativamente abaixo das expectativas de relevantes analistas do mercado de capitais, tais como BTG Pactual, Goldman Sachs e Itaú BBA.

323. As ações teriam sido negociadas a preços ainda muito abaixo do que poderiam alcançar, evidenciando que, se houve otimismo nos fatos relevantes, este em nada teria contribuído para inflar os preços.

324. O acusado teria ficado impossibilitado de negociar as ações da OGX aos melhores preços alcançados em função de um *black out period* voluntariamente realizado por ele.

325. Marcelo Torres teria negociado apenas pequena parte das ações de que era titular. Em suas duas sequências de venda, ele teria alienado, nesta ordem, apenas 32,5% e 20,5% do que possuía. O acusado teria obtido lucro maior caso tivesse alienado suas ações antes de iniciado o esquema imaginado pela Acusação. Se houvesse vendido a mesma quantidade de ações que vendeu no dia em que foi publicado o primeiro dos 54 fatos relevantes, teria angariado R\$ 397.125,00 a mais do que efetivamente angariou.

326. Além disso, seria um equívoco da SMI tentar comparar os movimentos das ações da OGX com os do IBOV, tendo em vista que, devido às peculiaridades da Companhia e do setor econômico, qualquer análise parametrizada por aquele índice sofreria riscos de imprecisão.

327. Considerando a realidade da Companhia à época, as informações divulgadas seriam definitivamente relevantes, uma vez que não trariam inverdades e teriam ao menos o potencial de impactar as cotações das ações de sua emissão.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IX.4.2 PAULO MENDONÇA

328. Em 28.03.2018, Paulo Mendonça também apresentou manifestação (fls. 4118-4130) frente ao despacho da GMA-2 na qual alegou que dois elementos essenciais do tipo ilícito “manipulação” não teriam sido comprovados pelo relatório: a existência de informação falsa ou artifício e o objetivo (dolo) de alterar a cotação das ações.

329. Além disso, a análise dos fatos relevantes e dos relatórios de analistas de mercado (fls. 3181-3186) revelaria que as informações objetivas fornecidas sobre perfurações e descobertas de hidrocarbonetos e sobre o volume de recursos prospectivos riscados e não-riscados teriam sido adequadamente classificadas pelos analistas de acordo com o risco envolvido.

330. A prestação de informações objetivas não poderia ser considerada como indício de manipulação de mercado – até porque alguns fatos relevantes divulgados teriam resultado em queda da cotação das ações emitidas pela OGX. Seria razoável, então, concluir que o comportamento da cotação das ações tinha relação com as informações objetivas veiculadas, sem influência da redação adotada nos fatos relevantes.

331. Ademais, o relatório da SMI não teria utilizado a técnica mais adequada à hipótese vertente sob a ótica econométrica ou estatística, o que teria sido explicado na análise feita pelos professores da COPPEAD no estudo em anexo (fls. 4122-4129) à manifestação.

332. Não teria sido feita análise individual dos fatos relevantes. Quando observados individualmente, apenas seis em 54 apresentariam impacto positivo significativo, enquanto que os 48 restantes teriam apresentado impacto não significativo ou negativo.

333. O relatório teria utilizado a correlação entre a variação das ações da OGX frente ao Índice Ibovespa e concluído que qualquer oscilação das ações que não estivesse correlacionada à cotação do IBOV não seria natural – o que careceria de fundamentação técnica. A OGX estando em fase pré-operacional carregaria um risco muito superior ao risco médio das demais companhias que compunham o IBOV.

X. DOS ATOS POSTERIORES

334. Em 18.09.2018, por meio de manifestação, a procuradora de Paulo Guimarães comunicou que o acusado havia falecido e requereu a extinção de punibilidade no âmbito do presente processo em relação às responsabilidades imputadas a ele. Em 07.02.2019 foi anexada a certidão de óbito correspondente (fls. 4141).

335. Em 30.04.2019, o Colegiado, acompanhando despacho do Diretor Relator, indeferiu pedido formulado por Paulo Mendonça consistente na juntada de informações que teriam subsidiado a divulgação dos fatos relevantes entre 2009 e 2012 constantes do Processo CVM nº 2013/7307, que contempla mais de 6.000 folhas (fls. 4.118; 3.140-3.141).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

336. Sobre o pedido, foi destacado na decisão que a SEP não afirma ser inverídico o teor dos fatos relevantes, mas irrelevantes e excessivamente otimistas. Deste modo, o objetivo do pedido de juntada de documentos apresentado por Paulo Mendonça, a saber, a veracidade das informações divulgadas à época pela administração da OGX, não é objeto de controvérsia do presente processo, razão pela qual foi indeferido o pedido.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/6517

Reg. Col. nº 9468/2014

Acusados: Eike Fuhrken Batista
José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
Marcelo Faber Torres
Paulo Manuel Mendes de Mendonça
Paulo de Tarso Martins Guimarães
Reinaldo José Belotti Vargas
Roberto Bernardes Monteiro

Assunto: Divulgação de fatos relevantes como instrumento de manipulação de preços das ações da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. Divulgação de fato relevante com omissão material induzindo investidores a erro. Infração ao inciso I, na forma prevista pelo item II, "b", da Instrução CVM nº 08/79. Infração ao artigo 153 da Lei 6.404/76 combinado com o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/09.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

I. OBJETO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador **instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas** ("SEP" ou "Acusação") em face de Eike Fuhrken Batista ("Eike Batista"), José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti ("José Cavalcanti"), Luiz Eduardo Guimarães Carneiro ("Luiz Carneiro"), Marcelo Faber Torres ("Marcelo Torres"), Paulo Manuel Mendes de Mendonça ("Paulo Mendonça"), Paulo de Tarso Martins Guimarães ("Paulo Guimarães"), Reinaldo José Belotti Vargas ("Reinaldo Vargas") e Roberto Bernardes Monteiro ("Roberto Monteiro") (em conjunto "Acusados"), na qualidade de administradores da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. ("OGX" ou "Companhia"), para apurar irregularidades relacionadas à divulgação de fatos relevantes que teriam servido para manipular os preços das ações da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Companhia entre 2009 e 2012, prática vedada no inciso I e definida no inciso II, “b”, da Instrução CVM nº 08, de 08 de outubro de 1979¹.

2. Apura-se também a responsabilidade dos administradores pela divulgação, em 13.03.2013, de aviso de fato relevante com omissão material sobre os negócios da Companhia, em infração aos arts. 153 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976², e 14 da Instrução CVM nº 480, de 2002³.

II. INTRODUÇÃO

3. Antes de iniciar a análise do mérito, entendo conveniente trazer um breve histórico do contexto fático que será objeto de análise neste processo.

4. A OGX iniciou suas atividades em 2007, tendo adquirido, nesse mesmo ano, diversas áreas exploratórias de petróleo e gás natural, em especial o bloco BM-C-41, na Bacia de Campos, no qual situavam-se, na parcela sul, as acumulações (reservas de petróleo) inicialmente chamadas de *Pipeline*, *Fuji* e *Illimani*, que posteriormente resultaram nos campos de Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia (“Campos”).

5. Entre 02.10.2009 a 26.04.2012, a OGX fez uma série de divulgações sobre a presença de indícios de hidrocarbonetos nos poços exploratórios que estavam sendo perfurados, tendo publicado mais de 50 avisos de fato relevante sobre o tema. Acerca da acumulação de Pipeline, a SEP ressaltou algumas divulgações (fls. 446-503):

a) em 16.12.2009, a Companhia informou a descoberta de óleo durante a perfuração do poço OGX-2, com volume de óleo recuperável estimado entre 400 a 500 milhões de barris;

b) em 22.12.2009, a Companhia divulgou nova estimativa do volume de óleo recuperável do poço OGX-2 entre 1 e 2 bilhões de barris;

c) em 13.05.2010, ao divulgar a conclusão da perfuração dos poços OGX-6 e OGX-8, a Companhia comunicou também que identificou a conectividade entre os poços OGX-2A e OGX-6 (*Pipeline* e *Etna*),

¹ I. É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II. Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;

² Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

³ Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

tratando-se de uma mesma acumulação com volume total de óleo recuperável estimado de 1,4 a 2,6 bilhões de barris;

d) em 15.07.2011, no que se refere ao poço OGX-39HP, Pipeline horizontal, a Companhia divulgou (i) a conclusão da perfuração; (ii) o resultado indicando capacidade de produção de 10.000 barris por dia de óleo e (iii) identificação de boas condições de reservatório.

6. Em relação às acumulações Fuji e Illimani, a área técnica fez evidenciar as seguintes referências:

a) em 24.03.2010 e 31.03.2010, foram divulgadas detecções de hidrocarbonetos durante a perfuração do poço OGX-8 cuja acumulação foi denominada Fuji (fls. 57-58);

b) em 15.05.2010, foi divulgada a (i) conclusão da perfuração do poço OGX-8 e (ii) a necessidade de novos dados para verificar se estavam “diante de uma mesma acumulação” referente à conectividade entre os poços OGX-3 e OGX-8 (fls.51);

c) em 24.01.2011, foi divulgada a presença de hidrocarbonetos na perfuração do poço 1-OGX-28D-RJS, cuja acumulação foi denominada Illimani (fls. 59).

7. Ainda sobre as publicações, a SEP destacou que em 38 dos fatos relevantes Paulo Mendonça fez comentários pessoais a respeito das descobertas, frisando os seguintes trechos (fls. 2.162 a 2.165) [grifos do original]:

a) em 07.10.2009: “OGX-1 representa o começo de uma campanha exploratória **altamente promissora**”;

b) em 30.11.2009: “a identificação de uma expressiva coluna com hidrocarbonetos em reservatórios de alta qualidade na seção do Albiano **superou nossas expectativas**”;

c) em 05.03.2010: “a província recentemente descoberta se estende também até o norte do bloco BM-C-41, ratificando o seu **importantíssimo potencial petrolífero**”;

d) em 12.04.2010: “[o poço] vem confirmar o **grande potencial** desta bacia em diversas idades geológicas, abrindo, portanto, uma **expressiva frente de novas possibilidades** para estes reservatórios”;

e) em 11.08.2010: “o que sinaliza para uma coluna **potencialmente superior** à já encontrada neste bloco. Esse resultado **reforça a atratividade desta região** mais ao norte da bacia de Campos, que pode



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

*representar **uma nova província de grande importância** para a nossa Companhia”;*

8. Diante disso, e considerando outros fatos e circunstâncias que serão amiúde analisados neste voto, a SEP concluiu que a divulgação de diversos fatos relevantes com comentários destacadamente otimistas, cujo conteúdo não seria relevante, configuraria conduta compatível com a prática ilícita de manipulação de preços.

9. Em 2011, os resultados dos poços exploratórios e dos testes de formação realizados nos referidos Campos já indicavam possível compartimentação diferente da prevista inicialmente, evidenciada notadamente pelos contatos óleo-água e pelas diferentes propriedades de óleo encontradas nos poços. Naquele momento, a gerência executiva de reservatórios da OGX (“Área de Reservatórios”) já sinalizava volumes de óleo e gás muito diferentes da interpretação inicial divulgada ao mercado (fls. 88).

10. Em meados de 2012, a Companhia decidiu realizar uma grande revisão dos volumes e reservas existentes nos reservatórios da OGX, bem como das suas perspectivas de produção, dado o cenário de risco identificado pela Área de Reservatórios. Nessa linha, em 24.07.2012, a Companhia formou um Grupo de Trabalho (“GT” ou Grupo de Trabalho”) com profissionais das áreas de exploração e de reservatórios da OGX e da empresa Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda. (“Schlumberger”), que, no dia 24.09.2012, realizou uma apresentação à diretoria executiva da Companhia com as seguintes conclusões (fls. 100 a 247):

- a) volume *in situ* de 676 milhões de barris de óleo equivalentes (boe) e de volume recuperável entre 49,5 milhões de boe (*cenário base*) e 77,7 milhões de boe (*cenário otimista*) para as acumulações; e
- b) para qualquer dos cenários traçados (base ou otimista), o valor presente líquido (“VPL”) ⁴ para a exploração dos Campos era negativo.

11. Outro problema apontado pelo GT para o desenvolvimento dos Campos estaria relacionado à necessidade de desenvolver unidade de produção capaz de tratar o gás contaminante sulfeto de hidrogênio encontrado nos reservatórios.

12. A análise feita pelo GT confirmou o modelo concebido pela Área de Reservatório da OGX, o que reduziu sobremaneira o volume *in place* total de óleo dos Campos para a faixa de 700 milhões de barris. Associada à redução do volume, o GT destacou ainda relevante redução do fator de recuperação, o que resultou num volume recuperável de 80 milhões de barris no caso mais otimista e 50 milhões no mais provável.

13. Além dos baixos volumes recuperáveis, o GT ressaltou que o projeto de exploração precisaria realizar a perfuração de 12 poços horizontais, com produção coletada e processada numa unidade de produção denominada WCPP, muito diferente da WHP-1 projetada para a área, bem

⁴ Método utilizado para determinar a viabilidade de um investimento em certo período de tempo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

como de um *Floating Production Storage and Offloading* (“FPSO”) para receber o óleo já descontaminado para o processamento final. Essas especificidades encontradas no projeto elevaram sobremaneira os custos de produção de petróleo na área, tendo o GT concluído pela inviabilidade econômica da exploração dos Campos.

14. Em fevereiro de 2013, a empresa Rameshini Associates Technology & Engineering, LLC (“RATE”), contratada pela OGX, entregou estudo afirmando que o projeto da OGX para solucionar o alto teor de gás contaminante (H₂S) nos Campos resultou em equipamentos de grandes dimensões e elevados custos, tendo sugerido à Companhia que avaliasse outras tecnologias para monetizar o projeto (fls. 97-100).

15. Importante registrar que, ainda que o projeto de desenvolvimento dos Campos fosse viável, a OGX externou a grande dificuldade de obter licenças para o seu desenvolvimento em função dos altos teores de gás contaminante encontrados nos poços e, por conseguinte, do alto risco para os trabalhadores e para o meio ambiente (fls. 292-309).

16. Em março de 2013, a empresa CGG Brasil realizou o reprocessamento da sísmica dos reservatórios da OGX com dados mais precisos sobre as características da área, notadamente o comportamento dos poços produtores de Tubarão Azul. A elaboração do novo modelo de reservatório evidenciou a intensa compartimentalização e descontinuidade dos reservatórios dos Campos (fls. 246-266).

17. Em 13.03.2013, a OGX divulgou fato relevante no qual informou que submeteu à ANP a declaração de comercialidade das acumulações *Pipeline*, *Fuji* e *Ilimani*, tendo informado uma estimativa de volume *in situ* total de 521 mmboe (P90), 823 mmboe (P50) e 1339 mmboe (P10). Com relação ao conteúdo desse comunicado, a área técnica concluiu que os administradores teriam induzido a erro os investidores ao publicar fato relevante que informava a entrega à ANP da declaração de viabilidade dos Campos sem alertar que a viabilidade ainda era objeto de grandes incertezas, conduta que violaria os deveres de cuidado e diligência estabelecidos na lei societária.

18. Em 01.07.2013, a OGX divulgou fato relevante informando não dispor de tecnologia capaz de tornar economicamente viável o desenvolvimento dos referidos Campos (fls. 37-43).

19. Em 06.09.2013, a OGX informou ao mercado que exerceu o direito de exigir do acionista controlador Eike Batista a subscrição de R\$100 milhões de novas ações ao preço de exercício de R\$6,30, nos termos do contrato de opção (“PUT”) firmado por Eike Batista. No mesmo dia, Eike Batista notificou a Companhia de que pretendia discutir a validade do exercício da PUT, em função da alteração do plano de negócios, o que o eximiria da obrigação contratual de aportar recursos, informação tornada pública pela Companhia em 09.09.2013 (fls. 406-409).

20. Em 30.10.2013, a OGX ajuizou pedido de recuperação judicial em vista de sua situação financeira desfavorável, dos prejuízos acumulados e do vencimento de grande parte de seu endividamento. E, em 24.12.2013, o acionista controlador, os detentores de títulos de dívida em face da Companhia e a OSX firmaram acordo para a reestruturação da OGX (fls. 423-426).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

III. DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES SUPOSTAMENTE INFRINGIDOS

III.1. MANIPULAÇÃO DE PREÇOS

21. Trazida a moldura fática, verifica-se que o presente processo apura se administradores teriam induzido acionistas e investidores a comprar ações da OGX por meio da inserção de comentários excessivamente otimistas nos avisos de fato relevante relativos à descoberta de indícios de hidrocarbonetos que, no sentir da área técnica, não seriam relevantes, para, com isso, influenciar indevidamente a cotação das ações da Companhia. Tal comportamento seria vedado pelo item I, definido no Item II, “b”, da Instrução CVM nº 08/79, conforme a seguir reproduzido:

I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.

II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:

(...)

b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários, a utilização de qualquer processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda.

22. O tipo administrativo requer a presença de três elementos: (i) a utilização de qualquer processo ou artifício; (ii) que o processo ou artifício tenha o objetivo de alterar a cotação de um valor mobiliário; e (iii) **que terceiros sejam por ele induzidos à negociação**. Trata-se, assim, de ilícito doloso em que o agente comete ato consciente e intencional de alterar o processo de formação de preço do valor mobiliário no mercado⁵.

23. A norma em comento foi editada de forma propositadamente genérica⁶ (“*utilização de qualquer processo ou artifício*”), delito de ampla abrangência de condutas, visando especificamente dar maior flexibilidade à atuação da CVM em face das inúmeras estratégias

⁵ Neste particular, menciono voto do Diretor Marcelo Trindade no PAS CVM SP nº 2001/0236, julgado na reunião de Colegiado de 02.04.02: “Quanto à definição de dolo para efeito da prática de manipulação, afirma o prof. Richard Friedman, em artigo publicado na Michigan Law Review, que a pergunta a ser feita é a seguinte: (...) (A atividade do agente foi decisivamente motivada pela expectativa de que essa atividade afetaria a cotação, no sentido de que, se não fosse por essa expectativa, ele não teria adotado a conduta?) (Michigan Law Review, vol. 89, Outubro de 1990, p. 35).

⁶ A opção da CVM por tipo abertos restou consignada na Nota Explicativa CVM nº 14/79: “entendeu a CVM conveniente adotar a segunda solução, ampliando, a vista da experiência já acumulada, o alcance dos dispositivos já constantes da Resolução nº 39, e conceituando de forma propositadamente genérica, situações que configuram operações ou práticas incompatíveis com a regularidade que se pretende assegurar ao mercado de valores mobiliários. Dentro dessa ótica é baixada pela CVM a INSTRUÇÃO Nº 08/79, que explicita serem vedadas a todos os participantes do mercado a criação de condições artificiais na negociação de valores mobiliários, a manipulação de preço, as operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

possíveis de serem praticadas pelos agentes visando à distorção da regular precificação dos valores mobiliários admitidos à negociação.

24. Como já tive a oportunidade de asseverar em precedente⁷ desta Comissão, os tipos administrativos contidos na Instrução CVM nº 08/79 são propositalmente abertos e destinados a conferir flexibilidade à autoridade supervisora do mercado, sem prejuízo de sua coercibilidade face à diversidade de situações possíveis em um mercado em constante evolução. É da essência desses tipos administrativos que eles possam se moldar às circunstâncias que permeiam a conduta investigada, sob pena de esvaziamento de seu comando normativo.

25. A regulação buscou, assim, preservar de forma ampla o mercado secundário de interferências indevidas passíveis de afetar a formação justa de preços, representada pela vontade legítima dos compradores e vendedores de nele transacionar⁸, dada a destacada importância econômica do mercado secundário para prover liquidez às emissões primárias, quando ocorre a efetiva transferência de recursos da poupança popular para o capital social das companhias.

26. A par da relevância do regular funcionamento e da credibilidade do mercado de capitais para o desenvolvimento econômico do país, o legislador pátrio decidiu, posteriormente, criminalizar certas condutas indesejadas praticadas nesse ambiente. Desse modo, por meio da edição da Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, cuja redação foi recentemente alterada pela Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, além do uso indevido de informação privilegiada, a prática de manipulação do mercado também foi inserida no rol de crimes contra o mercado de capitais da Lei nº 6.385/76, *in verbis*:

Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas destinadas a elevar, manter ou baixar a cotação, o preço ou o volume negociado de um valor mobiliário, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros: Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.

III.2. DEVER DE DILIGÊNCIA

27. O presente processo apura ainda se os administradores da OGX agiram com o cuidado e a diligência esperados às circunstâncias ao concordarem com a divulgação (i) de fatos relevantes que teriam servido para manipular o preço das ações da Companhia; e (ii) de fato relevante que teria sido omissos em relação às incertezas sobre a inviabilidade econômica dos Campos, em desacordo com o padrão de conduta exigido pelo art. 153 da Lei nº 6.404/76, *in verbis*:

⁷ PAS CVM nº RJ 2016-7192, j. 13.03.18.

⁸ Neste particular, oportuna a citação da doutrina de Nelson Eizirik: “Nos dois ilícitos administrativos – criação de condições artificiais e manipulação – o bem jurídico protegido é o mesmo: a regularidade e transparência do mercado de valores mobiliários, assegurando que o processo de formação de preços seja regido pela oferta e demanda”. EIZIRIK, Nelson ET al. *Mercado de Capitais Regime Jurídico*. 3ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 547-548.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

28. A lei societária adotou neste dispositivo padrão de conduta com conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais mediante modelo abstrato de conduta, a fim de ser possível aplicá-lo às mais diversas situações do dia a dia empresarial, independentemente do tamanho das companhias – pequenas, médias ou grandes – e dos negócios a elas relacionados – simples ou complexos. O legislador adotou, com isso, padrão de conduta que melhor se ajustasse à realidade das companhias nacionais e em linha com as legislações dos países desenvolvidos⁹.

29. Em seu conteúdo específico, o dever de diligência impõe aos administradores de companhia aberta o emprego do cuidado que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, exigindo-se, com isso, capacidade profissional com caráter técnico. Por se tratar de responsabilidade profissional, a figura do *bonus pater familias* que age com zelo e cuidado não é suficiente para respaldar a atuação do administrador¹⁰.

30. E essa diferenciação é bastante relevante, uma vez que o modelo teórico adotado pelo código civil remete a uma pessoa conservadora, preocupada na manutenção do seu patrimônio, incompatível, por isso, com a atividade empresarial, que exige, necessariamente, a antecipação de diversos fatores econômicos e de produção que estão sujeitos a riscos e a incertezas. Como se sabe, o risco é essência da atividade empresarial, razão pela qual não se pode invocar violação ao dever de diligência em razão da simples assunção de riscos na tomada de decisão, sob pena de desestimular indevidamente a função lucrativa da companhia, cujo objeto está consagrado no art. 2º da Lei 6.404/76.

31. Por outro lado, ao utilizar os recursos entregues pelos acionistas à companhia, o administrador deve deles dispor de maneira racional e justificada, tomando decisões técnicas respaldadas em informações relevantes disponíveis. Para avaliar esse processo decisório e instrumentalizar os comportamentos esperados, a doutrina decompôs o dever de diligência em múltiplos aspectos¹¹.

32. A aplicação da norma contida no referido artigo 153 pressupõe, assim, estabelecer qual comportamento que se poderia razoavelmente esperar do administrador em situações semelhantes¹², cuja concretude se reflete, entre outros aspectos, na busca por informações

⁹ LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coord.), Direito das Companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2ª edição, p. 800.

¹⁰ PARENTE, Flávia. *O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas*. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 102-107.

¹¹ Neste sentido, Flávia Parente cita cinco deveres específicos que se desdobram do dever de diligência: o dever de se qualificar para o cargo, o dever de bem administrar, o dever de se informar, o dever de investigar e o dever de vigiar. PARENTE, Flávia. *O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas*. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 102-107.

¹² Adamek, Marcelo Vieira von. “*Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as Ações Correlatas*”. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 125-126.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

necessárias e relevantes para respaldar uma decisão instruída, refletida e tomada no melhor interesse lucrativo da companhia.

33. Nessa análise, deverá o julgador examinar as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto para asseverar a regularidade ou não da conduta adotada pelo administrador, considerando o tamanho da companhia e seu objeto social, as funções genéricas e específicas de cada administrador estabelecidas no estatuto social, a complexidade das operações e transações realizadas, bem como quaisquer outras informações capazes de influenciar concretamente a condução dos negócios sociais pelo administrador.

34. Feitas essas breves considerações sobre os ilícitos em tese, passo a examinar a materialidade e autoria das irregularidades descritas no presente processo, na mesma ordem apresentada pela Acusação. Antes, examinarei as preliminares suscitadas pelos Acusados, como se segue.

IV. PRELIMINARES

IV.1 EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

35. Preliminarmente, em relação ao acusado Paulo de Tarso Martins Guimarães, cabe reconhecer a extinção da punibilidade¹³ no âmbito deste processo em relação às responsabilidades a ele imputadas, em razão do falecimento do acusado ocorrido em 07.09.2018, conforme certidão de óbito constante das fls. 4.141.

IV.2 AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL

36. Em sede preliminar, Marcelo Torres alegou que a Acusação teria sido formulada sem que ele fosse chamado para prestar depoimento pessoal, o que, caso tivesse acontecido, poderia ter evitado que se formasse uma visão distorcida dos fatos. Sobre o assunto, traz parecer¹⁴ no sentido de que “*não se pode[ria] dissimular a surpresa com o fato de ter sido produzida uma acusação de manipulação de preços sem que os depoimentos dos acusados e de outros diretores tenham sido tomados (...)*”.

37. Diante disso, e em razão dos questionamentos feitos pela SEP terem sido limitados, uma vez que a manifestação dos acusados teria que se resumir a responder, objetivamente, as restritas indagações a eles direcionadas, Marcelo Torres solicitou o arquivamento do processo sem julgamento de mérito. A defesa entende que a acusação não garantiu ao acusado a prerrogativa da autodefesa, que não poderia ser substituída por pedidos de esclarecimento, a violar o direito constitucional de ampla defesa.

38. Tal argumentação não merece prosperar.

¹³ Com base no disposto nos arts. 107, I, do Código Penal, art. 52 da Lei nº 9.784/99 c/c art. 27 da Deliberação CVM nº 538/08.

¹⁴ Parecer emitido por Marcelo Trindade apenso às fls. 2.806-2.836.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

39. Como se sabe, não se confundem as fases investigativa, em que está inserida a possibilidade de manifestação prévia do investigado, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/08, e sancionadora, que se inicia com a instauração do processo sancionador a partir da citação do acusado para apresentar defesa (art. 8º, §1º).

40. Durante a investigação, cabe à CVM diligenciar no sentido de obter dos investigados esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório de inquérito ou no termo de acusação, tratando-se, como já decidiu o Colegiado em diversas ocasiões¹⁵. Trata-se de medida de eficiência administrativa que tem por finalidade dar suporte, com os recursos disponíveis, à formação da convicção da área técnica quanto à materialidade e a autoria das infrações, não se configurando, portanto, em direito subjetivo do acusado.

41. Nesse sentido, ao tratar da manifestação preliminar do acusado, a norma não especifica a forma pela qual os esclarecimentos serão obtidos, cabendo à acusação definir o meio mais adequado, sendo aceitas as mais diversas formas possíveis de obter esclarecimentos sobre os fatos investigados¹⁶.

42. No caso concreto, Marcelo Torres foi intimado a prestar esclarecimentos por correspondência na fase investigativa (fls. 1.379-1.384), conforme regras previstas na Deliberação CVM nº 538/08. A legalidade formal do procedimento acusatório foi objeto de parecer afirmativo pela Procuradoria Federal Especializada – PFE (fls. 2.221-2.228).

43. Acrescento que o acusado teve acesso integral aos autos e apresentou sua correspondente defesa, na qual teve a oportunidade de contestar minuciosamente todas as provas e argumentos produzidos contra ele pela SEP (fls. 2.721-2.936). Além disso, deferi o seu pedido de produção de prova consistente no exame do comportamento das ações da OGX no período destacado pela Acusação, cujo resultado o acusado pôde novamente aduzir razões, a demonstrar que lhe foi dada ampla oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

¹⁵ Ver PAS RJ nº 2006/8572, j. em 16.03.2010; e PAS RJ nº 2008/4857, j. em 23.08.2011.

¹⁶ Neste sentido, ver a decisão proferida no âmbito do Processo 10372.100321/2018-76, pelo Conselheiro Relator Antonio Augusto de Sá Freire Filho, integrante do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que, ao analisar a matéria, consignou o seguinte: “11. *Conforme se vê nos autos, a CVM, com base nas informações inicialmente obtidas, decidiu diligenciar para obter as manifestações dos Acusados sobre os negócios considerados suspeitos, para os fins previstos no art. 11 da Deliberação CVM n 538/2008. 12. A orientação emanada da sua norma interna foi plenamente cumprida pelos servidores da CVM, não havendo nada na conduta deles que afete a higidez do processo. A referida norma não impõe forma estrita de realização da manifestação dos investigados e não se pode negar validade a nenhuma das diversas formas de oitiva existentes no mundo moderno – depoimento presencial, por carta, por videoconferência, por mensagem eletrônica, por meio telefônico, etc.(...)* 14. *Em reforço, rememoro que a doutrina e a jurisprudência sempre foram no sentido de impossibilidade de decretação de nulidade processual quando não provado, de forma irrefutável, o prejuízo substancial sofrido pela parte.*” [grifou-se]

:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

44. Por todas essas razões, e na ausência de prejuízo material sofrido pelo acusado, não há de se falar em nulidade processual, motivo pelo qual não acolho a preliminar suscitada.

IV.2 AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

45. Luiz Carneiro e Paulo Guimarães alegaram que a ausência de individualização de responsabilidade violaria o ordenamento jurídico ao promover responsabilização objetiva dos administradores da OGX (fls. 2.467-2.538).

46. Na mesma direção, José Cavalcanti alegou que sua autoria imprudente ou negligente acerca dos fatos apurados neste processo não teria sido provada pela SEP. Segundo alega, a Acusação teria apenas caracterizado a coautoria a todos aqueles a quem não imputou prática direta de irregularidade (fls. 2.376-2.466).

47. Reinaldo Vargas apresentou defesa na qual também alegou a necessária delimitação de competência dos administradores, já que, na condição de diretor de produção, suas atividades nada diriam respeito à comunicação de informação da OGX com o mercado. Acrescentou que a acusação de que ele não teria agido com cuidado e diligência ao manifestar concordância com as divulgações seria genérica e levaria à anulação da Acusação, na medida em que não comprovaria a participação efetiva do acusado nas práticas irregulares, a considerar a responsabilidade do acusado de forma objetiva, o que não é aceitável à luz da legislação (fls. 2.539-2.664).

48. Trazidas essas alegações, entendo que a Acusação, ao contrário do que alegam os acusados em suas defesas, traz elementos que permitem individualizar a conduta de cada um e lhes dar plena ciência das infrações imputadas.

49. Com efeito, a Acusação buscou demonstrar a existência do elemento volitivo caracterizado pelo dolo da conduta relacionada à manipulação de preços mediante a avaliação individual e concreta das negociações com ações realizadas por Marcelo Torres e Paulo Mendonça. Para os demais, ao reunir elementos referentes à participação deles na elaboração dos fatos relevantes considerados inadequados, e por se tratar de conduta culposa não compatível com o ilícito de manipulação, a SEP imputou responsabilidade por falta de diligência.

50. Na segunda acusação formulada pela SEP, embora tenha concluído que a divulgação do fato relevante de 13.03.2013 teria sido igualmente inapropriada, com omissão material de informação relevante, a Acusação entendeu que ela não teria servido de instrumento de manipulação de preços, mas passível de induzir os investidores a erro, motivo pelo qual imputou responsabilidade específica ao diretor de relações com investidores por infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09.

51. Sobre este mesmo fato, por entender que o mecanismo de elaboração das divulgações da OGX envolvia outros diretores e que haveria prova da ciência deles quanto ao conteúdo relevante não divulgado, estes diretores teriam concordado com a omissão de tal divulgação, sem,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

deste modo, terem empregado o cuidado e a diligência exigidos às circunstâncias pela legislação aplicável.

52. Como se observa, foram, portanto, devidamente individualizadas as condutas com a correlação entre os fatos apurados e o tipo administrativo infringido. Dessa forma, afasto também esta preliminar e passo a examinar as questões de mérito.

V. MÉRITO

V.1 MANIPULAÇÃO DE PREÇO

53. Segundo consta da peça acusatória, Paulo Mendonça, diretor de exploração, e Marcelo Torres, diretor de relações com investidores, teriam publicado entre 2009 e 2012 excessivo número de avisos de fato relevante sobre descobertas de indícios de hidrocarbonetos, cujo conteúdo não poderia ser considerado relevante à luz da legislação vigente, por ser apenas uma etapa do longo e custoso processo entre a prospecção e o desenvolvimento de um campo petrolífero.

54. Diante disso, e considerando que a Petrobras S/A divulgaria suas descobertas ao final da perfuração e, ainda assim, por meio de comunicado ao mercado, a Acusação concluiu que a mera notificação de descoberta de hidrocarboneto à ANP não constituiria informação relevante nos termos do art. 2º da Instrução CVM nº 358/02.

55. Ademais, a SEP entendeu que referidos administradores teriam acrescentado comentários demasiadamente otimistas sobre as descobertas realizadas e, ao mesmo tempo, não teriam advertido adequadamente os investidores sobre os riscos e as incertezas existentes entre aquele momento - de descoberta do indício de hidrocarboneto – e a efetiva extração lucrativa do óleo e gás dos Campos, uma vez que tais incertezas teriam sido descritas sem destaque, em notas de rodapé.

56. Em auxílio a sua tese, a Acusação buscou demonstrar a mácula da conduta dos acusados ao consignar que, depois dessas inadequadas divulgações, Paulo Mendonça e Marcelo Torres teriam alienado conjuntamente milhões em ações da Companhia, o que demonstraria a intenção dolosa deles de se beneficiar do aumento artificial da cotação das ações da OGX, em violação às regras contidas na Instrução CVM nº 08/79.

57. Nesse contexto, a SEP também concluiu que, por terem manifestado concordância com aquelas inadequadas divulgações, José Cavalcanti, diretor jurídico, Reinaldo Vargas, diretor de produção, e Eike Batista, diretor presidente, teriam descumprido o dever de diligência exigido às circunstâncias pelo art. 153 da Lei nº 6.404/76.

58. Em contraposição ao alegado pela área técnica, os acusados aduziram que o padrão de divulgação adotado pela OGX não seria ilegal ou violador de norma regulamentar, na medida em que os avisos de fato relevante teriam trazido divulgações obrigatórias, conforme estabelece a Instrução CVM nº 358/02.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

59. Quanto ao conteúdo dos fatos relevantes, argumentaram que este corresponderia à realidade dos fatos, que, por sua vez, teriam sido embasados em dados respaldados por relatórios técnicos emitidos por companhias especializadas do setor. Aduziram que, para qualquer sociedade petrolífera que estivesse em estágio pré-operacional, a ocorrência de uma descoberta na área explorada representaria um evento importante e animador, o que justificaria sua comunicação ao mercado, bem como, na visão de Paulo Mendonça, o tom otimista adotado quando da transmissão dele.

60. Afirmaram que, diferentemente do que alega a SEP, as publicações teriam sido acompanhadas de alertas adequados quanto aos riscos e incertezas inerentes às atividades operacionais desenvolvidas pela Companhia, e que a quantidade de fatos relevantes divulgados a respeito de novas descobertas de indícios de hidrocarbonetos seria proporcional à intensa atividade exploratória da Companhia naquele período, incomparável com as demais companhias do setor de óleo e gás.

61. Ao examinar a extensa documentação produzida neste processo e os principais argumentos apresentados, impõe-se afirmar, desde logo, que a Acusação não conseguiu reunir elementos suficientemente aptos a comprovar a sua tese de manipulação de preços.

62. Dentro da reconstrução dos fatos contidos neste processo, é possível identificar com clareza dois momentos diametralmente opostos experimentados pela OGX ao longo de seu ciclo de vida, distinção esta que tem importância para melhor compreender e, assim, examinar as condutas dos administradores neste caso e no que se seguirá adiante.

63. O primeiro começa em 2007 com a aquisição por meio de licitação do bloco BMC-41, situado na Bacia de Campos, e prossegue com a abertura do capital. Avança com o início da campanha exploratória, a perfuração de poços pioneiros, a descoberta de indícios de hidrocarbonetos e as divulgações dos fatos relevantes, encerrando-se pouco depois do início da produção, em 09.05.2012, do campo de Tubarão Azul.

64. Já o segundo período tem marco inaugural na decisão da administração de, pouco tempo depois do início da produção de Tubarão Azul, realizar uma grande revisão dos volumes e reservas existentes nos reservatórios da OGX, com a transferência da área de reservatórios, antes subalterna à diretoria de exploração, para a presidência da Companhia, em junho de 2012, dada as divergências internas quanto às estimativas de produção. Segue com a criação do GT, em 24.07.2012, que indica a inviabilidade econômica dos Campos, sendo posteriormente confirmada e divulgada ao mercado em 01.07.2013. E termina, em 24.12.2013, com o acordo para a reestruturação da OGX e a aprovação do plano de recuperação judicial.

65. Nessa sumária separação temporal, marcada por circunstâncias claramente antagônicas, verifica-se que no primeiro momento havia clima de confiança por parte da administração e do próprio mercado de que a OGX seria muito bem-sucedida em sua campanha exploratória. E é nesse período que a acusação de manipulação de preços se situa, período no qual



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a OGX era uma companhia pré-operacional, sem dados sobre seu desempenho passado, sem receitas operacionais, com futuro indefinido e sujeita a diversas variáveis e incertezas, com elevado risco de precificação, baseado exclusivamente em estimativas da futura produção de óleo e gás.

66. Nesse contexto, antes do início da produção e da consequente geração de receitas operacionais, entendo não ser possível afirmar, com a convicção demonstrada pela SEP, que a descoberta dos indícios de hidrocarbonetos não poderia ser considerada uma informação relevante. Isso tem destaque porquanto a presente acusação passa inicialmente pela confirmação de que as informações divulgadas pela OGX sobre a presença desses elementos químicos nos poços pioneiros então perfurados não seriam relevantes e, por isso, não deveriam ter sido divulgadas por meio de fatos relevantes.

67. Como já tive oportunidade de destacar ao analisar o PAS CVM RJ2014/12710¹⁷, é consabido que prevalece no nosso ordenamento jurídico o princípio do *full disclosure*¹⁸, segundo o qual as companhias emissoras são obrigadas a dar total publicidade de atos e fatos que possam influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários ou na decisão dos investidores de negociar ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de tais ativos.

68. Como os investidores são livres para tomar suas decisões de investimentos, a lógica do sistema consiste no fornecimento de todas as informações relevantes e disponíveis pela companhia, de sorte a propiciar uma tomada de decisão bem informada, o que contribui para promover a integridade e a eficiência do mercado de capitais na medida em que os preços negociados irão refletir as legítimas expectativas dos investidores.

69. Tal princípio encontra esteio no dever de informar dos administradores previsto no §4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76¹⁹, que estabelece a obrigação de tornar público os fatos relevantes relacionados aos negócios da companhia.

70. Ao regulamentar tal obrigação na Instrução CVM nº 358/02, a CVM definiu o conceito de informação relevante como sendo aquela capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários emitidos pela companhia ou na decisão dos investidores de negociar com eles, apresentando hipóteses, para facilitar o trabalho de interpretação da norma pelos administradores,

¹⁷ Processo julgado em sessão realizada em 05.12.2017, em que se apurou eventual responsabilidade de Gelson da Silva Batista, na qualidade de diretor de relações com investidores e diretor presidente da CCX Carvão da Colômbia S.A., pelo suposto descumprimento ao parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02 c/c o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e art. 3º, caput e §5º, da Instrução CVM nº 358/02.

¹⁸ Ver PAS CVM nº RJ2008/12124, julgado em 22.06.10; PAS CVM nº RJ 2012/14871, julgado em 26.11.13; PAS CVM nº RJ2012/3787, julgado em 02.09.14, PAS CVM nº RJ 2011/14514, julgado em 30.04.13.

¹⁹ “Art. 157. (...) §4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de fatos que, dada a experiência da Comissão no trato do tema, têm alta probabilidade de influenciar nas decisões dos investidores, *in verbis*:

Art. 2º Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.

Parágrafo único. **Observada a definição do caput, são exemplos de ato ou fato potencialmente relevante, dentre outros, os seguintes:** I - assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da companhia, ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva; II - mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas; III - celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a companhia seja parte ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da companhia; (...); XIX - início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de produto ou da prestação de serviço; **XX - descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da companhia;** XXI - modificação de projeções divulgadas pela companhia; XXII – pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento de falência ou propositura de ação judicial, de procedimento administrativo ou arbitral que possa vir a afetar a situação econômico financeira da companhia. [grifou-se]

71. De acordo com o arcabouço regulatório, cabe à administração da companhia avaliar os potenciais impactos que uma informação pode causar no comportamento dos investidores, devendo, para isso, formular juízo prospectivo antes de decidir transmitir ao mercado sua percepção de que aquela informação é passível de alterar as projeções de retorno do capital investido na companhia.

72. A despeito de a CVM poder avaliar a adequação das divulgações realizadas pelas companhias, notadamente a qualidade da informação, o momento de sua divulgação, bem como a existência de erros e omissões, forçoso reconhecer que se trata de tarefa complexa e subjetiva para a qual o administrador encontra-se, por acompanhar e dirigir o dia a dia dos negócios sociais, em melhor posição do que esta Comissão para avaliar, no calor dos acontecimentos, o que tem potencial de ser ou não relevante para os investidores.

73. Diante disso, fato é que a conclusão da SEP vai contra a própria previsão expressa no parágrafo único, inciso XX, da Instrução CVM nº 358/02, que considera a descoberta de novos recursos circunstância potencialmente capaz de influir nas decisões dos investidores, e, por isso, merecedora de ampla divulgação pela companhia.

74. Além disso, os elementos dos autos não autorizam retirar razão do julgamento feito pela Companhia de que aquelas informações deveriam ser consideradas relevantes à luz (i) da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

realidade pré-operacional da OGX, em que a descoberta de indícios de hidrocarbonetos representaria a primeira etapa para a geração futura de caixa pela Companhia; e (ii) da exigência de informar à ANP as descobertas de indícios de hidrocarbonetos, que seriam divulgadas por meio do site da agência reguladora, a produzir indesejável assimetria informacional.

75. De fato, até que houvesse uma perspectiva mais consistente de geração de caixa decorrente da exploração e produção de óleo e gás pela OGX, que não dispunha de receitas operacionais naquele momento, não se pode desmerecer a importância de informações que apontassem na direção de tornar a Companhia capaz de gerar receitas advindas de seus ativos operacionais. Do mesmo modo, a existência de informações sobre a descoberta de indícios de hidrocarbonetos divulgados pela ANP, em razão da legislação que regula o setor, poderia provocar assimetria entre os investidores especialistas do setor, que acompanham as notícias daquela agência, e os demais investidores.

76. Sobre o tema, a defesa de Paulo Mendonça faz menção ao processo administrativo sancionador CVM nº RJ 2009/6713, por meio do qual a SEP, diferentemente do que prescreve neste processo, formulou acusação em face do diretor de relações com investidores da Petrobras S/A justamente por não ter divulgado fato relevante sobre a existência de novos indícios e estimativas de óleo num determinado campo, cujos indícios e estimativas iniciais já teriam sido objeto de divulgação de fato relevante, quando da transmissão da atualização à ANP e a investidores por meio de teleconferência, a demonstrar que tal questão pode ser sensível aos investidores e deve ser considerada pela companhia²⁰. Algumas questões ora analisadas também foram lá controvertidas, contudo, não houve decisão de mérito do referido processo em razão do seu encerramento por meio da celebração de termo de compromisso.

77. De todo modo, uma dessas questões referia-se ao fato de que as novas estimativas ainda estavam sendo avaliadas, não gozando, portanto, da certeza necessária para a sua divulgação via fato relevante. Neste particular, cabe registrar que a informação acerca de um projeto complexo, composto por múltiplas etapas, como ocorre com o desenvolvimento de um projeto de exploração de petróleo, pode ser relevante independentemente de já se ter certeza de sua viabilidade comercial, dado que as fases do seu desenvolvimento podem, evidentemente, constituir informação relevante para os investidores.

78. Afinal, não é razoável supor que estes investidores não poderiam ser influenciados de maneira ponderável pela descoberta de indícios de hidrocarbonetos e pelas estimativas desta decorrentes simplesmente por ser incerto o desenvolvimento viável da área onde o poço foi perfurado, notadamente porque as principais informações da OGX naquele estágio pré-operacional

²⁰ De acordo com o Parecer do Termo de Compromisso: “Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização do Sr. A.G.B., na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com investidores da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS pelo descumprimento ao disposto no §4º do art. 157 da Lei nº 6.404/76 [1], combinado com o § 3º do art. 3º da Instrução CVM nº 358/02, por não ter divulgado Fato Relevante sobre a existência de petróleo leve na segunda perfuração do campo de Tupi, no momento em que tal informação foi transmitida à ANP, em 08.08.07”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

referiam-se justamente às perspectivas e projeções advindas de estudos técnicos e das perfurações realizadas pela Companhia.

79. Nada obstante, outros indícios apontados pela SEP tampouco conseguem colocar em xeque a plausibilidade da decisão tomada pela administração da Companhia de publicar aquelas informações na forma de aviso de fato relevante.

80. Descarto, neste sentido, o fundamento utilizado pela SEP consistente na comparação entre o padrão de divulgação realizado pela OGX e o da Petrobras, bem como a conclusão que seguiu na peça acusatória de que, se “a Petrobras não considera uma descoberta de hidrocarbonetos relevante”, a OGX igualmente não deveria considerar tal circunstância relevante.

81. A despeito de as defesas terem demonstrado que tanto a Petrobras quanto outras companhias já teriam divulgado descoberta de indícios de hidrocarboneto através da publicação de fato relevante, o que seria suficiente para afastar tal alegação, tenho que determinada informação pode ser considerada relevante para uma companhia e não ser para outra do mesmo setor, eis que elas podem diferir quanto ao estágio de desenvolvimento, complexidade das operações, posição no mercado, capacidade de geração de receitas, nível de endividamento, dentre outros fatores.

82. A dinâmica de comparação feita pela SEP, além de não comprovar o que se pretendeu, porquanto as diferenças havidas entre a Petrobras e a OGX eram bastante evidentes, incorre em grave erro por buscar tornar objetiva a tarefa da administração de julgar a relevância de determinada informação mediante a adoção de padrão único de divulgação, observável, sem reflexão, por todas as companhias do mesmo setor econômico. Como se sabe, tal julgamento é prospectivo e notadamente subjetivo, dependente da avaliação da potencial influência que o fato, caso divulgado, causaria no comportamento dos investidores.

83. Não se quer com isso afirmar que o simples fato de a companhia divulgar determinada informação através de aviso de fato relevante transforma uma informação desimportante necessariamente em relevante, ou ainda que a decisão da companhia não possa ter sido equivocada à luz do que rege a legislação. Trata-se, em realidade, de um juízo de valor efetuado pela administração da companhia de que aquela informação é, no seu entendimento, relevante, o que, contudo, pode não corresponder a realidade, dada a possibilidade de tal avaliação não ter sido bem realizada, conforme as circunstâncias do caso concreto.

84. O que se afirma com segurança a partir dos fatos aqui reunidos é que as razões declinadas pelos administradores para publicar as descobertas por meio de aviso de fato relevante, tal como descritas anteriormente, aparentam ter sido objeto de ponderação e justificação técnica (fls. 1.440-1.445), sendo assim o comportamento que se poderia razoavelmente deles esperar, notadamente porque o pilar regulatório estabelecido na Instrução CVM nº 358/02 consiste



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

justamente na obrigatoriedade da total publicidade das informações consideradas relevantes pela companhia²¹.

85. Com efeito, dado o imperativo de conferir maior transparência aos negócios das companhias estabelecido na legislação de regência, estou convencido de que a ausência de divulgação de informação relevante causa destacado prejuízo ao mercado, pois permite a determinados agentes negociar em posição de superioridade informacional, obtendo, com isso, vantagem indevida sobre os demais investidores. Por outro lado, a divulgação de informação não relevante na forma de aviso de fato relevante, ainda que seja indesejável, não produz o mesmo prejuízo. Sobre o assunto, transcrevo a citação de Luciano de Souza Leão Junior²²:

(...) não há sanção pela divulgação de fatos não relevantes como fatos relevantes, desde que as informações sejam reais e não tendenciosas. Esses fatos têm como resultado prático o inconveniente de incentivar o administrador de companhia aberta a divulgar, como fato relevante, informações que não necessariamente o sejam e mesmo a utilização do meio de divulgação como instrumento de “marketing”.

86. Também chamou a atenção da área técnica o excessivo número de fatos relevantes relacionados ao tema. No entanto, os fatos reconstruídos neste processo demonstram a opção da administração em empreender grande esforço para iniciar sua campanha exploratória, inclusive por meio de vultuoso endividamento, desenvolvendo intensa atividade de perfuração naquele período, a demonstrar, com base na documentação constantes dos autos, que as informações divulgadas tinham respaldo técnico²³ (fls. 1.440 a 1.445).

87. A par disso, outra circunstância que esmorece a tese de manipulação é que não há nos autos elementos para desqualificar o conteúdo dos fatos relevantes divulgados entre 2009 e 2012, ou seja, não há provas no âmbito deste processo de que os administradores teriam inserido informações falsas ou distorcidas sobre a realidade empresarial da Companhia naquele período, um dos comportamentos esperados daquele que busca manipular o mercado, conforme amplamente reportado na doutrina²⁴.

²¹ Trata-se, como já comentado, de mecanismo que busca evitar possíveis distorções nas negociações com ações, uma vez que se funda na premissa de que, se todas as informações relevantes para uma tomada de decisão racional de investimentos estiverem disponíveis, os preços dos ativos negociados em bolsa representarão as legítimas expectativas dos investidores.

²² De Souza Leão Júnior, Luciano. Conselho de Administração e Diretoria. In: Lamy Filho, Alfredo; Bulhões Pedreira, José Luiz. *Direito das Companhias*. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. Pág. 862.

²³ Segundo informações constantes dos autos, a OGX teria perfurado cerca de 145 poços, sendo 115 exploratórios e 30 de desenvolvimento, a um gasto de aproximadamente 10 bilhões de reais (fls. 1.433).

²⁴ “With regard to techniques used by fraudsters, more than 55% of cases involve spreading rumors or false information. Manipulators also frequently use wash trades and nominee accounts to create artificial trading activity (...). Pump-and-dump schemes involve touting a company’s stock through false or misleading statements in the marketplace in order to artificially inflate (pump) the price of a stock. Once fraudsters stop hyping the stock and sell their shares (dump), the price typically falls. Although pump-and dump schemes have existed for many decades, the emergence of the Internet and social media has provided a fertile new ground for fraudsters. False or misleading information can now be disseminated to a large number of potential investors with minimum effort, anonymously, and



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

88. Embora a SEP tenha afirmado que apenas uma publicação feita pela Companhia naquele período teria sido aparentemente equivocada em razão de informar estimativa de volume de óleo recuperável durante a perfuração do poço, o que foi contestado pelos acusados mediante a alegação de que as estimativas divulgadas teriam sido de recursos e não de reservas, na forma da legislação da ANP, importante repisar que a acusação de manipulação formulada nestes autos circunscreve-se na má-fé dos acusados de produzir conjunto excessivo de fatos relevantes com (i) informações irrelevantes; (ii) tom excessivamente otimista; e (iii) **sem ressaltar os riscos para os investidores.**

89. Especificamente em relação à inadequada divulgação dos riscos, incertezas e premissas das divulgações das projeções da OGX, forçoso reconhecer a impropriedade da SEP em afirmar que o alerta contido nos avisos de fato relevante teria sido feito em nota de rodapé. Compulsando a documentação correspondente, noto que todos os “avisos legais” publicados nos fatos relevantes continham alerta redigido no corpo do texto e no mesmo formato das informações relevantes divulgadas, e não em nota de rodapé.

90. Como bem apontado pelas defesas, não se pode atribuir poder de convencimento a um trecho de um documento particular e retirá-lo de outro do mesmo documento, conforme expressamente proíbe o art. 412 do Código de Processo Civil²⁵, que determina ser o documento particular indivisível, “*vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse*”. Dito de outra forma, não se pode pretender conferir poder de convencimento a informação sobre a descoberta dos indícios de hidrocarbonetos e, ao mesmo tempo, retirar a força de precaução contida no aviso legal informando os riscos de concretização daquelas estimativas publicadas no mesmo aviso de fato relevante.

91. Sobre o conteúdo do aviso legal, tenho que ele reportava os riscos das estimativas, projeções e expectativas manifestadas pelos administradores naqueles documentos, conforme faz prova o texto-padrão a seguir reproduzido (fls. 37 e 38):

Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, “prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de aceção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e

at a relatively low cost [...] Channels of communication used by fraudsters to disseminate false information to the marketplace include false or misleading press release, stock spam e-mails, websites, bulletin boards and, in recent years, social media”. Renault, Thomas. *Market Manipulation and Suspicious Stock Recommendations on Social Media* (December 20, 2017). Disponível em <<https://ssrn.com/abstract=3010850>>, acessado em 02.05.2019.

²⁵ Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída. Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento (...).

92. Esses fatos denotam que a administração da OGX agiu, naquele momento, da forma que seria a esperada às circunstâncias, divulgando as informações consideradas relevantes à medida que se tornaram disponíveis e concretas, bem como as projeções delas decorrentes, ressaltando eventuais incertezas quanto à concretização final da exploração comercial dos Campos, conforme preceitua a legislação e em linha com as decisões desta Comissão²⁶.

93. Quanto às declarações de Paulo Mendonça consideradas excessivamente otimistas pela SEP, cabe registrar inicialmente que não é proibido emitir opiniões sobre as informações divulgadas pelas companhias, desde que sejam elas verdadeiras, úteis, não tendenciosas e diferenciadas das informações factuais, conforme prevê a Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009:

Subseção I – Conteúdo e Forma das Informações

Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

Art. 15. Todas as informações divulgadas pelo emissor devem ser escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa.

Art. 16. O emissor deve divulgar informações de forma abrangente, equitativa e simultânea para todo o mercado.

Art. 17. As informações fornecidas pelo emissor devem ser úteis à avaliação dos valores mobiliários por ele emitidos.

Art. 18. Sempre que a informação divulgada pelo emissor for válida por um prazo determinável, tal prazo deve ser indicado.

Art. 19. Informações factuais devem ser diferenciadas de interpretações, opiniões, projeções e estimativas.

Parágrafo único. Sempre que possível e adequado, informações factuais devem vir acompanhadas da indicação de suas fontes.

94. Nota-se também que os comentários emitidos por Paulo Mendonça estavam separados das informações sobre a descoberta dos indícios de hidrocarbonetos e das projeções realizadas, na forma das regras acima mencionadas.

95. Ainda em linha com o que preconiza a referida instrução, as informações divulgadas pela OGX tinham respaldo factual, conforme realidade processual. Ademais, elas eram, de fato, positivas, pois indicavam a possibilidade de se extrair óleo dos poços perfurados. De outro modo,

²⁶ Neste sentido, convém transcrever trecho do voto do Diretor Relator Marcelo Trindade proferido no julgamento do PAS nº 22/1999, de 16.08.2001, em que consignou: “Esta sucessão de eventos revela claramente, em meu entendimento, que as companhias envolvidas, a CVM e a Bovespa agiram todas, naquele momento, da forma como deveriam: as empresas divulgaram as informações à medida que se tornaram disponíveis e minimamente concretas, mas sem aguardar o desfecho detalhado do assunto, evitando assim que se perdesse o controle sobre a informação. (...) O juízo do administrador é o mais sábio para atestar o momento em que se passa do campo da mera expectativa para o da possibilidade real sobre a efetivação de um negócio, de uma perda ou de um lucro, e a eventual incerteza quanto à concretização final do evento não deve afastar o dever de informar, desde que, naturalmente, seja feita a ressalva quanto àquela incerteza”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

não fossem descobertos tais elementos químicos naquelas perfurações, não seria possível eventualmente encontrar petróleo naquelas acumulações, o que certamente seria considerada uma informação de viés negativo em relação ao desenvolvimento dos Campos.

96. Com efeito, naquele contexto de confiança com o futuro promissor da Companhia e a confirmação da existência de óleo nos poços perfurados, conforme inicialmente planejado pelos administradores, tenho que as referidas declarações positivas contidas nos fatos relevantes representavam realmente a expectativa da administração e de Paulo Mendonça sobre a futura produção de óleo e gás, sem denotar, portanto, indício de que se tratava de um mecanismo previamente idealizado para induzir a erro os investidores da OGX.

97. Nessa direção, estou convencido de que, embora seja possível criticar uma ou outra declaração de Paulo Mendonça por ter tido um tom acima do que seria recomendado às circunstâncias, como bem andou a SEP ao pontuar em seu ofício circular²⁷, o exame do conjunto dessas declarações no período de 2009 a 2012 não me conduz à conclusão de que se tratava de artilho previamente criado pelos acusados com o intuito de transformar uma informação desimportante em uma informação artificialmente relevante, como preconiza a Acusação.

98. Também não posso deixar de mencionar que, muito embora tenha sido imputada aos acusados a responsabilidade por manipular o preço das ações da OGX por quase quatro anos consecutivos (2009 a 2012), não há na peça acusatória referência ao preço das ações no período. A despeito de tal prova não ser imprescindível para formular uma acusação deste tipo, há de se reconhecer que ela desempenha função importante para evidenciar que investidores foram induzidos à negociação.

99. E a importância da prova a respeito da oscilação do preço das ações provocada pelo mecanismo considerado ilícito avoca maior destaque quando se presta a amparar tese jurídica inédita, não avaliada anteriormente pelo Colegiado. Em tais circunstâncias, em que não existe convicção prévia acerca da idoneidade do meio utilizado para provocar a manipulação vedada pela legislação, devem as áreas técnicas redobrar o cuidado na obtenção do maior número possível de evidências sobre o ilícito, que, nesta seara, são quase sempre indiciárias.

100. Diante disso, e a pedido da defesa de Marcelo Torres, decidi encaminhar o processo à SMI para que fosse realizada a avaliação do comportamento das ações da OGX no período compreendido entre 2009 e 2012 (fls. 2.801-2.803). Após definir a metodologia, a SMI concluiu que, em seguida à divulgação dos fatos relevantes enfatizados pela SEP, a cotação das ações da OGX teria apresentado retornos superiores aos normais.

²⁷ OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/GEA-3/Nº01/2014: As informações objeto de divulgação deverão estar expressas em linguagem clara e objetiva, devendo ser verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro (...) a companhia deve eximir-se de emitir juízo de valor, sobretudo no que diz respeito ao andamento de disputas judiciais e decisões nelas proferidas, as quais devem refletir o exato teor de tais decisões.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

101. Em que pese as críticas bem formuladas pelas defesas à metodologia estatística adotada pela SMI, o efeito descrito pela SMI não destoaria daquele previsto de ocorrer em seguida à divulgação de uma informação relevante, qual seja, a modificação da percepção dos investidores sobre o valor da Companhia. Nesse sentido, ainda que o resultado demonstre que aquelas informações divulgadas nos avisos de fato relevante efetivamente alteraram a intenção dos investidores em negociar ações emitidas pela Companhia, ela não é capaz de comprovar a suposta manipulação aventada pela Acusação, mas, sim, reforçar o argumento de que se tratava de informação relevante.

102. Evidentemente que se as informações contidas naqueles fatos relevantes fossem porventura falsas, dolosamente distorcidas, ou não houvesse circunstância fática de caráter positivo a respaldar os comentários confiantes feitos naquelas divulgações, a prova produzida pela SMI assumiria outro contorno, pois serviria de evidência a demonstrar que o ardil utilizado pelos acusados teria sido hábil o suficiente para induzir os investidores a negociar com ações da OGX, criado com o intuito exclusivo de ludibriar o mercado sobre a perspectiva de rentabilidade futura da companhia. Contudo, essa não é a realidade dos autos.

103. Diante de todas as conclusões antes mencionadas, parece desnecessário avaliar o último indício trazido pela Acusação consistente na venda de ações realizadas por Paulo Mendonça e Marcelo Torres, na medida em que este elemento de prova não diz respeito à configuração, em si, do ilícito de manipulação de preços descritos na ICVM nº 08/79.

104. Nos termos do inciso I combinado com o II, “b”, da ICVM 08/79, a configuração da manipulação de preços prescinde da demonstração do prejuízo causado ou do benefício auferido, tratando-se de infração de mera conduta. A caracterização do ilícito, portanto, não requer a demonstração de que os acusados tiveram lucro nas suas negociações com a concretização da estratégia delituosa.

105. Ainda assim, cabe o registro de que as defesas apresentaram, neste particular, conjunto de documentos que suplantou, em muito, a dúvida trazida pela SEP de que a venda de ações realizada pelos acusados haveria de provar a intenção deles de obter vantagem com o aumento artificial do preço das ações da OGX. Nesse sentido, os elementos dos autos revelam que (i) os montantes negociados teriam sido muito inferiores aos que eles teriam direito de vender, de acordo com o plano de opção outorgado pelo acionista controlador; e que (ii) as vendas teriam ocorrido em poucas oportunidades, quando não haveria informação privilegiada ou proibição de qualquer natureza.

106. Com efeito, o padrão de negociação dos acusados retratado neste processo não é o que se aproxima daquele que busca tirar vantagem por meio da prática de manipulação de mercado, quando o mais provável seria o agente negociar destacada parcela de ações toda vez que fosse bem-sucedido na tarefa de alterar a direção da cotação das ações, para, assim, obter o maior retorno possível.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

107. Por todo o exposto, após minucioso exame das provas dos autos, concluo que a SEP não logrou êxito em comprovar que Paulo Mendonça e Marcelo Torres teriam manipulado o preço das ações da OGX no período de 2009 a 2012, razão pela qual julgo improcedente a acusação de infração à Instrução CVM nº 08/79.

108. Na mesma direção, e como já salientado, a SEP não demonstrou que as divulgações aludidas nesta acusação tivessem desobedecido a regras que regem a matéria. Faltando a comprovação do descumprimento culposos pelos administradores, cumpre julgar igualmente improcedente a acusação formulada em face de José Cavalcanti, Reinaldo Vargas e Eike Batista de violação do dever de diligência, previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76.

V.2 FATO RELEVANTE COM OMISSÃO MATERIAL

V.2.1 MATERIALIDADE DELITIVA

109. A segunda acusação formulada pela SEP neste processo refere-se à suposta incorreção da divulgação, em 13.03.2013, do fato relevante segundo o qual a OGX informou ao mercado que submeteu a declaração de comercialidade dos Campos à ANP. Segundo a área técnica, os administradores teriam deixado de revelar informações negativas já disponíveis na Companhia sobre as dificuldades de monetizar os Campos, destacadamente a redução substancial da estimativa do volume de recuperação e o valor presente líquido (“VPL”)²⁸ negativo do projeto.

110. Diante disso, a SEP entendeu que referida divulgação teria sido realizada de maneira inadequada por omitir informações materiais a respeito da provável inviabilidade dos Campos, e, por isso, responsabilizou o diretor de relações com investidores da OGX, Roberto Monteiro, por infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09. Também responsabilizou Luiz Carneiro, diretor presidente; Reinaldo Vargas, diretor de produção; e José Cavalcanti, diretor jurídico; por supostamente terem manifestado concordância com essa inadequada divulgação, faltando com o cuidado e a diligência exigidos pelo art. 153 da Lei nº 6.404/76.

111. Em contraposição, as defesas dos acusados alegaram, resumidamente, que a decisão da OGX de declarar a comercialidade dos campos teria o objetivo de reter as acumulações que estavam sob a concessão da Companhia, para que elas não fossem devolvidas, e, uma vez declarada, a publicação dela via fato relevante constituiria praticamente uma inexigibilidade de conduta diversa, pois não se poderia contestar que se tratava de informação relevante para os investidores.

112. Tal tratamento já haveria sido realizado em outras oportunidades pela OGX, conforme os fatos relevantes de 17.05.2011, 25.04.2012 e 14.05.2012, bem como pela Petrobras (fls. 2.719-2.720). Além disso, tal informação chegaria ao mercado de qualquer forma, uma vez que a ANP a disponibilizaria em seu site.

²⁸ Método utilizado para determinar a viabilidade de um investimento em certo período de tempo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

113. Com a chegada da data limite para se posicionar, e não tendo sido possível determinar em que grau a baixa produtividade obtida no poço do campo de Tubarão Azul afetava o desenvolvimento econômico dos demais, a Companhia teria decidido por emitir a referida declaração.

114. Acrescentaram que seria comum na indústria de óleo e gás esse procedimento de retenção da área por meio de uma declaração para posterior busca de soluções que viabilizem os projetos até a elaboração do plano de desenvolvimento. Por outro lado, a análise de viabilidade econômica seria um estudo mais aprofundado, o qual permitiria a decisão sobre iniciar ou não a fase de produção. Neste contexto, na visão dos acusados, não existiria omissão no conteúdo do fato relevante divulgado porque a estimativa de volume de óleo recuperável seria exatamente o que a Companhia estaria tentando calcular quando declarou a comercialidade.

115. As defesas também mencionaram o artigo 157, §5º, da Lei nº 6.404/76²⁹, que admitiria, em situações excepcionais, o sigilo sobre determinada informação potencialmente relevante caso os administradores entendessem que a sua revelação poderia prejudicar interesse legítimo da companhia. Segundo alegado, a divulgação relativa à existência de estudos e negociações sobre a tomada de decisões relevantes, antes que estas se tornassem definitivas, poderia contrariar interesse legítimo da OGX.

116. Concordo com o argumento das defesas de que a declaração de comercialidade era, inegavelmente, uma informação relevante. Contudo, assiste razão à Acusação ao afirmar que a simples leitura desta afirmação contida no aviso de fato relevante induziu o investidor a acreditar que a viabilidade econômica dos Campos estava mais próxima de se concretizar do que o contrário, o que comprovadamente não correspondia à realidade da OGX naquele momento.

117. A cronologia dos fatos reconstruída neste processo demonstra que as grandes promessas de rentabilidade decorrentes da exploração dos Campos já eram objeto de ceticismo pela Área de Reservatórios da OGX desde, ao menos, 2011. Os engenheiros já indicavam volumes de óleo inferiores aos da interpretação inicial divulgados ao mercado pela OGX.

118. Havia dissenso dentro da própria Companhia quanto às estimativas de produção das acumulações, e as previsões que eram divulgadas aos investidores não eram unanimidade entre os técnicos. Isso pode ser comprovado pela leitura do relatório interno denominado “Reavaliação dos Ativos da OGX na Bacia de Campos”, emitido em junho de 2013, em que consta, já em 2011, que

²⁹ Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. § 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

as análises da área de reservatórios já haviam sinalizado “*volumes e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial*”, cujo teor entendo relevante reproduzir (fls. 292-309):

Durante a fase exploratória foram perfurados e testados nestas áreas vários poços no carbonato Albiano, a maioria deles apresentando altos teores de H₂S, embora bastante variáveis. Este fato sugeria a possibilidade de termos áreas com teores de H₂S baixos, como foi o caso de Tubarão Azul. Além desta contaminação, os testes evidenciaram baixos índices de produtividade. Entretanto, o modelo de reservatório vigente até então era de que a produtividade seria muito maior com a utilização de poços horizontais, em função do sistema de fraturas, tomando como referência o caso positivo do poço horizontal de Tubarão Azul, o 9-OGX-26HP-RJS, que também tinha apresentado baixo IP no teste de poço vertical.

Apesar da contaminação com H₂S e dos baixos índices de produtividade, ter encontrado óleo nos diversos poços perfurados levou a uma estimativa bastante elevada de volume in-place de óleo, na faixa de dois bilhões de barris, o que permitiria a viabilização de um projeto mais caro, fruto da grande extensão areal e da tecnologia e material necessários para trabalhar com H₂S.

Nesta área, os **resultados dos poços exploratórios e dos testes de formação realizados já indicavam que a compartimentação poderia ser um complicador adicional**, evidenciada por contatos óleo-água e propriedades de óleo diferentes em diversos blocos. **As primeiras análises da Área de Reservatórios, ainda em 2011, já sinalizavam volumes e compartimentação muito diferentes da interpretação inicial**. Decidiu-se então pela contratação de uma consultoria externa, no caso a Schlumberger, que aportou técnicos com experiência em reservatórios carbonáticos de todo o mundo. [grifou-se]

119. E a sinalização daquela relevante divergência na interpretação das informações relacionadas aos Campos repercutiu na Companhia. Tanto isso é verdade que a administração da OGX decidiu (i) alterar a estrutura organizacional da Companhia em junho de 2012, transferindo a Área de Reservatórios – antes subalterna à diretoria de exploração – para a presidência, e (ii) contratar consultoria mundialmente reconhecida na área de exploração de petróleo para, em conjunto com os técnicos da OGX, reavaliar o modelo de exploração dos Campos.

120. Na apresentação de suas conclusões à diretoria executiva em 24.09.2012, o GT confirmou o cenário desfavorável apresentado pela Área de Reservatórios, **com a redução de 94% das estimativas iniciais de volume de óleo recuperável**. Desse modo, a administração da OGX já possuía, em setembro de 2012, a informação de que as estimativas dos volumes de óleo e gás dos Campos, inicialmente divulgadas ao mercado, não mais encontravam respaldo dentro da própria Companhia, visto que o GT havia concluído pela redução substancial de seus valores.

121. Cabe registrar que, no documento em que são sumarizadas as conclusões do GT, é mencionada, dentre as atividades que foram realizadas, a “*elaboração do conceito de produção, estimativa de prazos, ajuste na previsão de produção, estimativas de custo e prazo e análise econômica*”, a revelar que era escopo do GT avaliar a viabilidade econômica da exploração daqueles Campos. Nesse sentido, o GT identificou, em três diferentes cenários de custos de capital



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

para implantação do projeto, retornos negativos para o desenvolvimento da exploração dos Campos.

122. Dito de outra forma, ao analisar o retorno econômico para a Companhia, diante do investimento em três tipos distintos de plataformas para operar os Campos, **o GT verificou que, em todas as alternativas possíveis, não seria possível obter lucro.**

123. Portanto, é possível afirmar com convicção que no dia 24.09.2012, a administração da OGX já possuía a informação de que a estimativa inicial divulgada ao mercado não mais se mantinha e, por isso, deveria ser alterada, confirmando, desde então, a existência de uma informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

124. Ao longo de 2012, a visão chamada de pessimista dos engenheiros da Área de Reservatórios foi sendo corroborada, mas, ainda assim, a Companhia tentava achar uma alternativa que tornasse viável a exploração dos Campos. Em março de 2013, com o estudo da RATE e as novas sísmicas, já se tinha certeza de que não era economicamente viável a exploração com as tecnologias disponíveis, mas a Companhia decidiu postergar a divulgação deste fato até julho de 2013.

125. Nesse particular, a própria Companhia afirmou no Relatório de Reavaliação de Ativos que *“as comercialidades destas áreas foram declaradas com a perspectiva de até setembro deste ano se apresentar uma proposta para a ANP de postergação do desenvolvimento das mesmas, com o objetivo de se encontrar alguma solução tecnológica mais barata”* (fls. 292-309).

126. Desse modo, a administração da OGX estava ciente de que, no momento da divulgação do fato relevante de 13.03.2013, e com as soluções disponíveis, não seria possível extrair lucrativamente óleo e gás dos Campos, motivo pelo qual outras alternativas seriam buscadas até setembro de 2013.

127. Diante disso, estou convencido de que o insucesso do desenvolvimento dos Campos apresentado pelo GT à diretoria executiva da OGX e posteriormente amparado pelos relatórios técnicos elaborados pela RATE e CGG Brasil consistia em informação relevante de divulgação imediata e obrigatória, na forma da legislação de regência. Ou seja, naquele momento a administração já estava ciente de que o desenvolvimento não era possível, e mesmo assim declarou a comercialidade a fim de postergar a suspensão do desenvolvimento dos Campos, tendo optado por reter informação de extrema relevância e impacto na tomada de decisão de investimento dos investidores.

128. Neste ponto, cabe afastar o argumento das defesas de que a análise de viabilidade econômica seria um estudo mais aprofundado e que não se poderia divulgar estudos inconclusivos, pois a estimativa de volume de óleo recuperável ainda seria incerta. Como já comentado neste voto, em relação aos fatos relevantes ainda não definitivos ou concluídos, a administração deve divulgar as informações consideradas relevantes à medida que elas se tornem disponíveis e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

concretas, ressaltando eventuais incertezas quanto à concretização final da operação, transação ou projeto em curso, conforme preceitua a legislação e em linha com as decisões desta Comissão³⁰

129. Diferentemente do que quer fazer aparentar a defesa, o insucesso da campanha de exploração dos Campos foi divulgado em julho de 2013 ancorado em documentos produzidos antes da divulgação do fato relevante de 13.03.2013, conforme descreve o já citado Relatório de Reavaliação de Ativos (fls. 292-309). A rigor, fossem esses resultados tão incertos, não teriam sido todos eles referenciados no relatório, e a conclusão pela inviabilidade aprovada na sua integralidade pela diretoria e conselho de administração da OGX, a demonstrar que eles possuíam concretude suficiente para certificar o insucesso daquele projeto.

130. Nesse contexto, assiste razão à Acusação ao afirmar que a administração da OGX dispunha de informações relevantes sobre a baixa probabilidade de desenvolver economicamente os Campos, e, ainda assim, divulgou a declaração de comercialidade sem destacar essas informações materiais contidas naqueles documentos técnicos. Tais informações eram indispensáveis para a adequada compreensão de que, naquele momento, a Companhia estava muito mais próxima de anunciar o fracasso da exploração dos Campos do que o contrário, como fez parecer o fato relevante.

131. Inegavelmente, as provas dos autos demonstram que a OGX não cumpriu as determinações contidas ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, segundo o qual a companhia emissora deve divulgar informações completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.

132. O argumento dos acusados de que o fato relevante de 13.03.2013 era bastante elucidativo ao destacar os expressivos riscos, incertezas e premissas a que estavam sujeitas as afirmações divulgadas não lhes aproveita neste caso, porque, diferentemente do que foi examinado antes, não se está avaliando a divulgação de projeções, estimativas ou expectativas, mas da completa ausência de informações concretas e disponíveis sobre o insucesso dos Campos.

133. Estou certo que os alertas contidos no fato relevante de 13.03.2013 não eram minimamente aptos a advertir o investidor de que a entrega da declaração de comercialidade dos Campos à ANP representava, naquele momento, tão somente um meio de postergar a devolução daquelas acumulações em seis meses, em razão da ausência de qualquer solução viável de desenvolvimento das áreas, como os acusados declararam em uníssono nas suas correspondentes manifestações prévias e defesas.

134. Melhor sorte não assiste às defesas na alegação da pretensa necessidade de manter em sigilo essas informações para não prejudicar interesse legítimo da Companhia, hipótese excepcional dada aos administradores na forma do art. 157, §5º, da Lei nº 6.404/76³¹. Como

³⁰ Ver PAS CVM nº 22/99, julgado em 16/08/01; e PAS CVM nº RJ2006/5928, julgado em 17/04/07.

³¹ Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. § 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

mentionado anteriormente, prevalece no nosso ordenamento jurídico o princípio do *full disclosure*, no qual as companhias emissoras são obrigadas a dar total publicidade de fatos relevantes relacionados à companhia. Tal dever de informar dos administradores de companhias abertas está preconizado no art. 157³² da Lei nº 6.404/76.

135. A norma faculta aos administradores deixarem de divulgar, excepcionalmente, os atos ou fatos relevantes, caso entendam que sua revelação porá em risco “**interesse legítimo da companhia**”. Entretanto, essa faculdade cessa quando a informação escapar ao controle ou ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários, nos termos do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02³³, hipótese na qual deverá o fato relevante ser divulgado imediatamente.

legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.

³² Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.

§ 1º O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assembléia-geral ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social:

- a) o número dos valores mobiliários de emissão da companhia ou de sociedades controladas, ou do mesmo grupo, que tiver adquirido ou alienado, diretamente ou através de outras pessoas, no exercício anterior;
- b) as opções de compra de ações que tiver contratado ou exercido no exercício anterior;
- c) os benefícios ou vantagens, indiretas ou complementares, que tenha recebido ou esteja recebendo da companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo;
- d) as condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pela companhia com os diretores e empregados de alto nível;
- e) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia.

§ 2º Os esclarecimentos prestados pelo administrador poderão, a pedido de qualquer acionista, ser reduzidos a escrito, autenticados pela mesa da assembléia, e fornecidos por cópia aos solicitantes.

§ 3º A revelação dos atos ou fatos de que trata este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da companhia ou do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem

§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.

§ 5º Os administradores poderão recusar-se a prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de divulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido dos administradores, de qualquer acionista, ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o caso.

§ 6º Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente, nos termos e na forma determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas posições acionárias na companhia.

³³ Art. 6º Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia. Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

136. O referido dispositivo não define exatamente o que é interesse legítimo, deixando o conceito aberto para que a própria administração, diante do caso concreto e nos limites da Lei, defina a sua aplicabilidade. Ao analisar os precedentes desta Comissão, observa-se que, embora a definição do termo “interesse legítimo” não fosse a questão central objeto da análise dos processos, em algumas decisões foram fixados parâmetros para que a exceção à imediata divulgação fosse corretamente aplicada.

137. No voto condutor do PAS CVM nº RJ2006/4776, julgado em 17.01.2007, o Diretor Relator Pedro Marcílio destacou que deve existir um “*legítimo propósito empresarial na manutenção do sigilo*”, não se enquadrando no conceito a ausência de divulgação em decorrência do potencial impacto negativo no preço das ações da Companhia:

56. Assim, se a divulgação de uma informação que deveria ser tornada pública, de acordo com as regras de divulgação de informação, pode impedir a conclusão de um negócio, a conquista de um cliente ou o desenvolvimento de um produto ou serviço ou pode prejudicar legítimos interesses negociais da companhia, a companhia poderá, de acordo com a legislação específica, deixar de divulgar a informação.

57. Isso não significa que as companhias podem deixar de prestar informações simplesmente porque acreditam que seus negócios podem ser prejudicados pela divulgação. É preciso que haja um **legítimo propósito empresarial na manutenção do sigilo**. Assim, por exemplo, um negócio em que se beneficie um acionista específico **não pode deixar de ser divulgado porque essa informação impactaria negativamente o preço das ações da companhia**, aumentando o seu custo de captação.

58. Mesmo com relação a negócios legítimos e desinteressados, essa exceção à divulgação não é absoluta, pois, de acordo com o parágrafo único do art. 6º da Instrução 358/02, é obrigatório “divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.

138. Na mesma direção, Alfredo Lamy Filho e Bulhões Pedreira afirmam que essa previsão do §5º do art. 157, presente na maior parte das legislações desenvolvidas, é uma cláusula de proteção que tem como objetivo equilibrar o direito à informação dos acionistas ao invés de tratá-lo de forma absoluta, citando como causas legítimas para a não divulgação possíveis prejuízos a terceiros, podendo implicar inclusive responsabilidade para a companhia. Neste sentido, cita, por exemplo, a divulgação de contratos confidenciais, além de situações envolvendo “*os interesses da confiança, o good will, o segredo profissional, as normas reguladoras e de salvaguarda da concorrência, o segredo industrial*” dentre outros, cuja legitimidade para recusa deve ser apreciada no caso concreto³⁴.

³⁴ LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (coord.), Direito das Companhias, Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2ª edição, p. 856.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

139. No presente caso, nota-se que as informações relevantes a respeito das perspectivas negativas para o desenvolvimento dos Campos não divulgada referia-se, em um primeiro momento, à redução substantiva nas estimativas de volume recuperável e, pouco tempo depois, à própria inviabilidade dos Campos, não sendo, portanto, informações de cunho concorrencial ou cuja revelação poderia atrapalhar interesses negociais da Companhia, quando há uma transação a ser concluída.

140. Como já ressaltado, tratava-se de informação essencial sobre o valor dos ativos da companhia, fundamental para os investidores precificarem as ações da OGX, não se afigurando legítima a sua retenção dolosa por receio dos seus potenciais efeitos no preço das ações da Companhia. A certeza de que a informação influirá, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia não configura o interesse legítimo de que trata o art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, sob pena de subverter-se o princípio da transparência que permeia a higidez e a eficiência do mercado de capitais. Em casos que tais, o interesse legítimo a ser tutelado, em realidade, é o do investidor em obter informações verdadeiras, completas, consistentes e que não o induzam a erro.

141. De acordo com a legislação aplicável, não era permitido à administração da Companhia, tendo conhecimento das fundadas incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, divulgar fato relevante sobre a entrega da declaração de comercialidade destas acumulações à ANP, com conteúdo que fazia o investidor acreditar, inequivocamente, que seria possível obter, com brevidade, retornos positivos com a exploração daquelas áreas. Tem-se, portanto, configurada a violação ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09.

V.2.2 AUTORIA DO DELITO

V.2.2.1 RESPONSABILIDADE DO DIRETOR ROBERTO MONTEIRO

142. Com relação a Roberto Monteiro, diretor de relações com investidores da OGX, não resta dúvidas de que fazia parte de suas atribuições elaborar e divulgar as informações relevantes da Companhia de acordo com as prescrições legais e regulamentares.

143. Como se sabe, é extremamente importante ao funcionamento regular do mercado de capitais que as companhias abertas, na figura do diretor de relações com investidores, divulguem com clareza e presteza todas as informações passíveis de sensibilizar a decisão dos investidores, atuais e potenciais.

144. Por esse motivo, a CVM tem continuamente aprimorado a qualidade das informações que devem ser divulgadas, no atendimento ao princípio da ampla divulgação já comentado neste voto. Deste modo, a atuação do diretor de relações com investidores é primordial para a preservação deste princípio, pois todos depositam nela expectativa de que as informações sociais continuarão a ser bem valioso para os investidores.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

145. Embora tenha alegado a ausência de má-fé, lembrando, neste particular, a proteção conferida pela regra da decisão negocial ao administrador que age de boa-fé, importante ressaltar que a comprovação de má-fé não é requisito para a configuração de uma irregularidade culposa, como a ora apreciada. Como se sabe, para a caracterização de infrações desta natureza, basta tão somente a comprovação do descumprimento culposo dos preceitos contidos nos dispositivos legais e regulamentares, conforme indicado pela Acusação.

146. Ademais, o padrão de revisão de conduta da regra da decisão negocial tem como requisito essencial para sua aplicação a existência de uma decisão negocial, o que não se verifica no presente caso. Neste sentido, a Diretora Luciana Dias³⁵ afirmou que *“a doutrina da decisão negocial não diz respeito a toda e qualquer decisão da administração de uma companhia, mas volta-se a decisões de cunho negocial e afasta decisões relacionadas a questões organizacionais, ou ao mero cumprimento de obrigações impostas pela regulamentação ou pelo estatuto da companhia”*.

147. Nota-se, assim, que a decisão de divulgar um fato relevante verdadeiro, completo e que não induza a erro os investidores em nada se assemelha a uma decisão negocial, afigurando-se, em realidade, no cumprimento de uma obrigação imposta pela regulamentação vigente.

148. Deste modo, ao elaborar e divulgar o fato relevante de 13.03.2013 omitindo informações relevantes para uma correta avaliação da Companhia, em desacordo com as normas que regem a matéria, Roberto Monteiro violou o art. 14 da ICVM 480/09.

V.2.2.2 RESPONSABILIDADE DO DIRETOR LUIZ CARNEIRO

149. Luiz Carneiro exerceu o cargo de diretor presidente da OGX entre junho de 2012 e outubro de 2013, ou seja, exatamente durante o período em que as revisões sobre as estimativas de óleo e gás dos Campos foram realizadas e chegou-se à conclusão que a exploração daquelas acumulações era inviável economicamente.

150. Sobre o assunto, importante pontuar que, por conta das divergências internas acerca da estimativa de volume de óleo recuperável nos Campos, foi proposta uma reestruturação da administração, tendo, inicialmente, Paulo Mendonça assumido o cargo de diretor presidente, e, em junho de 2012, o acusado assumiu a presidência, conforme esclarece trecho da defesa a seguir reproduzido:

(...) imediatamente após ser empossado, [Luiz Carneiro] promoveu uma importante mudança na OGX, ao transferir a área de reservatórios, que se reportava anteriormente ao Diretor de Exploração, para a própria Presidência da Companhia (...).

A primeira tarefa que o Sr. Luiz Carneiro designou ao novo gerente executivo de reservatórios foi a avaliação criteriosa de alguns assets da Companhia, o que

³⁵ Nos termos do voto proferido em 21.07.2015, no âmbito do PAS CVM nº 09/2009.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

gerou o relatório ‘Valoração dos Ativos Bacias de Campos e Parnaíba’ de julho de 2012, o qual questionava alguns dados considerados até então como verdadeiros, inclusive aqueles resultantes do workshop.

De posse desse relatório, o Sr. Luiz Carneiro convocou a nova Diretoria da OGX e deu ciência do seu resultado a todos os seus membros, tendo recomendado a criação de um grupo de trabalho com o objetivo de ‘avaliação de oportunidade de desenvolvimento da produção das acumulações de Pipeline, Fuji, Illimani e Osorno’, sugestão aprovada por unanimidade.

151. Entendo particularmente importante ressaltar esses pontos trazidos pela defesa porque demonstram que acusado estava, no âmbito de suas funções de administrar e gerir os negócios da Companhia, diretamente envolvido com os esforços de esclarecer as divergências técnicas relativas aos Campos, bem como com as possíveis alternativas para tentar solucionar o problema.

152. Nessa direção, foi o acusado quem imediatamente alterou a estrutura organizacional da OGX para que a Área de Reservatórios, mais conservadora quanto às estimativas de óleo e gás, passasse a responder diretamente a ele, a demonstrar que o seu ingresso na Companhia estava intimamente ligado àquelas divergências envolvendo a exploração dos Campos. Ademais, esses ativos eram extremamente valiosos para a Companhia, exigindo do acusado o acompanhamento próximo das análises e dos estudos realizados sobre o tema.

153. Com efeito, não há dúvidas de que o acusado acompanhava os estudos e seus resultados, bem como participava ativamente das decisões ligadas à matéria, ações esperadas à luz de suas atribuições estatutárias³⁶ e da relevância do assunto para o futuro da Companhia. Esperava-se de um administrador diligente que, diante das conclusões do GT e, mais tarde, de posse dos resultados das análises da RATE e das sísmicas, não permitisse que o fato relevante de 13.03.2013 omitisse dos investidores os problemas técnicos já conhecidos pela Companhia para desenvolver os Campos.

154. Além disso, a Política de Divulgação e Uso de Informações da Companhia (“Política”) previa a existência de um Comitê de Divulgação e Negociação (“Comitê”) cuja direção caberia ao acusado, nos termos do item 6 da Política (fls. 1.398 a 1.405). Embora o Comitê nunca tenha sido

³⁶ Nos termos do Estatuto Social da OGX (aprovado em assembleia geral ordinária e extraordinária em 26.04.2012): “Artigo 14 - A Diretoria é composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 9 (nove) membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia, dos quais poderão ser designados um Diretor-Presidente, um Diretor Geral, um Diretor de Exploração, um Diretor de Produção, um Diretor Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores, um Diretor Jurídico, e os demais Diretores terão a designação indicada pelo Conselho de Administração à época de sua eleição. Os Diretores da Companhia terão as seguintes atribuições: (a) Cabe ao Diretor Presidente administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente: (i) fazer com que sejam observados o presente Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral; (ii) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, juntamente com o relatório dos auditores independentes, bem como a proposta para alocação dos lucros auferidos no exercício fiscal precedente; (iii) elaborar e propor, para o Conselho de Administração, o orçamento anual e plurianual, os planos estratégicos, projetos de expansão e programas de investimento; e (iv) conduzir e coordenar as atividades dos Diretores no âmbito dos deveres e atribuições estabelecidos para os respectivos Diretores pelo Conselho de Administração e pelo presente Estatuto Social, convocando e presidindo as reuniões da Diretoria;” (grifou-se)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

instalado, por questões de alegada praticidade, uma vez que as questões sobre as quais ele deveria deliberar eram tratadas sem a necessidade da instalação formal, tem-se que fazia parte das atribuições do diretor presidente avaliar o conteúdo dos fatos relevantes publicados pela Companhia, conforme se depreende da própria declaração do acusado prestada na fase investigativa do presente processo³⁷.

155. Portanto, estou convencido da responsabilidade de Luiz Carneiro por permitir a divulgação de fato relevante omissivo, não agindo com o cuidado e a diligência exigidos pelo art. 153 da Lei nº 6.404/76.

V.2.2.3 *RESPONSABILIDADE DO DIRETOR REINALDO VARGAS E DO DIRETOR JOSÉ CAVALCANTI*

156. Assim como os acusados anteriormente citados, Reinaldo Vargas e José Cavalcanti, que exerciam, respectivamente, os cargos de diretor de produção e diretor jurídico na OGX, são acusados por terem omitido informações relacionadas à inviabilidade econômica da exploração dos Campos na divulgação do fato relevante de 13.03.2013.

157. Com relação a esses acusados, cabe ressaltar que não lhes cabia elaborar e divulgar fatos relevantes, de acordo com o alegado pelas defesas, atribuição conferida pelo estatuto ao diretor de relações com investidores, como mencionado anteriormente. No que diz respeito ao comportamento dos acusados diante dos acontecimentos que precederam à divulgação do fato relevante, também não se verifica liame entre as suas funções estatutárias e o assunto objeto da divulgação, conforme se depreende da leitura do estatuto da OGX:

(d) Cabe ao Diretor de Produção: (i) auxiliar o Diretor Geral em suas funções; (ii) coordenar as atividades de Desenvolvimento da Produção e dos investimentos aprovados pelo Conselho de Administração; (iii) gerenciar a implantação dos projetos da Companhia; e (iv) planejar, coordenar, desenvolver e controlar as atividades e projetos que compõem o portfólio da Companhia de forma otimizada;

(...)

(g) Cabe ao Diretor Jurídico: (i) auxiliar o Diretor Geral em suas funções; e (ii) planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades e assuntos de natureza jurídica (Contratos, Societário, Cível, Trabalhista, Penal, Ambiental e Tributário) da Companhia, através da definição e/ou execução de planos, metas e estratégias, garantindo a observância dos requisitos legais e regulatórios vinculados às atividades da Companhia e de suas subsidiárias, realizadas de forma independente ou em parceria com terceiros;

³⁷ Neste sentido, o diretor presidente Luiz Carneiro declarou: “ *dessa forma, uma vez estruturada determinada informação das áreas competentes da companhia, as minutas dos Fatos Relevantes e dos Comunicados ao Mercado da OGX eram circuladas aos demais diretores e, posteriormente, à área de Relações com Investidores da EBX. Nesse procedimento, garantia-se que todos os diretores – e, portanto, todos aqueles que seriam os membros do Comitê – tivessem prévio acesso ao conteúdo de tais documentos, a fim de que pudessem comentá-los, alcançando, deste forma, o objetivo do Comitê, já que permitiria prévio acesso aos Fatos Relevantes e Comunicados aos diretores*” (fls. 1.467 a 1.473).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

158. Neste contexto, tem-se que ambos exerciam atividades específicas em suas áreas de atuação, com foco, no caso de Reinaldo Vargas, na produção de óleo e gás da Companhia, e, no caso de José Cavalcanti, nas questões jurídicas relacionadas à OGX, sem relação direta com as questões de exploração e viabilidade dos Campos, assunto objeto da divulgação do fato relevante de 13.03.2013.

159. Deste modo, na ausência de atribuição específica ou de elemento de prova a ligar a condutas dos acusados ao descumprimento das regras indicadas pela Acusação, não me parece razoável exigir que ambos tivessem tomado qualquer atitude com relação à elaboração e divulgação do fato relevante de 13.03.2013.

160. Conclui-se que, no caso concreto, a SEP não demonstrou o descumprimento culposos pelos referidos administradores, motivo pelo qual se impõe julgar improcedente a acusação formulada em face de Reinaldo Vargas e José Cavalcanti por violação do dever de diligência previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76.

VI. CONCLUSÃO

161. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, considerando a gravidade das infrações, a alta dispersão acionária da Companhia e grande volume de negócios à época³⁸, além dos danos à imagem do mercado de valores mobiliários, voto pela condenação de:

- a) **Roberto Bernardes Monteiro**, na qualidade de diretor de relações com investidores da OGX, à penalidade de multa pecuniária, no valor de **R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)**, pela divulgação de fato relevante omissos em 13.03.2013, induzindo a erro investidores da OGX Petróleo e Gás Participações S/A, em infração ao artigo 14 da Instrução CVM nº 480/09.
- b) **Luiz Eduardo Guimarães Carneiro**, na qualidade de diretor presidente, à penalidade de multa pecuniária, no valor de **R\$300.000,00 (trezentos mil reais)**, por não ter agido com cuidado e diligência ao concordar com a divulgação de fato relevante omissos em 13.03.2013, induzindo a erro investidores da OGX Petróleo e Gás Participações S/A, em infração ao artigo 153 da Lei nº 6.404/76.

162. Voto também pela extinção da punibilidade de **Paulo de Tarso Martins Guimarães**, em razão do seu falecimento em 07.09.2018, e pela absolvição de **Paulo Manuel Mendes de Mendonça, Marcelo Faber Torres, Eike Fuhrken Batista, Reinaldo José Belotti Vargas, e José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti** das acusações que lhes foram formuladas neste processo.

³⁸ A ação OGXP3, ação ordinária de emissão da OGX, chegou a integrar a carteira teórica de ativos do IBOVESPA, que leva em consideração, além de outros elementos, critérios como volume financeiro e índice de negociabilidade.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

163. Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/Nº 55/2014 (fl. 2.287).

É como voto.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR-RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/6517

Reg. Col. nº 9468/2014

Acusados: Eike Fuhrken Batista
José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
Marcelo Faber Torres
Paulo Manuel Mendes de Mendonça
Paulo de Tarso Martins Guimarães
Reinaldo José Belotti Vargas
Roberto Bernardes Monteiro

Assunto: Divulgação de fatos relevantes como instrumento de manipulação de preços das ações da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (atual Dommo Energia S.A.). Divulgação de fato relevante omissivo relacionado aos negócios da Companhia. Infração ao inciso I da Instrução CVM nº 08/1979. Infração ao artigo 153 da Lei 6.404/1976 combinado com o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009.

Diretor Relator: Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,

1. Embora compartilhe da sua preocupação com o excessivo alargamento do dever de diligência¹, entendo que nesse caso específico não há como concluir que Luiz Eduardo Guimarães Carneiro foi diligente na revisão do fato relevante de 13.03.2013 (“Fato Relevante”), razão pela qual acompanho o voto do Diretor Relator.
2. No regime sancionador da CVM, os acusados se defendem tanto dos fatos quanto do tipo que lhe foi imputado.

¹ V. voto que recentemente proferi no Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/11703, j. em 11.06.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

3. Esse fato, vale frisar, diferencia os processos sancionadores instaurados por essa autarquia de outros tipos de processos administrativos punitivos² e mesmo do processo penal³. Na CVM, o Colegiado pode dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da peça acusatória, mas não no momento do julgamento, devendo dar aos acusados afetados pela nova definição jurídica prazo para aditamento de suas defesas⁴.

4. Ponderando os prós e contras, acredito que essas limitações que a CVM se impôs ao regular o trâmite dos seus processos sancionadores foram acertadas. Afinal de contas, o tipo imputado pode ter reflexo direto na forma como a conduta do acusado pode ser revista⁵ e, conseqüentemente, no modo pelo qual esse se defende. Nessa perspectiva, garantir que os acusados possam se defender tanto dos fatos quanto da sua capitulação é medida que propicia o mais amplo direito de defesa.

5. De outro lado, não podemos ignorar que tais limites restringem a atuação do julgadores. A sistemática adotada na Deliberação CVM nº 538/2008 e mantida na Instrução CVM nº 607/2019 confere ao Relator o poder de cristalizar a imputação pela qual a conduta de cada acusado será analisada. Pouco debatido, esse poder é bastante

² Recurso em Mandado de Segurança. 2. Anulação de processo administrativo disciplinar e reintegração ao serviço público. Alteração da capitulação legal. Cerceamento de defesa. (...) 5. Entendimento pacificado no STF no sentido de que o indiciado defende-se dos fatos descritos na peça acusatória e não de sua capitulação legal. Jurisprudência. 6. Princípios do contraditório e da ampla defesa observados na espécie. Ausência de mácula no processo administrativo disciplinar. 7. Recurso a que se nega provimento. (RMS 24.536/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 05.03.2004). No mesmo sentido, RMS 32.495, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.08.2014 e REsp 617.103/PR, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 22.05.2006.

³ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. ANÁLISE VERTICAL E EXAURIENTE. OMISSÃO NA PEÇA ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. (...) 4. É princípio comezinho do direito penal e processual penal que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. 5. Contrariamente ao alegado pelo agravante, e já estatuído nas instâncias ordinárias, a questão atrai a normatividade do artigo 383 (emendatio libelli) e não do artigo 384 (mutatio libelli) do Código de Processo Penal, razão pela qual mostra-se desprovida a abertura de prazo para a manifestação da defesa, tendo em conta que o réu se defende dos fatos narrados na incoativa, e não da capitulação jurídica ofertada pelo Parquet. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 289.078/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 15.02.2017)

⁴ Artigos 25 e 26 da Deliberação CVM nº 538/2008 e o artigo 47 da Instrução CVM nº 607/2009.

⁵ Sobre a distinção entre padrões de conduta e padrões de revisão, v. EISENBERG, Melvin Aron. "The Divergence of Standards of Conduct and Standards of Review in Corporate Law". In: 62 Fordham Law Rev. 437 (1993). Disponível em: <http://ir.lawnet.fordham.edu/fr/vol62/iss3/1>. Tive a oportunidade de tratar do assunto com maior vagar no voto que proferi no Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/11703, j. em 31.07.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

importante. Basta dizer que, no processo sancionador da CVM, se no julgamento se concluir que a conduta não se amolda ao tipo imputado, o resultado é a absolvição.

6. Penso que esse regime acaba por impor ao relator a enorme responsabilidade de fazer uma análise cuidadosa dos tipos imputados para, quando for o caso, propor ao Colegiado a redefinição jurídica dos fatos. Não podemos, é claro, distorcer os fatos ou dar aos dispositivos alegadamente infringidos um alcance que eles não têm com o intuito de salvar acusações mal formuladas, ainda que os fatos indiquem ter, efetivamente, havido infração a algum tipo – distinto, contudo, daquele escolhido pela acusação e confirmado pelo Relator com a sua decisão de iniciar o julgamento.

7. No entanto, existem casos em que a conduta pode ser analisada com base em mais de um dispositivo legal. Talvez nenhuma situação retrate isso de maneira mais clara do que os deveres fiduciários impostos aos administradores, que em larga medida se interpenetram⁶. Esse me parece justamente o caso de Luiz Eduardo Guimarães Carneiro: sua conduta poderia, como bem apontado pelo Presidente, ter justificado uma acusação de violação ao dever de informar. Mas não vejo porque ela não possa, alternativamente, ser analisada apenas sob o prisma da diligência. No caso, a decisão pelo último parece decorrer de uma opção consciente da acusação, que, diante das provas dos autos, preferiu que a conduta do CEO fosse analisada por uma perspectiva de culpa e não de dolo.

8. Como destacado nos dois votos já proferidos, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro havia assumido papel importante tanto na revisão dos reservatórios quanto na divulgação dos fatos relevantes. No momento em que a Companhia divulgou o Fato Relevante, havia uma série de dúvidas quanto ao volume das reservas e a viabilidade da sua exploração. Na minha leitura, as notícias negativas disponíveis quando da divulgação do Fato Relevante não eram tão conclusivas como parece indicar o voto do Relator. Mas as significativas incertezas já estavam colocadas de modo bastante claro, como bem retratado pelo Presidente em sua manifestação.

9. Nessa perspectiva, parece-me que, se de um lado, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro atuou de modo diligente na condução da investigação acerca do potencial de produção dos reservatórios da Bacia de Campos, de outro, omitiu informação material no Fato Relevante, na medida em que este transmitia uma impressão de que os negócios da Companhia evoluíam em boa marcha. Comparado a fatos relevantes do período anterior,

⁶ Como bem assinala Luis Felipe Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 6.404/1976 são todos “extremamente próximos, com influência mútua – não há, portanto, separação clara”. SPINELLI, Luis Felipe. *Conflito de Interesses Na Administração da Sociedade Anônima*. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 96. Sobre esse ponto, reporto-me aos votos que proferi no julgamento dos Processos Administrativos Sancionadores CVM nº RJ2013/11703 e RJ2016/4271.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

vê-se uma linguagem mais comedida, mas não se pode ignorar a declaração do próprio Luiz Eduardo Guimarães Carneiro no corpo do comunicado indicando que aquele momento marcava a transição para uma “etapa focada no desenvolvimento de nossos ativos e avanço na produção”.

10. A minha divergência com relação ao bem lançado voto do Presidente decorre, sobretudo, da possibilidade desse fato ser capitulado como um problema de diligência. Em linha com o Relator, eu entendo que sim.

11. Previsto no artigo 153 da Lei nº 6.404/1976, o dever de diligência é o mais importante dos deveres fiduciários e desempenha um papel central no sistema da nossa Lei Societária. Nesse sentido, Luiz Antonio de Sampaio Campos assinala que o dever de diligência é a lente pela qual a atuação dos administradores deve ser primordialmente examinada:

“A LSA não se filiou exclusivamente a um critério sintético ou analítico, de sorte que ao mesmo tempo em que há deveres genéricos, há condutas e responsabilidades específicas – ou mesmo implícitas – indicadas ao longo da lei. Não obstante, a despeito de estar previsto um dever, uma conduta ou uma responsabilidade específica em algum ponto da LSA, tal fato não afasta a aplicação dos critérios de aferição de condutas e responsabilidades previstas genericamente nos artigos 153 a 159 da LSA, que terão inteira aplicação. Independentemente da descrição constante do corpo da LSA, todas as condutas, especialmente para fins da responsabilização, devem ser lidas pela lente do dever de diligência.”⁷

12. Entendo que a acusação teria sido mais precisa se tivesse sido realizada com base no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976 e com o artigo 14 da Instrução CVM nº 480/2009. Eventualmente, conjugados também com o artigo 153. Contudo, julgo que a omissão desses dispositivos não tornou insubsistente a acusação nem trouxe qualquer prejuízo à defesa. Afinal de contas, ainda que incluídos os dispositivos acima referidos – e mesmo que a acusação não mencionasse, dentre os dispositivos infringidos, o artigo 153 –, a conduta do acusado deveria, ao fim e ao cabo, ser analisada à luz do dever de diligência.

13. Se havia à época da divulgação do Fato Relevante notícias negativas a respeito das reservas, e se tais informações eram de conhecimento de Luiz Eduardo Guimarães Carneiro – e parece-me que temos no Colegiado consenso quanto a essas questões de fato – não vejo como concluir que o acusado foi diligente.

⁷ CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Conselho de Administração e Diretoria”. In: LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Org.). *Direito das Companhias*. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2009, Vol. 1, p. 1087.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

14. Melhor dizendo: há evidências de que Luiz Eduardo Guimarães Carneiro foi diligente nas questões relativas à reavaliação dos campos e, por isso, sabia que o Fato Relevante não retratava de modo fiel a situação da Companhia. Assim, mesmo analisando a conduta do acusado a partir de uma perspectiva meramente procedimental, parece-me forçoso concluir que a decisão final quanto ao conteúdo do Fato Relevante não pode ser explicada pelos procedimentos adotados – ao revés, é contraditória. Não vejo, portanto, como considerá-la razoável ou justificável no contexto.

15. Consequentemente, tenho que Carneiro, ao concordar com a publicação do Fato Relevante com aquele conteúdo, no mínimo, não foi diligente. A conduta do acusado pode, de fato, ter sido mais grave, mas me parece que há, no caso, também uma falta de diligência⁸, que restou bem demonstrada pela acusação e merece, portanto, ser censurada.

16. Diante do exposto, acompanho na integralidade as conclusões do Diretor Relator Henrique Machado.

É como voto.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor

⁸ Como disse no Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2016/4271: “27. Embora tenham conteúdos diferentes, os deveres de diligência e lealdade são bastante próximos. Em uma abordagem simplista, pode-se dizer que o dever de diligência se associa ao modo de atuação do administrador, sendo usualmente analisado sob uma perspectiva meramente procedimental. Já o dever de lealdade avança no conteúdo das decisões tomadas pelos administradores, buscando verificar a existência de um interesse extra-social e a ação ou omissão dolosa em detrimento dos acionistas ou cotistas, conforme o caso. 28. A interpenetração entre os dois deveres é clara e as fronteiras que os separam não podem ser delimitadas de modo absolutamente objetivo. Há quem diga que o dever de lealdade decorre do dever de diligência. Nessa perspectiva, pode-se defender que a diligência antecede à lealdade, no sentido de que o administrador pode agir sem diligência sem ser desleal, mas em toda falta de lealdade, há também (ou primeiramente) uma falta de diligência. Alternativamente, pode-se dizer que a questão vai além de uma mera precedência, uma vez que as discussões de diligência e lealdade se relacionam, respectivamente, a condutas culposas e dolosas.” (grifei)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/6517

Reg. Col. nº 9468/2014

Acusados:

Eike Fuhrken Batista
José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
Marcelo Faber Torres
Paulo Manuel Mendes de Mendonça
Paulo de Tarso Martins Guimarães
Reinaldo José Belotti Vargas
Roberto Bernardes Monteiro

Assunto:

Divulgação de fatos relevantes como instrumento de manipulação de preços das ações da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (atual Dommo Energia S.A.). Divulgação de fato relevante omissivo relacionado aos negócios da Companhia. Infração ao inciso I da Instrução CVM nº 08/79. Infração ao artigo 153 da Lei 6.404/76 combinado com o art. 14 da Instrução CVM nº 480/09.

Diretor Relator:

Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,

1. Compartilho da visão de que houve divulgação de fato relevante omissivo, tendo em vista que silente acerca das substanciais incertezas que haviam sido identificadas com relação à viabilidade econômica da exploração dos Campos¹, ao tempo em que, ao divulgar a Declaração de Comercialidade, o Fato Relevante de 13.03.2013 transmitia impressão favorável quanto às perspectivas do projeto, com potencial de conduzir os investidores a um entendimento equivocado sobre as informações então reveladas.
2. No que tange à acusação feita em face do acusado Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, à época Diretor Presidente da Companhia, concordo que teria sido melhor enquadrada com a inclusão ao menos do art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e do art. 14 da

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Instrução CVM nº 480/02, dentre os dispositivos infringidos, mas não considero que se tenha se tornado insubsistente por ter sido formulada apenas ao amparo do art. 153 da Lei nº 6.404/76.

3. Em que pese o primoroso detalhamento acerca do conteúdo legal do dever de diligência e sua relação com o dever de informar apresentado em sua manifestação de voto, respeitosamente divirjo da aplicação dada ao caso concreto.

4. Como ponderado, o dever de diligência previsto no art. 153 consubstancia o núcleo do qual emanam os demais padrões de conduta previstos na Lei nº 6.404/76, havendo uma correlação, e mesmo uma interseção, entre o dever de diligência e o dever de comunicar o mercado sobre atos ou fatos relevantes.

5. Embora não discorde que a conduta diligente deva ser aferida notadamente sob a perspectiva procedimental, entendo que os esforços adotados não podem ser tidos como razoáveis e adequados se apontam para um descumprimento consciente de obrigação imposta pela regulamentação vigente, para cumprimento de dever fiduciário, em especial quando exercidos por administrador diretamente envolvido com os fatos a serem divulgados e com a elaboração do próprio Fato Relevante e em posição de comando na Companhia, como ocorreu neste caso.

6. Registro, por fim, que o descumprimento do dever de diligência consubstanciado na concordância com a divulgação do Fato Relevante omissa em nada retira ou diminui o mérito da conduta diligente que o acusado Luiz Eduardo Guimarães Carneiro claramente exerceu com relação à apuração das informações referentes à viabilidade econômica da exploração dos Campos, por meio da promoção de reorganização estrutural e mudanças na governança interna da Companhia, que deram luz às divergências existentes entre as áreas de Exploração e de Reservas & Reservatório, e pela contratação dos diversos e imprescindíveis estudos que foram conduzidos para afastar as incertezas.

7. Feitas essas breves considerações, acompanho as conclusões do voto do Diretor Relator, em sua integralidade.

É como voto.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/6517

Reg. Col. nº 9468/2014

Acusados: Eike Fuhrken Batista
José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti
Luiz Eduardo Guimarães Carneiro
Marcelo Faber Torres
Paulo Manuel Mendes de Mendonça
Paulo de Tarso Martins Guimarães
Reinaldo José Belotti Vargas
Roberto Bernardes Monteiro

Assunto: Divulgação de fatos relevantes como instrumento de manipulação de preços das ações da OGX Petróleo e Gás Participações S.A. (atual Dommo Energia S.A.). Divulgação de fato relevante omissivo relacionado aos negócios da Companhia. Infração ao inciso I da Instrução CVM nº 08/79. Infração ao artigo 153 da Lei 6.404/76. Infração ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09.

Diretor Relator: Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. O objetivo desta manifestação de voto é apresentar considerações a respeito de uma das acusações feitas no âmbito deste processo administrativo sancionador e, por consequência, das conclusões do voto do Diretor Relator sobre tal acusação. Refiro-me ao suposto descumprimento, pelo Sr. Luiz Eduardo Guimarães Carneiro (“Luiz Carneiro”), na qualidade de Diretor Presidente da Companhia¹, do dever de diligência estabelecido no art. 153 da Lei nº 6.404/76. Embora acompanhe o entendimento de que, no aspecto informacional sob análise, o acusado agiu de um modo que não se revelou acertado, o enquadramento que foi dado pela acusação para sua conduta, o conjunto fático-probatório constante dos autos e os limites da análise revisional desta CVM, em especial deste Colegiado, me levam a conclusão distinta quanto a sua culpabilidade.

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

2. De acordo com a acusação, ao manifestar sua concordância com a divulgação do fato relevante de 13.03.2013 (“Fato Relevante”) que, na visão da área técnica, teria omitido informações relevantes a respeito da provável inviabilidade dos Campos, Luiz Carneiro teria agido em desacordo com o padrão de conduta condizente com seu dever de diligência.

3. Ao analisar a evolução das discussões sobre a exploração dos reservatórios de petróleo e gás natural, lideradas pela Diretoria da OGX, no período compreendido entre junho de 2012 e março de 2013, chego à mesma conclusão alcançada pela área técnica e pelo Diretor Relator: na data da publicação do Fato Relevante, havia informações que, embora inconclusivas, tinham o potencial de influir de modo ponderável na decisão dos investidores de negociar as ações da Companhia. Entretanto, tais informações não foram reveladas pela OGX até 01.07.2013, privando o mercado de elementos suficientes para permitir a percepção *“de que, naquele momento, a Companhia estava muito mais próxima de anunciar o fracasso da exploração dos Campos do que o contrário”*².

4. A despeito do que alguns dos acusados procuraram sustentar em suas defesas com relação ao melhor entendimento quanto ao significado de uma declaração de comercialidade, é indubitoso que tal ato tem o condão de gerar, nos investidores, impressão favorável a respeito das perspectivas do projeto a que se refere. Consta dos autos que a Procuradoria Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em resposta a questões levantadas pela área técnica no âmbito das investigações, declarou que: *“A Declaração de Comercialidade, portanto, é o documento em que o Concessionário informa que, de acordo com seus estudos a partir dos dados e informações adquiridos e processados durante a Etapa de Avaliação, a acumulação de hidrocarbonetos **tem viabilidade econômica para ser produzida**. Declarada a comercialidade, a descoberta para [sic] a ser uma Descoberta Comercial, definida, pela Lei nº 9.478/1997, como aquela ‘em condições que, a preços de mercado, **tornem possível o retorno dos investimentos no desenvolvimento e na produção**”* (fls. 517/518) (grifou-se).

5. Assim sendo, ainda que faltasse aos investidores conhecimento técnico preciso sobre o significado de uma “declaração de comercialidade”, é forçoso presumir que o sentido literal do termo tenha ensejado expectativas positivas em relação à exploração dos Campos³, uma vez que

² Conforme o voto do Diretor Relator.

³ A natureza otimista do Fato Relevante é ainda mais evidente quando se atenta para o comentário de Luiz Carneiro, que integrou o texto do Fato Relevante, com a seguinte mensagem: *“O final do período exploratório para as bacias de Campos e Santos representa a transição da OGX para uma etapa focada no desenvolvimento de nossos ativos e avanço na produção. Seguimos com a execução de nossos projetos buscando recursos de qualidade e as melhores práticas da indústria para a otimização dos reservatórios existentes”, comentou Luiz Carneiro, Diretor Presidente da OGX*” (fl. 55). Adicionalmente, também vale observar que constaram do Fato Relevante informações a respeito do



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

a percepção dos acionistas sobre seus investimentos na OGX baseava-se essencialmente nas informações do progresso da Companhia. Além disso, o próprio significado técnico do documento, conforme explicado pela ANP, permitia que investidores vislumbassem uma perspectiva positiva para a companhia a partir de sua divulgação.

6. Por se tratar de fato relevante, era fundamental que sua divulgação fosse feita da forma prevista na Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, o que implicaria, por exemplo, que seu conteúdo permitisse ao leitor compreender o fato por todos os ângulos importantes, ou seja: que a informação fosse apresentada de forma completa⁴.

7. No entanto, não foi o que ocorreu no caso do Fato Relevante, dada a ausência da informação de que a viabilidade econômica ainda estava sendo analisada e que estudos, mesmo que inconclusivos, haviam identificado dificuldades referentes à exploração lucrativa dos Campos que se expressaram, notadamente, na redução substancial da estimativa do volume de óleo recuperável em relação aos volumes originalmente divulgados ao mercado e nos retornos negativos para o desenvolvimento da exploração dos Campos (“Incertezas”)⁵.

8. Vale mencionar que não se discute, aqui, em que momento precisamente – anterior a 01.07.2013 – essas informações deveriam ter sido reveladas ao mercado: o que de fato importa para o presente caso é avaliar se sua divulgação se tornou inadiável diante da publicação do Fato Relevante e se, conseqüentemente, além de injustificadamente omitir informação material, seu conteúdo teve o potencial de conduzir os investidores a uma impressão equivocada sobre as informações reveladas.

9. Isso porque a lei apenas autoriza a não divulgação imediata de determinada informação relevante, caso incidente a exceção prevista no art. 157, §5º da Lei das S.A. e no art. 6º, parágrafo único da Instrução CVM nº 358/02⁶, qual seja, identificada a possibilidade de que sua revelação

“Desenvolvimento” e da “Exploração” dos Campos, sinalizando avanços nessas atividades, a saber: “Tubarão Tigre, Tubarão Gato e Tubarão Areia: Finalizando engenharia de reservatório” e “Bacia de Campos: Compromisso de perfurar três poços nos PADs até o segundo semestre de 2013” (fl. 56).

⁴ Nesse sentido, o Colegiado da CVM decidiu: “Um outro aspecto importante sobre a divulgação de fatos relevantes, é que as informações divulgadas ao mercado pelas companhias devem sempre ser prestadas de forma completa (art. 3º, §4º da Instrução 358/02), clara e precisa (§5º do mesmo artigo). Considera-se completa uma informação quando ela contém os fatos, dados, nuances e demais informações necessárias para a avaliação do impacto da informação principal sobre preço dos valores mobiliários ou sobre as decisões de investimento relativas a esses valores mobiliários. Não é considerada informação completa aquela que possa induzir os investidores a erro” (conforme passagem do voto proferido pelo então Diretor Pedro Marcílio no PAS CVM nº RJ2006/4776, j. em 17.01.2007).

⁵ Conforme exposto pelo Diretor Relator em seu voto, a apresentação das conclusões do grupo de trabalho à Diretoria da OGX em 24.09.2012 (especialmente fls. 106-108) indicava redução de 94% das estimativas iniciais de volume de óleo recuperável e, em três diferentes cenários de custos de capital para implantação do projeto, apontou retornos negativos para o desenvolvimento.

⁶ Destaco que o acusado trouxe esse argumento de defesa aos autos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

coloque em risco interesse legítimo da companhia. Contudo, tal ressalva ao *full disclosure* sujeita-se a determinadas circunstâncias limitadoras, como aquelas previstas no art. 6º, parágrafo único da Instrução CVM nº 358/02: oscilação atípica e a informação escapar do controle.

10. E, a meu ver, além dessas duas hipóteses expressamente previstas na regulamentação, tal exceção sempre estará suscetível à existência de um terceiro fator limitador: a existência de outras obrigações legais e regulamentares que, por sua natureza, não permitam que a administração da sociedade postergue seu cumprimento ou as realize de forma parcial⁷.

11. Não havendo margem de discricionariedade para decidir quanto ao cumprimento de tais obrigações, a regra geral da lei deverá ser cumprida, não podendo o administrador alegar que uma decisão informada e refletida tomada com base em permissivo legal genérico o levou a concluir pela violação de comando específico que estava obrigado a cumprir.

12. E este é o caso da obrigação de divulgar, prontamente, *“informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”*, prevista no art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, que incide sobre aquelas consideradas pela administração como fatos relevantes nos termos do art. 2º da Instrução CVM nº 358/02.

13. Quanto a este ponto, contudo, é necessário salientar que existem normas que contêm conceitos abertos, como, por exemplo, o de “interesse legítimo da companhia”, constante do art. 6º da mesma instrução e igualmente aplicável ao caso concreto. Como a aplicação prática desse dispositivo depende de um juízo complexo e subjetivo⁸, é aceitável – mais que isso, esperado – que administradores igualmente habilitados e diligentes divirjam quanto à sua configuração. Por esse motivo, entendo que a CVM deve ter certa deferência ao juízo feito por aqueles que dirigem o processo de divulgação de fatos relevantes.

14. Decerto essa deferência não exime a CVM de examinar se a não divulgação imediata de determinada informação resultou de uma decisão diligente, se houve omissão dolosa ou culposa, ou se houve erro não excusável por parte da administração. Mas conduz à conclusão de que, ainda que venhamos a discordar do julgamento feito, aos envolvidos não deve ser imputada responsabilidade quando a avaliação era razoável e justificável no contexto em que foi realizada, e se pautada pelos critérios estabelecidos pela Lei das S.A. e pela Instrução CVM nº 358/2002.

⁷ Nesse ponto, convém remeter à precedente observação do Diretor Relator, no sentido de que *“a decisão de divulgar um fato relevante verdadeiro, completo e que não induza a erro os investidores em nada se assemelha a uma decisão negocial, afigurando-se, em realidade, no cumprimento de uma obrigação imposta pela regulamentação vigente”*.

⁸ Nessa linha também parece entender o Diretor Relator, conforme se infere de seu voto: *“O referido dispositivo não define exatamente o que é interesse legítimo, deixando o conceito aberto para que a própria administração, diante do caso concreto e nos limites da Lei, defina a sua aplicabilidade.”* (§136)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

15. Ante o exposto, no caso em tela, entendo que a exceção à imediata divulgação encontra um limite adicional, temporal e objetivo, que torna necessário analisar se a divulgação das incertezas sobre os Campos se tornou inadiável diante da publicação do Fato Relevante, deixando de ser juridicamente aceitável⁹. Com efeito, havendo a administração decidido divulgar o Fato Relevante, a não inclusão em tal comunicado de informações a respeito das Incertezas, tendo em vista a necessidade de atendimento ao disposto no art. 14 da Instrução CVM nº 480/09, somente seria lícita diante de evidências de que: (i) as Incertezas não tinham relação direta com as informações divulgadas no Fato Relevante; ou (ii) sua não inclusão não comprometeria a veracidade ou compreensão do conteúdo do Fato Relevante, evidências estas que poderiam ter sido identificadas no âmbito de detida análise da administração.

16. Nesse contexto, ainda que visando, ao final, a verificação de possível irregularidade informacional, justifica-se a análise de sua conduta não apenas sob um aspecto objetivo, mas também sob a ótica do dever de diligência. Afinal, havendo explicação razoável, que envolva uma conduta diligente por parte do administrador, não cabe à CVM entrar no mérito de decisão informada e refletida que, posteriormente, se revelou prejudicial à Companhia ou a seus acionistas.

17. Segundo a tese acusatória, Luiz Carneiro foi responsabilizado por ter deixado de comunicar ao mercado informações relevantes relacionadas aos negócios da Companhia e das quais tinha ciência, quais sejam: as dificuldades e incertezas relacionadas à exploração dos Campos, incluindo a probabilidade, àquela altura já bastante expressiva, de que o desenvolvimento lucrativo desses projetos era inviável.

⁹ De acordo com o Diretor Relator: “No presente caso, nota-se que as informações relevantes a respeito das perspectivas negativas para o desenvolvimento dos Campos não divulgada referia-se, em um primeiro momento, à redução substantiva nas estimativas de volume recuperável e, pouco tempo depois, à própria inviabilidade dos Campos, não sendo, portanto, informações de cunho concorrencial ou cuja revelação poderia atrapalhar interesses negociais da Companhia, quando há uma transação a ser concluída. 140. Como já ressaltado, tratava-se de informação essencial sobre o valor dos ativos da companhia, fundamental para os investidores precificarem as ações da OGX, não se afigurando legítima a sua retenção dolosa por receio dos seus potenciais efeitos no preço das ações da Companhia. A certeza de que a informação influirá, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia não configura o interesse legítimo de que trata o art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, sob pena de subverter-se o princípio da transparência que permeia a higidez e a eficiência do mercado de capitais. Em casos que tais, o interesse legítimo a ser tutelado, em realidade, é o do investidor em obter informações verdadeiras, completas, consistentes e que não o induzam a erro. 141. De acordo com a legislação aplicável, não era permitido à administração da Companhia, tendo conhecimento das fundadas incertezas relacionadas à viabilidade econômica da exploração dos Campos, divulgar fato relevante sobre a entrega da declaração de comercialidade destas acumulações à ANP, com conteúdo que fazia o investidor acreditar, inequivocamente, que seria possível obter, com brevidade, retornos positivos com a exploração daquelas áreas. Tem-se, portanto, configurada a violação ao art. 14 da Instrução CVM nº 480/09.” (§§139-141)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

18. Logo, quando a acusação sustenta que a irregularidade da conduta do acusado consistiu em este ter “*manifest[ado] concordância com a divulgação de fato relevante omissa*” (fl. 2218), e que isso configurou falta de diligência, o julgador deve, para levar tal acusação adiante, identificar, na concordância com a divulgação do fato relevante omissa, evidência de que o acusado não observou o comando do artigo 153 da Lei nº 6.404/76. Afinal, a acusação fornece não apenas à defesa, mas também aos julgadores, o quadro fático e jurídico a ser contraditado pela primeira e apreciado pelos últimos.

19. Em outras palavras, e conforme entendimento pacífico deste Colegiado: a decisão do Colegiado deverá restringir-se à análise da acusação formulada, inclusive porque foi considerando esses termos que Luiz Carneiro exerceu seu direito de defesa¹⁰. Aceitar entendimento diverso significaria, neste caso, permitir que se formasse um “ponto cego” em desfavor do acusado, que se veria na situação frágil de ter que se defender não apenas das imputações constantes da acusação, mas também de outras possíveis imputações que poderiam advir da leitura dos fatos narrados na peça acusatória.

20. Nesse ponto, noto que, em vista de sua relação com o dever de informar do acusado, o melhor enquadramento para o presente caso envolveria a inclusão, ao menos, do art. 14 da Instrução CVM nº 480/02 e do art. 157, §§4-5º da Lei das S.A., dentre os dispositivos infringidos¹¹⁻¹².

21. Desse modo, em vista dos limites da acusação, procurarei, a seguir, esclarecer alguns aspectos do dever de diligência que julgo relevantes para os fins do julgamento. Em especial, em vista de se tratar de divulgação incompleta de fato relevante, considero útil cotejar o dever de diligência com o dever de informar.

22. O legislador de 1976 optou por definir o dever de diligência como um conceito aberto, conferindo ao intérprete ampla liberdade para conformá-lo às circunstâncias e à realidade do caso

¹⁰ Conforme decisões proferidas no âmbito do PA CVM nº SP 2011-302 e 2011-303, j. em 24.06.2014 e do PAS CVM nº RJ2013/6635, j. em 26.05.2015.

¹¹ A acusação também poderia ter explorado o fato de que a regulamentação vigente impunha a Luiz Carneiro, na hipótese de este constatar omissão da área de relações com investidores no que toca à divulgação de informações relevantes, o dever de comunicar imediatamente referida informação, nos termos do art. 3º, §2º, da Instrução CVM nº 358. Para tanto, a acusação teria que demonstrar que o acusado, ao revisar a minuta do Fato Relevante e constatar a omissão sobre informações materiais – no caso, informação completa sobre a conjuntura da exploração dos Campos – se absteve de tomar a referida medida. Todavia, não foi este o caminho seguido pela acusação, que sequer elencou o referido dispositivo regulamentar no tipo administrativo infringido.

¹² Ressalto que não caberia, neste momento, depois de iniciado o julgamento, propor nova definição jurídica aos fatos objeto deste processo, nos termos do art. 25 da Deliberação CVM nº 538/08. E, tampouco, alterar a tese acusatória, o que seria inoportuno e contrário ao regime que rege a tramitação dos processos sancionadores no âmbito desta autarquia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

concreto. A lei, portanto, não reflete uma escolha por abordagem mais prescritiva ou exaustiva do conceito, com requisitos apresentados de forma detalhada. A escolha por padrões mais abertos permite melhor adaptabilidade às mudanças impostas pela rápida evolução das práticas empresariais, impulsionadas pelas mudanças culturais e tecnológicas¹³⁻¹⁴.

23. Sendo um critério relativo, que se amolda às especificidades de cada caso, como já observado pela doutrina, *“não há uma única forma de atuar diligentemente, mas uma zona de comportamentos que podem ser considerados diligentes, o que significa, por outras palavras, que, para fins de verificar o cumprimento desse dever por parte dos administradores, não se deve indagar qual a conduta mais diligente, mas, sim, se houve falta de diligência no comportamento adotado”*¹⁵.

24. Com efeito, a doutrina e o Colegiado elencaram, respeitadas algumas variações¹⁶, três principais ordens de comportamentos que compõem o padrão de diligência previsto em lei e, por

¹³ Referindo-se a esse padrão, Carlos Klein Zanini assim descreve o dever de diligência: *“(...) o dever de diligência – também encontra-se previsto, expressamente, na lei societária brasileira. Tem-se, aqui, tanto no direito norte-americano como no brasileiro, a utilização de um padrão de conduta, lá denominado – em termo tomado de empréstimo por nós – de standard, como referência para avaliar, qualitativamente, os atos praticados pelo administrador na gestão da sociedade. (...) Da adoção deste standard, necessariamente genérico, pela lei, decorre que a ocorrência de uma infração ao dever de diligência somente poderá ser aferida mediante o exame do caso concreto, quando cumprirá ao intérprete determinar se a ação – ou omissão – do administrador configura ou não um desatendimento ao padrão de conduta esperado do homem ativo e probo na administração de seus próprios negócios”* (ZANINI, Carlos Klein. A doutrina dos “fiduciary duties” no direito norte-americano e a tutela das sociedades e acionistas minoritários frente aos administradores das sociedades anônimas. In: *Revista de direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 109, 1998, p. 139). No direito norte americano é válida a descrição do dever de diligência, em termos bastante amplos, feita por Robert Clark: *“Statutes and case law say that directors and officers owe their corporations a duty of care: They must exercise that degree of skill, diligence, and care that a reasonably prudent person would exercise in similar circumstances”* (CLARK, Robert Charles. *Corporate Law*. Boston, Little, Brown and Company Law Book Division, 1986, p. 123).

¹⁴ Referindo-se a esse padrão, Carlos Klein Zanini assim descreve o dever de diligência: *“(...) o dever de diligência – também encontra-se previsto, expressamente, na lei societária brasileira. Tem-se, aqui, tanto no direito norte-americano como no brasileiro, a utilização de um padrão de conduta, lá denominado – em termo tomado de empréstimo por nós – de standard, como referência para avaliar, qualitativamente, os atos praticados pelo administrador na gestão da sociedade. (...) Da adoção deste standard, necessariamente genérico, pela lei, decorre que a ocorrência de uma infração ao dever de diligência somente poderá ser aferida mediante o exame do caso concreto, quando cumprirá ao intérprete determinar se a ação – ou omissão – do administrador configura ou não um desatendimento ao padrão de conduta esperado do homem ativo e probo na administração de seus próprios negócios”* (ZANINI, Carlos Klein. A doutrina dos “fiduciary duties” no direito norte-americano e a tutela das sociedades e acionistas minoritários frente aos administradores das sociedades anônimas. In: *Revista de direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 109, 1998, p. 139). No direito norte americano é válida a descrição do dever de diligência, em termos bastante amplos, feita por Robert Clark: *“Statutes and case law say that directors and officers owe their corporations a duty of care: They must exercise that degree of skill, diligence, and care that a reasonably prudent person would exercise in similar circumstances”* (CLARK, Robert Charles. *Corporate Law*. Boston, Little, Brown and Company Law Book Division, 1986, p. 123). Este Colegiado reiteradamente reconheceu o caráter amplo do dever de diligência. Veja-se, por exemplo, o trecho do IA CVM 04/99: *“a enumeração das regras de conduta que devem ser seguidas pelo administrador é praticamente impossível. Por isso a lei opta por estabelecer um padrão que será apreciado à luz da experiência do julgador”* (Rel. Diretora Norma Parente, j. 17.04.02).

¹⁵ CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). *Direito das Companhias*. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 802.

¹⁶ A doutrina também faz referência aos deveres dos administradores de se qualificar para o exercício da função, de comparecer com assiduidade às reuniões da administração, de não praticar erros graves, de bem administrar, entre



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

isso, são empregados como parâmetros para a aferição da diligência das condutas adotadas pelos administradores¹⁷, em sede de revisão jurisdicional¹⁸. Refiro-me, aqui, aos deveres do administrador de se informar, vigiar e investigar, os quais lhe impõem, em linhas gerais, a obrigação de, respectivamente, tomar decisões de maneira informada, monitorar as políticas e atividades da companhia – dirigidas ou fiscalizadas pelo administrador – e tomar adequado conhecimento de fatos quando alertados por circunstâncias que exijam maior atenção sobre determinado assunto.

25. Como se vê, a análise da aderência de determinada conduta ao padrão de diligência previsto em lei deve ser feita com foco no aspecto procedimental. Ou seja, o que deve ser objeto de exame para aferir o cumprimento desses ditos subdeveres – e, por consequência, do dever de diligência – é a forma segundo a qual o administrador atua e não o conteúdo final de suas decisões¹⁹. Isso significa que importa, para a aferição do cumprimento deste dever que seja verificado, na prática, o emprego, pelo administrador, de esforços necessários e suficientes para o alcance de determinado resultado.

outros (conforme: RIBEIRO, Renato Ventura. *Dever de diligência dos administradores de sociedades*. São Paulo: Quartier Latin, 2006, pp. 221-231; EIZIRIK, Nelson. *A Lei das S/A Comentada – Artigos 138 ao 205*. 2ª ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. v. III, pp. 120-124; PARENTE, Flávia. *O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 101-131; BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. *A Administração de Companhias e a Business Judgment Rule*. São Paulo: Quartier Latin, 2017, pp. 60-68).

¹⁷ Tais parâmetros também foram reconhecidos na análise de casos concretos, conforme demonstram os diversos precedentes que afastaram a responsabilidade pelo descumprimento do dever de diligência quando adotados esses comportamentos: PAS CVM nº 21/04, j. em 15.05.2007; PAS CVM nº RJ2008/9574, j. em 27.11.2012; PAS CVM nº 11/2002, j. em 26.02.2013; e PAS CVM nº 02/2008, j. em 05.03.2013, entre outros.

¹⁸ A respeito, veja-se voto do Diretor Gustavo Gonzalez: “*De plano, parece-me importante registrar – sem nenhuma pretensão, todavia, de esgotar o assunto – a importante distinção entre os padrões de conduta e os padrões de revisão adotados para verificar, ex post, o cumprimento dos deveres fiduciários. (...) Embora por vezes inadvertidamente considerados como intercambiáveis, o dever de diligência é padrão de conduta, que não se confunde com um padrão de revisão. A regra da decisão negocial, por sua vez, é um padrão de revisão, que em nossa jurisprudência administrativa protege decisões tomadas de modo informado, refletido e desinteressado. Confundir o dever de diligência com a business judgment rule conduziria à conclusão de que uma decisão interessada não poderia ser considerada diligente, o que, a toda evidência, não corresponde à realidade, nem reflete o sistema da nossa lei. O administrador interessado que toma uma decisão negocial pode não estar protegido pela business judgment rule, fato que não lhe exime, de modo algum, de atuar de forma diligente e tampouco permite concluir, sozinho, pela falta de diligência*”. (PAS CVM nº RJ2013/11703, j. em 31.07.2018)

¹⁹ CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). *Direito das Companhias*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 805. No mesmo sentido: “*En primer lugar, resulta claro, a nuestro entender, que el deber de diligencia aplicable a la gestión no puede ser entendido como <<otra fuente más>> al mismo nivel que lo son las fuentes normales consideradas hasta ahora (ley, estatutos, acuerdos, etc.). Estas imponen obligaciones específicas, de contenido determinado, cuyo cumplimiento se agota, normalmente, en la realización o ejecución de lo que en ellas venga exigido. El deber de diligencia, por el contrario, es una pauta de administración de la sociedad. En este sentido, el deber de diligencia expresa también la forma en que deben ser cumplidas las obligaciones puntuales que emanan de las fuentes formales indicadas. Así entendido, como forma de cumplimiento de las obligaciones según las pautas establecidas en su momento, es obvio que el deber de diligencia no es algo ajeno a las fuentes de esas obligaciones. Las fuentes indican qué obligaciones ha de cumplir el administrador y de dónde provienen; el deber de diligencia indica cómo se deben de cumplir esas obligaciones, qué comportamiento es exigible a los administradores en general, en una sociedad determinada, etc.*” (GONZALEZ, Jesus Quijano. *La responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anonima: aspectos sustantivos*. Universidade de Valladolid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca, 1985, pp. 186/187).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

26. Tipicamente, a diligência de determinada conduta é examinada sob o aspecto negocial ou fiscalizatório²⁰. O primeiro refere-se às decisões tipicamente negociais em face das quais impõe-se o teste da *business judgment rule*. O segundo abarca dimensão voltada à supervisão das mais variadas atividades da companhia²¹, no âmbito da qual a diligência é aferida a partir da verificação da razoabilidade e adequação dos esforços despendidos pelo administrador no desempenho de sua função.

27. E nesse ponto cabe notar que o dever de diligência vale para todos os administradores, independentemente de suas funções e poderes²², inclusive sob o prisma fiscalizatório. Quero com isso dizer que, não obstante a Lei das S.A. ser expressa no que toca ao dever dos Conselheiros de fiscalizar a gestão dos Diretores (art. 142, III), é natural que um Diretor atento à gestão da Companhia tenha ciência de iniciativas que estejam sendo conduzidas por outros Diretores e que, por suas características, mereçam sua atenção e postura vigilante²³.

²⁰ Conforme expôs o então Diretor Otavio Yazbek, “o conteúdo do dever de diligência possui duas naturezas distintas: uma de cunho negocial, sujeita ao teste da *business-judgment rule*; e outra de natureza fiscalizatória, sujeita a uma análise de razoabilidade e de adequação” (PAS CVM nº 24/2006, j. em 18.02.2013). Esta lógica foi explorada com mais detalhe por referido Diretor em artigo sobre o tema, em relação ao qual destaco as seguintes passagens: “[f]oi nesse processo que se consolidou (...) a distinção entre um conteúdo gerencial do dever de diligência e um conteúdo mais supervísório ou fiscalizatório. A rigor, estes difeririam entre si não apenas em razão do tipo de cuidado requerido dos administradores, mas também em razão da forma pela qual se apura, em cada caso, a legitimidade do comportamento destes. Para a decisão tipicamente negocial, impõe-se o teste da chamada *business judgment rule*: se a decisão foi tomada com base em informações adequadas e suficientes, com boa-fé e procurando atender aos interesses da companhia, o administrador não pode ser punido pelos resultados que dela decorreram. Entender de maneira distinta seria permitir que os julgadores avaliassem o mérito de decisões de negócio, ingressando em seara que foge aos limites do dever de diligência propriamente dito. Por outro lado, quando se está tratando de dever de monitoramento, ao menos nas suas formas mais típicas, não há que se falar em aplicação da *business judgment rule* pelo simples fato de inexistir uma decisão propriamente negocial, conformadora dos resultados obtidos – impor-se-ia então a verificação da razoabilidade e da adequação dos esforços despendidos pelo administrador nas suas atividades.” (YAZBEK, Otavio. Representações do Dever de Diligência na Doutrina Jurídica Brasileira. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Coord.). *Temas essenciais de direito empresarial – Estudos em homenagem a Modesto Carvalhosa*. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 944).

²¹ Destaca-se, para ilustrar esse ângulo do dever de diligência, a seguinte passagem de voto proferido pelo então Diretor Otavio Yazbek: “[s]e não por outro motivo porque, ao proceder dessa maneira, ignora-se que o dever de diligência não se resume ao dever de tomar decisões negociais diligentes, envolvendo, também, toda uma dimensão voltada à supervisão das atividades da companhia, à qual não se aplicam os mesmos parâmetros (i.e., se se trata de decisões tomadas de maneira informada, refletida e desinteressada). (...) Em casos como esse, mais do que uma ênfase no procedimento, a apuração da conduta dos administradores, ao que me parece, deve passar pela análise concreta da forma pela qual se ‘procedimentalizaram’ as atividades dentro da sociedade. Há que se avaliar se os procedimentos criam uma razoável segurança para as atividades da companhia e, para que isto aconteça, é necessário verificar se a ‘procedimentalização’ dos controles internos é razoável e adequada” (PAS CVM nº 24/2006, j. em 18.02.2013).

²² Nesse sentido, ver RIBEIRO, Renato Ventura. *Dever de diligência dos administradores de sociedades*. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 218.

²³ O papel fiscalizatório dos diretores é reconhecido no Direito das Companhias: “[a]s atribuições [dos Diretores] em geral são definidas segundo cargos usualmente designados, entre outros, Diretor-Presidente, industrial, financeiro, comercial e administrativo, que compreendem a direção e fiscalização de determinadas atividades e serviços da empresa. Os poderes de diretores são de gestão ou administração e de representação.” (DE SOUZA JR., Luciano. Título VI - Órgãos Sociais In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). *Direito das Companhias*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 772).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

28. Por ser estabelecido como um padrão aberto, é de se esperar que o atendimento do dever de diligência seja possível, via de regra, de múltiplas formas²⁴. Se cada decisão tomada pelo administrador deve refletir uma convicção formada no interesse da companhia ao final da devida reflexão, isso não quer dizer que todo administrador, diante da mesma situação, somente terá um caminho a seguir para dar cumprimento ao seu dever de diligência.

29. É dizer: o sistema da lei societária aceita uma pluralidade de respostas diante das mesmas situações. Como resultado, o que torna determinada conduta questionável sob o ponto de vista da diligência é exatamente a ausência dos elementos necessários para o atingimento do padrão de cuidado exigido pelo art. 153²⁵.

30. É inclusive por conta desse amplo alcance que, na sistemática vigente, o art. 153 é o núcleo a partir do qual os demais padrões de conduta emanam da Lei nº 6.404/76²⁶. É assim, por exemplo, que o dever de diligência orienta e se relaciona com o dever de comunicar o mercado sobre atos ou fatos relevantes, nos termos estabelecidos pelo art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76²⁷ e pela Instrução CVM nº 358/02, que regulamenta referido dispositivo. Esta relação se dá na medida em que o cumprimento do dever de informar está, invariavelmente, condicionado à adoção de

²⁴ Evidentemente, não se pode ignorar que, na vida empresarial, vez ou outra a situação que se apresenta não permite ao administrador uma multiplicidade de escolhas.

²⁵ Ao referir-se ao dever de diligência como obrigação de meio e descrever como se prova seu descumprimento, Marcelo Vieira Von Adamek enfatiza esse racional: “no caso da obrigação de meio, o interessado precisa provar a completa omissão do obrigado em adotar qualquer comportamento (= não geriu) ou, o que é mais comum suceder, provar que a conduta do obrigado não foi conforme o padrão ordinário de administrador diligente, de modo a assim caracterizar a culpa do administrador, e o correlato dever de reparar os danos que sejam decorrência direta e imediata de seu comportamento antijurídico” (ADAMEK, Marcelo Vieira Von. *Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as ações correlatas*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 134).

²⁶ Conforme entendimento do Colegiado manifestado por ocasião dos julgamentos dos PAS CVM nº RJ2013/1402 e RJ2008/9574, respectivamente em 22.07.2014 e 27.11.2012. A doutrina corrobora essa interpretação ao afirmar que “[a] chave interpretativa do sistema de responsabilidade dos administradores das companhias é o dever de diligência, previsto no artigo 153 da LSA. É ele o guia seguro que permitirá a aplicação adequada e justa do sistema de responsabilidade dos administradores, que, se bem aplicado, a um só tempo não permitirá que se cometam excessos e que se entorpeça a ação, sem deixar os administradores negligentes livres de qualquer responsabilidade. (...) Portanto, a todo o tempo o intérprete deverá, à luz da conduta e da estrutura específica, remeter-se ao dever de diligência para aferir se houve ou não inadequação da conduta” (CAMPOS, Luiz Antonio Sampaio. Conselho de Administração e Diretoria. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). *Direito das Companhias*. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 870-871) e, ainda, que “[a] lei impõe deveres específicos aos administradores, deveres esses que se entroncam na ampla proposição contida no art. 153” (GUERREIRO, José Alexandre Tavares. Responsabilidade dos administradores de sociedades anônimas. In: *Revista de direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 42, 1981, p. 73).

²⁷ Art. 157. § 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

conduta diligente, sendo possível afirmar que existe uma zona de interseção entre o dever de informar e o dever de diligência²⁸.

31. A corroborar com este entendimento, o Colegiado da CVM já teve a oportunidade de se manifestar, em sede de julgamento de processos administrativos sancionadores em que a responsabilidade pelo descumprimento do dever de informar foi analisada sob o prisma da diligência²⁹, no sentido de afastar tal responsabilidade a partir da constatação de que os acusados não deixaram de adotar conduta diligente³⁰.

32. É importante reforçar que a interseção entre os deveres de diligência e de comunicar ao mercado atos ou fatos relevantes não se restringe a aspectos fiscalizatórios, mas materializa-se,

²⁸ Acerca da relação entre o dever de diligência e o dever de informar, especificamente o de divulgar fatos relevantes, Flávia Parente afirmou: “[a]ssim, os administradores estarão atuando com diligência se prontamente efetuarem a divulgação dos fatos relevantes de que tenham conhecimento. Com efeito, o dever de disclosure advém não apenas do dever de lealdade, como também do dever de diligência. O dever de diligência impõe, ainda, aos administradores a obrigação de verificar se a companhia tem condições de efetuar a divulgação de fatos relevantes de maneira adequada, estabelecendo procedimentos específicos para tanto e supervisionando seu cumprimento. (...) A partir do momento em que o administrador tem a obrigação de verificar se a companhia está preparada para realizar adequadamente o disclosure e, ainda, de supervisionar o exato cumprimento dos procedimentos internos que estabelecem a política de transparência e divulgação de informações pela companhia, conclui-se que, também sob esse aspecto, o dever de diligência está relacionado ao dever de informar” (PARENTE, Flávia. *O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, pp. 245/246). A mesma lógica também é observada no direito norte-americano. Ao descrever o “standard of care” à luz das atividades de supervisão e monitoramento dos administradores, Regina Burch afirma: “For example, the duty of care gives rise to the duty to monitor and to exercise oversight, the duty to remain informed about the corporation, the duty to regularly review financial statements and devote attention to board duties and the duty to inquire into corporate affairs. Further, the duty of loyalty gives rise to the duty not to usurp corporate opportunities, the duty not to engage in improper self-dealing transactions with the corporation, and the duty not to transfer control of corporate assets to a third-party who may loot those assets. And the duties of care and loyalty give rise to the duty to properly disclose material information about the company. These subsidiary duties often overlap” (BURCH, Regina F. Director Oversight and Monitoring: The Standard of Care and the Standard of Liability Post-Enron, in *Wyoming Law Review*, v. 6, Number 2, 2006, p. 488).

²⁹ Confira-se, nesse sentido, o PAS CVM nº RJ2014/6225 (j. em 18.04.2017) e o PAS CVM nº RJ2014/3402 (j. em 13.12.2018). Em relação a este último destaque o seguinte trecho do voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez: “Diante dessas circunstâncias, a defesa sustenta não ser razoável exigir que o DRI de uma companhia com tamanha exposição midiática conheça e analise todas as notícias que são veiculadas a respeito dessa companhia. Em tese, o argumento é válido. Embora a regulamentação editada pela CVM atribua ao diretor de relações com investidores um dever de monitoramento de mercado, tal dever precisa ser construído a luz do dever geral de diligência e não como uma infração objetiva. (...) Nesse contexto, parece-me evidente que um diretor com relações com investidores pode, em certas situações, se eximir de responsabilidade administrativa por não ter divulgado fato relevante quando a notícia fugiu do controle mediante demonstração de que a companhia possuía controles razoáveis para monitorar o mercado que, todavia, não identificaram um pequeno vazamento. A decisão final, naturalmente, dependerá das circunstâncias específicas do caso concreto” (grifou-se).

³⁰ Confira-se, nesse sentido, a passagem do voto proferido pelo Diretor Relator Henrique Machado no PAS CVM nº RJ2014/12710 (j. em 05.12.2017), em que foi acompanhado pela unanimidade do Colegiado: “Desta maneira, não parece razoável exigir que o DRI conseguisse, a partir das 15h50min, verificar um movimento de alta na ação, concluir que houve oscilação atípica, preparar o Fato Relevante sobre uma operação complexa e de extrema importância para a Companhia, tudo isso em pouco mais de uma hora. 27. Sem dúvidas, a pronta divulgação de fatos relevantes é de extrema importância para o cumprimento do princípio do full and fair disclosure, a fim de evitar a assimetria informacional e negociações com informações privilegiadas, que põe em risco o funcionamento regular do mercado. No entanto, deve-se exigir do DRI o cuidado e a diligência de um homem ativo e probo, e não uma tarefa impossível de ser cumprida. (...) Não se mostra razoável e proporcional esperar que houvesse a divulgação desse fato relevante nas circunstâncias do caso em apreço. 30. Portanto, entendo que não restou configurada infração ao art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02, combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, razão pela qual voto pela absolvição do Acusado”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

necessariamente, sempre que se avalia a conduta dos administradores sob a perspectiva procedimental, com o objetivo de verificar, à luz das circunstâncias do caso concreto, se os esforços por eles adotados foram razoáveis e adequados para se desincumbirem das obrigações que lhes são impostas pelo art. 157, §4º e pela Instrução CVM nº 358/02³¹.

33. Para ilustrar a interação entre esses dois deveres, tome-se como exemplo a atuação do Diretor de Relação com Investidores (DRI) na divulgação de fatos relevantes³². Entre os deveres impostos pela Instrução CVM nº 358/02 ao DRI para que realize adequada divulgação de informações ao mercado, inclui-se o dever de monitoramento, segundo o qual o DRI deverá dotar-se dos meios razoavelmente necessários para monitorar o vazamento de informações e a oscilação atípica dos valores mobiliários de emissão da Companhia³³.

34. Assim, será diligente o DRI que, por descuido, falhar nessa supervisão, o que levará, nesta hipótese, ao descumprimento do art. 6º, parágrafo único da Instrução CVM nº 358/02. Esses deveres, é importante lembrar, não estão restritos à esfera de atuação dos sujeitos que ocupam cargos de DRI, estendendo-se aos demais administradores³⁴⁻³⁵.

³¹ A título de exemplo da análise realizada pelo Colegiado, à luz do aspecto procedimental, ver PAS CVM nº 01/2007 e do PAS CVM nº RJ2008/9574, julgados respectivamente em 22.09.2016 e 27.11.2012.

³² Outros pontos de intersecção, é bom que se diga, podem ser identificados a depender das circunstâncias e particularidades de cada situação.

³³ A este respeito, destaco a seguinte passagem do voto proferido pelo Diretor Gustavo Gonzalez, no qual foi acompanhado por unanimidade do Colegiado, em processo sancionador que apurava a conduta de DRI por não ter tempestivamente efetuado a divulgação de fato relevante: *“Tais decisões parecem apenas refletir certa perplexidade com executivos que argumentam cumprir plenamente com os deveres que lhes foram atribuídos nas normas da CVM, mas não são capazes de demonstrar os critérios que utilizavam para se desincumbir de suas obrigações (que, no caso dos diretores de relações com investidores, incluem um dever de monitoramento do mercado). 53. Sendo mais específico, se o diretor de relações com investidores deve atuar caso os valores mobiliários da companhia se comportem de forma atípica, parece razoável esperar que tais executivos, de forma diligente, busquem criar parâmetros que indiquem o comportamento típico do mercado e situações em que, aparentemente, existe atipicidade”* (grifou-se) (PAS CVM nº RJ2015/1591, j. em 26.09.2017).

³⁴ Sobre isso, reporto-me ao seguinte trecho do voto proferido pelo então Diretor Pablo Renteria: *“50. Vale lembrar que, nos termos do art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, o dever de informar e, notadamente, o dever de divulgar fato relevante ocorrido nos negócios da companhia aberta incumbe a todos os administradores e, por extensão, aos membros do conselho fiscal e dos demais órgãos com previsão estatutária. Ao acionista controlador, dada a posição peculiar de comando que ocupa no seio da companhia, também se atribui obrigação semelhante. 51. Ainda que se reconheça a divisão de competências e responsabilidades, estabelecida nas Instruções CVM nº 358/2002 e 480/2009, entre, de um lado, o diretor de relações com investidores e, de outro, os demais administradores, acionistas controladores, conselheiros fiscais e integrantes de órgãos estatutários, é certo que estes últimos devem desempenhar com diligência as atribuições relativas ao dever de informação que lhe são reservadas nos termos da legislação vigente. 52. No contexto do comando previsto no art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, isso significa que as pessoas acima mencionadas devem dotar-se dos meios necessários para que estejam em condições de verificar eventual descontrole da informação, ou oscilação atípica nos negócios envolvendo valores mobiliários da companhia e, ainda, a eventual omissão do diretor de relações com investidores no cumprimento do dever de divulgar imediatamente o fato relevante. Dessa forma, e valendo-me de uma expressão em voga nos dias atuais, tais pessoas estariam efetivamente atuando como uma “segunda linha de defesa”, tal como pretendido pela norma da CVM”* (grifou-se) (PAS CVM nº RJ2014/6225, j. em 18.04.2017).

³⁵ Observo, nesse sentido, que, muito embora a Instrução CVM nº 358 tenha consagrado a responsabilidade primária do DRI de zelar pela ampla e imediata disseminação de informações relevantes relacionadas aos negócios da companhia, esta mesma instrução previu expressamente que, caso outros administradores tenham conhecimento



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

35. Feitas essas considerações sobre o conteúdo legal do dever de diligência e sua relação com o dever de informar, observo que a análise de seu cumprimento por determinado administrador deve considerar, ao menos:

- (i) suas competências legais e estatutárias (e, eventualmente, atribuições adicionais desempenhadas na prática), as quais definirão se o acusado tinha um dever de conduzir pessoalmente determinado assunto ou realizar determinado ato, ou se sua atribuição consistia em fiscalizar a execução de referido trabalho;
- (ii) o grau de técnica da matéria analisada, cuja medida determinará o envolvimento direto do administrador nas discussões a respeito ou então exigirá e justificará a consulta a especialistas internos ou a contratação de externos (*reliance defense*³⁶); e
- (iii) a existência de sinais de alerta que apontem para a irregularidade posteriormente identificada pela acusação, os quais justificarão a exigência de uma fiscalização mais atenta e assídua quanto a assuntos ou atos específicos.

36. Entendo que a análise desses três aspectos trará subsídios para que se possa aferir, com certa margem de segurança, o cumprimento dos já referidos subdeveres de se informar, vigiar e investigar, e determinar se os acusados escolheram meios adequados e empregaram esforços proporcionais aos esperados de um administrador diligente na mesma função, considerando-se os fatos e ambiente então vigentes³⁷.

37. Transportando esse raciocínio para o caso concreto, é necessário verificar, portanto: (i) qual foi o envolvimento de Luiz Carneiro na elaboração do Fato Relevante; (ii) se havia justificativa plausível para a não inclusão das informações mais detalhadas sobre o estágio da análise da viabilidade dos Campos no Fato Relevante; e (iii) se foram evidenciadas pela acusação

pessoal sobre essas informações e constatem a omissão do DRI, deverão comunicar imediatamente referido ato ou fato relevante à CVM, sob pena de serem responsabilizados (vide art. 3º, §2º).

³⁶ Teoria que resulta de construção jurisprudencial norte-americana, segundo a qual um administrador pode alegar, em resposta a acusação por conduta negligente, que contava com a atuação de outro administrador, de especialista ou de comitê de assessoramento, por exemplo, para o tratamento do assunto em questão. Obviamente, tal defesa não pode ser utilizada irrestritamente nem servirá para que um administrador a empregue por mera conveniência. Vejamos exemplo de aplicação desta defesa: “...o conselho de administração buscou o auxílio de profissionais externos e especializados para confirmar a razoabilidade dos termos negociados. Dentre tais profissionais encontram-se tanto advogados externos quanto um consultor de recrutamento, que em sua análise concluiu que os tipos de gatilho e os valores propostos estavam em linha com as práticas de mercado. Não existe nenhum elemento nos autos que desabone o aconselhamento prestado ou que indique que os administradores não atuaram de boa-fé, ignorando sinais de alerta, razão pela qual esse aconselhamento também deve ser reconhecido como defesa.” (Manifestação de Voto apresentada pelo Dir. Gustavo Gonzalez, em 31.07.2018, nos autos do PAS CVM nº RJ2013/11703).

³⁷ Cabe lembrar que: “[a]o contrastar a conduta do administrador à luz do dever de diligência, o intérprete não pode olvidar a necessidade de, em sede de juízo retrospectivo, aferir as alternativas disponíveis por ocasião da tomada da decisão, à luz da realidade e dos fatos da época, e não depois dos fatos consumados. Não há de perquirir propriamente se a decisão tomada foi a melhor possível, à vista do que posteriormente sucedeu. Deve-se analisar, sim, se, por ocasião da tomada da decisão, a conduta do administrador foi razoável e apropriada à luz dos fatos e do ambiente então vigentes.” (ADAMEK, Marcelo Vieira Von. *Responsabilidade Civil dos Administradores de S/A e as ações correlatas*. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 128)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

falhas procedimentais indicando falta de diligência por parte do acusado, que contribuiu para a divulgação inadequada do Fato Relevante. Conforme passarei a explicar, não logrei identificar, na narrativa da acusação, elementos que me permitissem tal conclusão.

38. Neste sentido, o primeiro ponto que gostaria de destacar é sobre o papel de Luiz Carneiro na divulgação, pela Companhia, de atos ou fatos relevantes. Consoante exposto pelo Diretor Relator, a Companhia apresentava política interna de divulgação e uso de informações, que previa a existência de um “*Comitê de Divulgação e Negociação*”, cuja direção cabia a Luiz Carneiro³⁸. Entre as principais atribuições do Comitê estava “*a avaliação da relevância e materialidade de atos ou fatos ocorridos e relacionados aos negócios da Companhia e a supervisão do processo de difusão de informações ao mercado*”³⁹. Nota-se, pois, que a governança interna da OGX atribuía ao Diretor Presidente papel substancial na divulgação de atos ou fatos relevantes.

39. Embora os administradores da Companhia tenham afirmado que, por questões de praticidade, referido comitê jamais fora instalado, declararam que, na prática, o órgão funcionava conforme previsto⁴⁰. Ao descrever a rotina de elaboração e divulgação de fatos relevantes e comunicados ao mercado pela Companhia, o próprio acusado atestou que “*uma vez estruturada determinada informação das áreas competentes da companhia, as minutas dos Fatos Relevantes e dos Comunicados ao Mercado da OGX eram circuladas aos demais diretores (...) a fim de que pudessem comentá-los*”⁴¹.

40. A prática que se adotava na Companhia com relação à divulgação de fatos relevantes demonstra, portanto, que a função do acusado nessa atividade extrapolava o mero acompanhamento do assunto, tendo participação direta na revisão de anúncios de fatos relevantes e ampla margem para intervir nas minutas preparadas pela área de RI, propondo ajustes e comentários. Vale destacar, aliás, que, especificamente com relação ao Fato Relevante, constou de sua redação declaração pessoal de Luiz Carneiro a respeito das informações divulgadas

³⁸ De acordo com a política, além do diretor presidente, também compunham o comitê o diretor de relações com investidores, o diretor jurídico (se houvesse) e o gerente de relações com investidores e/ou representantes por eles indicados (fl. 654).

³⁹ Conforme item 7 da Política (fl. 654).

⁴⁰ Conforme manifestações de Marcelo Faber Torres (Diretor de Relações com Investidores) (fl. 1382), José Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti (Diretor Jurídico) (fl. 1419), Roberto Bernardes Monteiro (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores) (fls. 1454/1455) e Paulo de Tarso Martins Guimarães (Diretor de Exploração) (fls. 1485/1486).

⁴¹ Confira-se o trecho da declaração de Luiz Carneiro na íntegra: “*uma vez estruturada determinada informação das áreas competentes da companhia, as minutas dos Fatos Relevantes e dos Comunicados ao Mercado da OGX eram circuladas aos demais diretores e, posteriormente, à área de Relações com Investidores da EBX. Nesse procedimento, garantia-se que todos os diretores – e, portanto, todos aqueles que seriam os membros do Comitê – tivessem prévio acesso ao conteúdo de tais documentos, a fim de que pudessem comentá-los, alcançando, desta forma, o objetivo do Comitê, mas sem a necessidade de reuniões formais*” (fl. 1468).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

naquela oportunidade⁴², o que reforça, uma vez mais, seu envolvimento direto na elaboração desse documento.

41. Consequentemente, não considero plausível que a redação do Fato Relevante tenha passado ao largo do escrutínio do acusado, sem que este fizesse as devidas ponderações, o que denotaria negligência ao revisar a minuta. Ao contrário disso, os elementos constantes dos autos⁴³ indicam que Luiz Carneiro revisou refletida e detidamente o Fato Relevante, tendo anuído com seu conteúdo.

42. Tendo isso em vista, torna-se necessário avaliar em qual extensão a conduta do acusado quanto à divulgação ao mercado de informações relevantes denota, no caso concreto, falta de diligência para, então, concluir sobre sua responsabilização pelo descumprimento deste último.

43. Entendo pertinente, assim, conferir se o acusado se desincumbiu dos seus deveres de se informar, investigar e vigiar naquilo que concerne à exploração dos Campos, o que, ao meu ver, seria forte indicativo de que não houve falta de diligência quanto a seu dever de revelar ao mercado atos ou fatos relevantes sobre os negócios da Companhia.

44. Isso porque a constatação de que o acusado se manteve inerte em face das análises e discussões da exploração dos Campos e, por essa razão, permitiu a divulgação do Fato Relevante de forma incompleta, demonstraria conduta abaixo do padrão de diligência necessário para o cumprimento do seu dever de informar.

45. Observo, quanto a esse propósito, que, desde sua posse como Diretor Presidente da OGX, o acusado transferiu a competência sobre a área de reservatórios, especializada na avaliação do volume de óleo recuperável nos Campos, para a própria presidência da Companhia, e substituiu o gerente executivo da área de reservatórios, medidas que demonstram que, mais que se informar sobre os estudos acerca da exploração das acumulações de petróleo da OGX, envolveu-se diretamente na condução desse tema na Companhia, acompanhando de perto o seu desenvolvimento.

46. Nesse contexto, também é possível constatar que Luiz Carneiro investigou com maior atenção questões que considerou sensíveis, a exemplo daquelas relacionadas às divergências

⁴² Conforme exposto na nota de rodapé nº 3 desta manifestação de voto.

⁴³ Incluindo a ausência de elementos trazidos pela defesa para demonstrar que o acusado não participou da elaboração do Fato Relevante. Ao invés disso, a defesa limitou-se a afirmar que “[q]uanto aos fatos relevantes publicados durante a sua gestão, os Srs. Luiz Carneiro e Paulo de Tarso, dentro da competência de cada um, sempre atuaram tentando alcançar o melhor resultado possível para a Companhia” (fl. 2492).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

internas acerca da estimativa do volume de óleo recuperável. Consoante expôs a defesa, logo depois de assumir o cargo de Diretor Presidente, Luiz Carneiro promoveu a avaliação de alguns ativos da OGX, dentre os quais a Bacia de Campos⁴⁴, a fim de aprofundar a análise de aspectos que geravam dúvidas entre os técnicos especializados em reservatório e em exploração quanto ao volume de óleo recuperável⁴⁵. E, de posse dos resultados dessa primeira avaliação, recomendou a constituição de grupo de trabalho destinado a aprofundar o conhecimento sobre o potencial de produção dos reservatórios e esclarecer as divergências técnicas entre a área de exploração e de reservatórios⁴⁶.

47. Em vista desses elementos, não vislumbro sinais de que o acusado tenha faltado com seu dever de se informar, de investigar ou vigiar com relação às informações referentes à viabilidade econômica da exploração dos Campos, uma vez que procurou se inteirar sobre o assunto, identificou questões que exigiam maior atenção dedicando-se a melhor compreendê-las.

48. Noto que a própria acusação reconheceu a adequação dos esforços empreendidos pela administração ao afirmar que “[n]ão é preciso análise tão profunda para que se chegue a conclusão de que os administradores tentaram realizar todos os estudos possíveis para divulgarem, com o maior nível de certeza possível, que os Campos eram comercialmente inviáveis” (fl. 2212).

49. Diante do exposto, tampouco se verifica, nos autos, a existência de sinais de alerta não investigados pelo Diretor Presidente, capazes de revelar falhas procedimentais de sua parte na divulgação do Fato Relevante. Ao que parece, ao menos Luiz Carneiro ponderou a inclusão das informações sobre as incertezas relacionadas à inviabilidade dos Campos, tendo concluído pela não divulgação dessas informações com base no permissivo legal constante do art. 157, § 5º.

50. Tampouco encontrei nos autos evidências de que as Incertezas não tinham relação direta com as informações divulgadas no Fato Relevante a indicar que a análise sobre sua divulgação tivesse passado despercebida, ou de que a administração da OGX tenha se fundamentado em justificativas razoáveis no sentido de que a não inclusão dessas informações no Fato Relevante não comprometeria a veracidade ou compreensão de seu conteúdo. Nesse tocante, os acusados se

⁴⁴ Na qual se situavam as acumulações de petróleo relativas aos Campos.

⁴⁵ De acordo com a defesa, esse relatório teria sido elaborado para avaliar com maior profundidade alguns dados considerados, até então, como verdadeiros pela Companhia, dentre os quais os resultados preliminares positivos em relação aos campos Pipeline, Fuji, Illimani e Osorno apresentados pela administração anterior e que suscitaram dúvidas entre os técnicos especializados em reservatórios e em exploração quanto ao volume de óleo recuperável (fls. 2471/2472).

⁴⁶ Nos exatos termos em que constou do documento apresentado à Diretoria com as conclusões do grupo de trabalho, estava no escopo de suas atividades a “[e]laboração do conceito de produção, estimativa de prazos, ajuste na previsão de produção, estimativas de custo e prazo e análise econômica” (fl. 102).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

limitaram a alegar que os fatos divulgados em tal documento também foram divulgados pela ANP, o que criaria uma situação de assimetria informacional no mercado. Ora, não se discute aqui o cabimento da divulgação do Fato Relevante, mas sim a insuficiência das informações transmitidas através de tal documento, de modo que tal alegação não se prestou a atender aos fins desejados.

51. Repito que, caso houvesse uma explicação razoável, que envolvesse uma conduta diligente por parte do administrador, esta poderia até mesmo afastar a responsabilização de administrador que tivesse se mostrado diligente ao longo do processo decisório. Afinal, não caberia à CVM entrar no mérito de decisão informada e refletida que, posteriormente, tenha se revelado prejudicial. Mas a verdade é que tal narrativa não foi explorada nos autos, seja pela acusação ou pela defesa.

52. Diante do quadro acima descrito, a dificuldade que enxergo em relação à configuração do descumprimento do art. 153 da Lei nº 6.404/76 no caso concreto é justamente a ausência dos elementos caracterizadores da falta de diligência na conduta do acusado, seja na condução de atividade crucial para o êxito da companhia – exploração dos Campos –, seja na condução, junto com o DRI, do reporte deste tema ao mercado. Em outras palavras, não faltou, de parte de Luiz Carneiro, naquilo que lhe cabia na revisão do documento, diligência. O que parece ter havido, isso sim, foi uma escolha consciente por não fazer constar informação entendida como passível de pôr em risco interesse legítimo da Companhia. Assim sendo, concluo que a conduta que, segundo a acusação, era esperada do acusado – assegurar que o Fato Relevante contemplasse informações sobre os problemas técnicos já conhecidos pela Companhia para desenvolver os Campos – não resultou de falta de diligência.

53. Todavia, em que pese meu entendimento pela inexistência de nexo causal entre uma suposta falta de diligência e a divulgação do Fato Relevante omissa, entendo que houve um erro inescusável por parte dos responsáveis por sua elaboração, justamente por ser obrigatória a divulgação de *“informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”*, nos termos do art. 14 da Instrução CVM nº 480/09. Dessa forma, ainda que as informações divulgadas no Fato Relevante sejam verdadeiras e compatíveis com o que seria divulgado pela ANP, é inegável que seus destinatários mantiveram expectativas positivas quanto aos Campos, sendo induzidos a erro.

54. Exatamente por isso, acompanho o Diretor Relator quanto a suas conclusões sobre o DRI da OGX, Roberto Bernardes Monteiro. Acertadamente, a acusação imputou-lhe responsabilidade pelo descumprimento da infração objetiva constante do art. 14 da Instrução CVM nº 480/09. Pelo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

que já foi exposto ao longo desta manifestação, entendo que, no caso concreto, os acusados não conseguiram trazer aos autos elementos que tornassem excusável a ausência de informações sobre as Incertezas relacionadas à rentabilidade dos Campos no Fato Relevante. Com efeito, voto pela condenação de Roberto Monteiro da acusação de descumprimento do art. 14 da Instrução CVM nº 480/09.

55. Antes de concluir, me parece importante fazer rápidas ponderações finais sobre o que considero um aspecto relevante dos limites e possibilidades do padrão de conduta previsto no art. 153 da Lei nº 6.404/76.

56. O dever de diligência representa um dos principais instrumentos de controle e disciplina da atuação dos administradores por sua abrangência e seu caráter orientador dos demais deveres fiduciários. Sem embargo, é preciso ter cautela na sua utilização como meio de aferição da conformidade dos atos praticados por administradores, de modo a evitar sua utilização, na prática, como uma garantia ampla contra a falibilidade dos administradores.

57. Essa interpretação mais extensiva pode trazer efeitos práticos relevantes, como por exemplo dificultar sobremaneira a compreensão, pelos próprios administradores, dos padrões de conduta que a lei lhes impõe, o que pode, por sua vez, servir como desincentivo para que pessoas capazes e honestas aceitem cargos na administração de companhias⁴⁷.

58. Por esse motivo, entendo que a responsabilização de administradores de companhias abertas por falta de diligência deve ser construída na extensão que a lei conferiu a este dever, notadamente quando se avalia determinada conduta sob a perspectiva procedimental e quando ausentes os elementos que demonstram o cuidado necessário por parte do administrador. Deve-se, assim, reconhecer que o descumprimento de um dispositivo legal ou regulamentar específico nem sempre será motivado pela falta de diligência. Do mesmo modo, nada na lei autoriza o entendimento de que a inobservância de um dever fiduciário sempre significará, também, falta de diligência.

⁴⁷ Ao discorrer sobre a individualidade dos deveres dos integrantes do conselho de administração, Luiz Antonio Sampaio Campos constrói lógica que se aplica a essa consideração: “[a] estrutura dualista na administração da companhia não pode ser ignorada, sob pena de afugentar pessoas capazes, honestas e competentes, de aceitarem participar do Conselho de Administração, por conta da eventual extensão dos deveres e responsabilidades dos administradores a excessos utópicos, que tornaria o risco da posição inaceitável à luz das contrapartidas que teriam no exercício do cargo e culminaria por desvirtuar, por completo, a estrutura do Conselho de Administração. Esses preceitos devem pautar a atuação do intérprete e do aplicador da lei” (CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Deveres e responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coords.). *Direito das Companhias*. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 798).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

59. Feitas essas ponderações e retomando o caso concreto, é importante reiterar: não discordo quanto à conduta do acusado ter se revelado inadequada. Entretanto, sem que haja indicação clara de falta de diligência, corre-se o risco de alargar o conceito de um dever fiduciário previsto em lei que, a despeito de sua centralidade no sistema disciplinar dos administradores de companhias, não pode se prestar a garantir a responsabilização a qualquer custo, mesmo quando faltarem melhores elementos relacionados a outros deveres mais específicos – tanto mais em sede de formação de juízo condenatório.

60. Por essas razões, embora reconheça que a atuação de Luiz Carneiro não atendeu ao que dele se poderia esperar com base na lei societária, e que sua decisão contribuiu para a postergação de divulgação de alerta, via fato relevante, sobre a situação de incerteza econômica vivida pela OGX, não vejo como responsabilizá-lo pelo descumprimento do art. 153, da Lei nº 6.404/76, motivo pelo qual voto por sua absolvição de tal acusação.

61. Por fim, com relação aos demais acusados deste processo, acompanho as conclusões do voto do Diretor Relator.

É como voto.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019.

Marcelo Barbosa

Presidente